

ALFREDO DI PIETRO

Profesor titular ordinario
en las Facultades de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires
y de la Pontificia Universidad Católica Argentina

DERECHO PRIVADO ROMANO

2ª edición

Reimpresión



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

1ª edición: 1996
2ª edición: 1999

A Amelita, mi *dilectissima uxor*.
A mis *dilectissimi filii*:
Alfredo Gustavo y Liliana,
Virginia y Hugo,
María Amelia,
Juan Ignacio y Santiago José.

I.S.B.N. 950-14-1716-6 (2ª ed.)

©
EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES
LEXIS-NEXIS ARGENTINA S.A.

Talcahuano 494 (C1013AA1) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 5382-8806 • Fax: (54-11) 5382-8888
e-mail: lexis-nexis@lexis-nexis.com.ar • info@lexis-nexis.com.ar

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Derechos reservados
Impreso en la Argentina Printed in Argentina.

PRÓLOGO

La denominación de Derecho Romano no es unívoca. Por un lado con ella nos podemos referir al derecho propio que tuvieron los romanos. Siendo así tiene la significación de "Derecho Romano de los romanos". Es el que comprende el desenvolvimiento jurídico que va desde los orígenes (siglo VIII a.C.) hasta la concreción de la célebre compilación justiniana (siglo VI d.C.). Pero por el otro lado, el Derecho Romano no se acabó luego de la redacción del denominado Corpus Iuris Civilis. Al contrario, sus instituciones, y lo que es más importante, sus principios y la configuración de la forma mentis romana continuó vigente tanto en Oriente como en Occidente. Adaptado a las circunstancias, luego de su renacimiento en la Edad Media, alcanzó a convertirse en el "Derecho Común europeo". Es decir, constituyó el Derecho civil por excelencia que se aplicó en Occidente, alcanzando a ser la ratio scripta en materia jurídica. Incluso, en los países germánicos, debido al fenómeno de la "Recepción", ocurrida en el siglo XVI, pasó a ser en dicha área alemana el derecho positivo que se aplicaba por los jueces y tribunales, lo cual continuó hasta la aparición del Código Civil alemán del año 1900. Pero también en los otros países occidentales, o quedó trasvasado en los distintos códigos civiles de Europa y América, o quedó constituyendo una fuente perenne que de algún modo alimenta las instituciones jurídicas.

Esta multiplicidad de sentidos que tiene el Derecho Romano es el que crea una problemática muy especial. En efecto, aun cuando las fuentes escritas son las mismas, por lo que podemos hablar de una cierta unidad, con el decurso del tiempo se fue produciendo una diversidad de aplicaciones. Brevemente dicho, estas fuentes consisten en los textos ya fijados de la compilación justiniana, además de una buena cantidad de obras procedentes de autores romanos clásicos y posclásicos. Los juristas siguieron apoyándose en las mismas, pero al beber de ellas, apreciaron una pluralidad de gustos en el sabor de lo que manaba de los textos justinianos.

Así, cuando asistimos al renacimiento de los estudios romanísticos, nos encontramos con una primera lectura efectuada por los llamados Glosadores (siglo XII). Con posterioridad surgieron los Comentaristas, que de algún modo, aun leyendo las mismas fuentes, nos denotan una lectura distinta de los viejos textos. Y lo mismo ocurrirá con los Humanistas franceses (siglo XVI), los Juristas holandeses y germanos, así como también con los juristas de la llamada Escuela Histórica y posteriormente con la Pandectística alemana.

En el fondo, pues, existe un problema hermenéutico, es decir, de interpretación. Frente a una

configuración cerrada y unitaria de las fuentes, sin embargo, los textos pueden ser interpretados de manera diversa. Esta circunstancia, para quien sabe algo de Derecho, es coetánea a la Ciencia Jurídica, que no es en el fondo sino un problema de interpretación. En la misma Roma, el jurista es propiamente un intérprete que se adentra en el caso concreto que se le presentaba buscando interpretar la realidad. Incluso en el Digesto estaban propuestas (I-3 y 50-16) toda una colección de reglas interpretativas. Además, era saber interpretar los textos que han querido develar las "soluciones justas" que se encontraban en la realidad de cada uno de los casos.

Esta posibilidad de distintas apreciaciones obedecía sobre todo a dos causas principales. Por un lado está la realidad misma del intérprete que se aboca a estas cuestiones. Lo quiera o no, él mismo está cargado de una concepción particular del mundo y de las cosas. Para decirlo con la sonora palabra alemana, bien modernista, de su propia Weltanschauung. Y además, el jurista trata siempre de lograr la aplicación concreta de los textos para adecuarlos a la realidad socio-económica de su época. Es por ello que nos explicamos que, por ej., las sapientes conclusiones de un Friedrich Carl von Savigny resultan de algún modo distintas de aquellas a que llegó el célebre Bartolo de Sassoferrato. Y sin embargo, ambos se refieren a los sempiternos textos que nos ha dejado el genio jurídico latino.

Siendo así las cosas, la elaboración de una obra de Derecho Romano no resulta fácil. En el fondo, su supervivencia depende de las distintas generaciones, a las cuales les cabe un deber de volver a reinterpretar dichos textos para apreciar su riqueza. Cumplimentando este deber generacional es que hemos emprendido la tarea de escribir este tratado de Derecho Privado Romano. Por ello hemos optado por la explicación del "Derecho Romano de los romanos". Lo que nos hemos propuesto es un "regreso a las fuentes", tratando de ver avec des yeux neufs, lo que fue realmente el Derecho Romano. Verlo "con ojos nuevos" significa acá hacer el esfuerzo intelectual de interpretar sus instituciones y sus principios tal cual lo vivenciaron los propios juristas romanos, tratando de buscar su esencia prístina. No olvidamos las interpretaciones y las observaciones muchas veces profundas y atinadas de tantos romanistas de fuste. Pero fundamentalmente hemos querido volver a los textos mismos establecidos por los propios romanos. Una vez estudiada la experiencia genuina de los romanos, podremos tener una visión más clara que nos ilumine en los problemas que se presentan en el momento jurídico actual.

Debido a este carácter que le asignamos a la investigación, no nos ha preocupado el aspecto erudito de la cita bibliográfica. Por eso la obra carece de notas al pie, y solamente cuando ha resultado imprescindible hemos recurrido al nombre de un romanista. El punto central pasa por la cita directa de las fuentes. La experiencia nos ha demostrado que muchas veces la ciencia romanística, sobre todo la expresada en los manuales, realiza en forma atrevida afirmaciones que no encuentran el respaldo fontal. Hay que desconfiar de cualquier aseveración que no se apoye en una fuente romana directa.

En tal sentido, en esta tarea de depuración de las instituciones romanas, hay algunos aspectos que considero importantes. Así, en primer lugar, nuestros manuales continúan por lo general —de manera consciente o sin saberlo— la línea interpretativa de la Pandectística alemana. Esta es tributaria de los principios iluministas de la Modernidad. De allí el empleo frecuente de vocablos centrales como el de "sujeto de derecho", "derechos subjetivos", y sobre todo el repertorio especializado correspondiente al amplísimo voluntarismo, propio de la ciencia jurídica decimonónica. Hoy día uno de los temas más debatidos es el de establecer si los Tiempos Modernos continúan todavía vigentes, o como lo dicen los llamados "posmodernistas", la Modernidad, con todos sus dogmas, entre los cuales encontramos el Willensdogma (dogma de la voluntad), y el progreso indefinido de las ideas y de la Humanidad, ya ha concluido. No entraré en estas consideraciones, pero hay algo que resulta irremediablemente innegable: los romanos no eran "modernistas", de tal modo que aplicar las ideas de la Aufklärung (Iluminismo) a las instituciones romanas es señalarlas de un pensamiento posterior a la lettre. Nuestro esfuerzo consiste en eliminar a las instituciones y principios romanos de ideologías extrañas a su espíritu. Simplemente nos ocupamos de recrear el Derecho Romano tal como lo vivieron los propios romanos. Y ello sólo se puede lograr tratando de interpretar las fuentes jurídicas que ellos mismos nos han dejado, buscando ser fieles a los distintos textos.

El segundo riesgo que hemos querido evitar, muy usual en nuestro país, es el de interpretar el Derecho Privado Romano por medio del Código Civil vigente en cada comunidad. Por esta vía, los estudios romanísticos se han convertido en una especie de "Introducción general del Derecho Civil", tratando de demostrar a los alumnos cómo el texto codificado incorpora muchas de las soluciones romanas. Todo esto es muy cierto, y lejos estoy de negarlo. Pero si le queremos asignar a nuestra materia su carácter fontal, el camino a seguir es precisamente el inverso. Se trata de adentrarse en el Derecho Romano tal cual fue, ir siguiendo sus evoluciones en cada una de las instituciones, tratando de descubrir los cambios que se fueron operando en la propia Roma, y con posterioridad, como muchas veces en el mundo jurídico occidental se continuó con las soluciones romanas, y otras muchas se apartó de ellas. Estamos seguros de que

de este modo, no solamente entenderemos mejor el *ius* de los habitantes del Lacio y de Bizancio, sino también entenderemos nuestro estado actual de cosas en el ámbito jurídico.

El tercer aspecto que nos ha preocupado es el de establecer lo más prudente que resultó factible la evolución interna que tuvieron las propias instituciones romanas a lo largo de muchos siglos. Nuestros hermanos, civilistas actuales, cuando se refieren al Derecho Romano —aclaro que con mucho respeto— lo suelen ver y citar como un todo único, sin advertir que las soluciones romanas dependen de cada una de las épocas en que se desarrolló su *ius*. Ello obedece al hecho de ver en el Corpus Iuris un estadio permanente, sin advertir la riqueza de matices que es dable apreciar entre las soluciones clásicas, las posclásicas, las bizantinas y los propios de los compiladores justinianos.

Por ello, en el tratamiento de las diversas instituciones hemos seguido el criterio de apoyarnos fundamentalmente en el denominado Derecho Romano Clásico. Ello nos permite, por un lado, descubrir la inmensa tarea de superación que los juristas romanos realizaron respecto del denominado Derecho antiguo, y también conocer con más profundidad cómo esa tarea fue luego rectificada —a veces bien, otras no tan bien— en el Derecho posclásico y en el bizantino-justiniano.

Hemos tratado de destacar lo fundamental con un tipo de letra más grande, procediendo luego a ampliar los detalles con un tipo de letra más chica. La exposición se abre con un capítulo primero tendiente a dar una información somera de la historia de la constitución política romana, diferenciada en el capítulo segundo del desarrollo histórico del *ius*. Nuestro propósito de realizar la deconstrucción del trasfondo modernista resulta bien evidente en todas las instituciones tratadas. Pese a ello, aunque sin abandonar el espíritu de la tarea que nos hemos propuesto, a veces hemos tenido que hacer alguna concesión, como al tratar en forma genérica y sistematizada el negocio jurídico, tarea a la cual no se abocaron los juristas romanos. Ello se debe a que hemos tratado de evitar al estudiante de las instituciones de Roma una mayor complicación en el acercamiento a nuestra materia.

No queremos acá dejar de expresar nuestro muy particular reconocimiento al doctor César E. Mele, quien se encargó de la supervisión de las pruebas de imprenta, principalmente en cuanto a los vocablos y expresiones latinas. Esta tarea la desarrolló con gran altura lingüística y con el cariño y amor que resultan propias de quienes aman lo "clásico".

Muchas veces se suele hablar del "legado jurídico de Roma". A fuer de ser sinceros, no obstante lo elogioso que ello puede resultar en una primera lectura, no aceptamos la idea de legado, puesto que supone la muerte del *de cuius*. Y para nosotros, Roma, si bien es "causa", y de allí lo de causante, todavía no ha muerto. Goza de muy buena salud.

La Plata, Día de la Natividad del Señor, 1995.

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO	IX
ABREVIATURAS USADAS	XXI
CUADRO HISTÓRICO. TABLAS CRONOLÓGICAS	XXIII
ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS	417

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1. Historia de las instituciones políticas romanas	3
---	---

§ 1. División de la historia política romana. I. La Monarquía. § 2. Origen. § 3. Composición política: (a) Rex; (b) Senado; (c) Comicios curiados; (d) Colegios sacerdotales. § 4. Composición social: (a) patricios; (b) clientes; (c) plebeyos; (d) esclavos. § 5. Reformas de Servio Tulio. § 6. Efectos de las reformas de Servio Tulio.

II. La República. § 7. Aparición de la res publica. § 8. Integración patricio-plebeya. § 9. Composición política: (A) § 10. Los magistrados. § 11. Caracteres generales. § 12. El *cursus honorum*. § 13. Magistraturas extraordinarias. § 14. Los tribunos de la plebe. (B) § 15. Los comicios. (C) § 16. El Senado. § 17. Atribuciones del Senado.

III. El Principado. §§ 18-20. Aparición y circunstancias históricas. § 21. Constitución política del Principado. § 22. ¿Principado o diarquía? § 23. Desarrollo histórico de las dinastías.

IV. El Dominado. § 24. Diocleciano. § 25. Constantino. § 26. Teodosio.

Capítulo 2. Historia del Derecho Romano	17
---	----

§ 27. Concepto de Derecho Romano. § 28. Etapas en la historia del Derecho Romano. I. Derecho Romano antiguo (Derecho quiritaro). § 29. Características. § 30. Las denominadas *leges regiae*. § 31. Ley de las XII Tablas. § 32. La *interpretatio*. § 33. Las leyes. 1. Concepto. 2. Procedimiento. § 34. Partes de la *lex*. § 35. Denominación. § 36. Clases de leyes. § 37. Importancia relativa de las *leges* en el *ius privatum*. § 38. Los plebiscitos.

II. Derecho Romano clásico. § 39. Caracterización. § 40. (A) Comienzos del período clásico. § 41. El Edicto de los magistrados. § 42. Clases de edictos. § 43. Importancia del Edicto del Pretor. § 44. Los *responsa prudentium*. § 45. Labor de los jurisprudentes. § 46. Primeros juristas. (B) El Derecho clásico central. § 47. Caracterización. § 48. Los senadoconsultos. § 49. Los *responsa prudentium*. El *ius publice respondendi*. § 50. Los jurisconsultos de esta época. Escuela Proculiana y Escuela Sabiniana. (C) La última etapa de la época clásica. § 51. Características. § 52. *Constitutiones Principum* (Constituciones imperiales). § 53. Los grandes juristas de esta época.

III. El Derecho romano posclásico. § 54. Comienzos. § 55. El Derecho Vulgar. § 56. Las Escuelas de Derecho. § 57-58. La Ley de Citas. § 59. La tarea de la codificación. § 60. Las leyes romano-bárbaras. § 61. La compilación de Justiniano. § 62. Las interpola-

mones. § 63. Medidas legislativas de Justiniano. § 64. El *Corpus Iuris Civilis*: I. El Código. II. El Digesto. III. Las Institutas. IV. Las Novelas.

Evolución posterior del Derecho Romano. § 65. El derecho romano en Oriente después de Justiniano. § 66. Supervivencia del Derecho Romano en Occidente. § 67. Escuela de los Glosadores. § 68. Escuela de los Comentaristas. § 69. La escuela humanista. § 70. La escuela del Derecho Natural. § 71. La escuela histórica. § 72. La Pandectística alemana. § 73. Situación actual. § 74. El Derecho Romano en la Argentina.

Capítulo 3. Conceptos fundamentales del derecho romano 37

§ 75. *Ius* y Derecho. § 76. Etimología de *iur*. § 77. Etimología de Derecho. § 78. Distintas acepciones de la palabra *iur*. §§ 79-80. Diversos empleos del vocablo *iur*. § 81. El *Fus*. § 82. Definiciones básicas: (a) *Iustitia*; (b) *Aequitas*; (c) Principios fundamentales del Derecho; (d) *Iurisprudentia*.

Clasificaciones del *iur*: §§ 83-84. *Ius publicum* - *Ius privatum*. § 85. *Ius commune*, *iur singulare*, *beneficium*, *privilegium*. §§ 86-88. *Ius civile* - *iur gentium* - *iur naturale*. § 89. *Iur praetorium* o *iur honorarium*.

PARTE PRIMERA

EL PROCEDIMIENTO ROMANO

Capítulo 1. La *actio* 47

§ 90. Generalidades. § 91. I. *Actio*. II. Clasificación de las *actiones*: § 92. *Actiones in rem* - *actiones in personam*. § 93. *Actiones reipersecutorias*, penales y mixtas. § 94. *Actiones perpetuae* y *actiones temporales*.

Capítulo 2. Evolución histórica del procedimiento judicial romano 51

Parte primera: I. El procedimiento judicial antiguo. Las *Legis actiones*. § 95. Generalidades. § 96. Características generales. § 97. Enumeración. § 98. Iniciación del procedimiento. § 99. I. *Sacramentum*: (A) *Sacramentum in rem*. § 100. Monto del *sacramentum*. § 101. Posesión interina de la cosa. § 102. *Sacramentum in personam*. § 103. II. *Iudicis (vel arbitrius) postulatio*. § 104. III. *Condictio*. § 105. Las vías ejecutivas: I. *Manus iniectio*. § 106. Casos especiales. § 107. II. *Pignoris capio*.

Parte segunda: II. El procedimiento formulario.

§ 108. Decadencia de las *legis actiones*. §§ 109-110. Origen del procedimiento formulario.

Marcha del procedimiento. I. *Etapa in iure*. § 111. (A) Iniciación del procedimiento. § 112. (B) Partes del procedimiento. § 113. Actuación por un *cognitor*. § 114. Actuación por un *procurator*. § 115. (C) Actuación ante el magistrado. § 116. Análisis del juicio por el magistrado. § 117. Posiciones que puede asumir el demandado. § 118. (D) Decreto de *iudicium dare*. Nombramiento del *iudex*. Libramiento de la fórmula. § 119. Clases de jueces. § 120. (E) *Litis contestatio*. II. Procedimiento *apud iudicem*. § 121. La tarea del *iudex*. § 122. La sentencia. § 123. Efectos de la sentencia.

Análisis de la fórmula. § 124. Características. § 125. Partes ordinarias de la fórmula: *demonstratio*, *intentio*, *condemnatio*. § 126. *Adiudicatio*. § 127. Particularidades de la *intentio*. *Pluris petitio* y *minus petitio*. § 128. Particularidades de la *condemnatio*. § 129. *Litis aestimatio*. § 130. Partes extraordinarias de la fórmula: (A) § 131. *Praescriptio*. (B) § 132. *Exceptio*. § 133. Clasificación de las *exceptiones*.

Clasificación de las fórmulas. § 134. I. Fórmulas *in ius conceptae*. § 135. II. Fórmulas

in factum conceptae. § 136. III. Fórmulas *factitiae*. § 137. IV. *Bonae fidei iudicia*. § 138. Otras fórmulas pretorianas: (A) Fórmula arbitraria; (B) Fórmulas con trasposición de personas.

Otros medios pretorianos especiales. I. *Interdictum*. § 139. Concepto. § 140. Clases. § 141. Procedimientos. II. § 142. *In integrum restitutio*. III. § 143. *Missio in possessionem (in bona)*. IV. § 144. *Stipulationes praetoriae*.

Ejecución de la sentencia en el proceso formulario. § 145. *Actio iudicati*. § 146. La *venditio bonorum*. § 147. Trámite de la *venditio bonorum*. § 148. *Cessio bonorum*. § 149. *Distractio bonorum*.

Parte tercera: Procedimiento extra ordinem (la *cognitio*).

§ 150. Generalidades. § 151. Características. § 152. Marcha del procedimiento: Comparecencia de las partes. § 153. Actuación ante el juez. § 154. Las pruebas. § 155. La sentencia. § 156. La apelación. § 157. El procedimiento arbitral. § 158. Las vías de ejecución. § 159. Apreciación de la *cognitio*.

PARTE SEGUNDA

DERECHO DE LAS PERSONAS

Capítulo 1: Las personas 79

§ 159 bis. Hombre y persona. I. Comienzo y fin de la persona. § 160. Comienzo de la persona: el concebido (*nasciturus*). § 161. II. Requisitos para considerar nacida la persona. § 162. III. Extinción de la persona. § 163. IV. *Status* y *capitis deminutio*.

Status libertatis. § 164. Clasificación. § 165. Los esclavos. § 166. I. Condición jurídica del esclavo. § 167. Capacidad jurídica. § 168. II. Causas de esclavitud. § 169. Causa de esclavitud del *iur gentium*. § 170. *Postliminium (ius postliminii)*. § 171. *Fictio legis Corneliae*. § 172. Causas de esclavitud del *iur civile*. § 173. III. Fin de la esclavitud. § 174. Manumisión. § 175. Formas no solemnes de manumisión. § 176. Leyes restrictivas de las manumisiones. § 177. Los libertos: clases. § 178. El patronato. Deberes del liberto. § 179. Deberes del patrono. § 180. Situaciones similares a la esclavitud.

Status civitatis. § 181. Clasificación. § 182. (A) Los ciudadanos romanos. § 183. Adquisición y pérdida de la ciudadanía romana. § 184. (B) Los latinos. § 185. Los peregrinos. *Status familiae*. § 186. Generalidades (remisión).

Causas modificativas del *status*. § 187. Causas: (A) Edad; (B) Sexo; (C) Enfermedad mental; (D) Infamia.

Personas jurídicas (corporaciones y fundaciones). § 188. El problema de las "personas jurídicas" en Roma. § 189. *Populus*. § 190. *Fisco*. § 191. *Municipia* - *Civitates*. § 192. *Collegia*. § 193. Fundaciones.

PARTE TERCERA

DERECHO DE LAS COSAS

Capítulo 1. Las cosas 103

§ 194. Concepto de cosa. § 195. *Res corporales et incorporales*. § 196. Patrimonio. § 197. Clasificación general de las cosas. § 198. I. *Res extra commercium*. 199. *Res divini iuris*. § 200. *Res communes*. *Res publicae*. *Res universitatis*. § 201. II. *Res in commercio*. *Res mancipi* et *non mancipi*. Otras clasificaciones de las *res in commercio*. § 202. Cosas inmuebles y muebles. § 203. Cosas simples y compuestas. § 204. Cosas fungibles y no

fungibles. § 205. Cosas consumibles y no consumibles. § 206. Cosas divisibles e indivisibles. § 207. Partes, accesorios, pertenencias y frutos.

Capítulo 2. La posesión. 111

§ 208. Conceptos generales. § 209. Efectos de la posesión. § 210. Adquisición de la posesión § 211. Conservación de la posesión. § 212. Pérdida de la posesión. § 213. Clases de posesión.

Protección de la posesión. § 214. Interdictos. § 215. Clases de interdictos posesorios. § 216. I. Interdictos *retinendae possessionis causa*; § 217. *Uti possidetis*. § 218. *Utrubi*. § 219. II. Interdictos *recuperandae possessionis causa*. § 220. Los interdictos en la época posclásica y justiniana.

§ 221. Cuasi-posesión (*quasi possessio*).

Capítulo 3. La propiedad 119

§ 222. Noción de la propiedad. § 223. El dominio en Roma. § 224. I. Caracteres y contenido del dominio (absoluto); § 225. (exclusivo); § 226. (perpetuo). II. Clases de dominio: § 227. *Dominium ex iure Quiritium*. § 228. *In bonis habere*. § 229. Propiedad provincial. § 230. Propiedad peregrina. § 231. La propiedad en el derecho posclásico. § 232. III. Limitaciones del dominio: § 233. (A) Limitaciones por interés público. § 234. (B) Restricciones por relaciones de vecindad.

§ 235. IV. Adquisición de la propiedad: modos. (A) Modos *inter vivos* derivativos; § 236. I. *Mancipatio*. § 237. II. *In iure cessio*. § 238. III. *Traditio*. § 239. (B) Adquisición de la propiedad por la *usucapio*. § 240. Requisitos para *usucapir*. § 241. La *longi temporis praescriptio*. § 242. (C) Modos de adquisición originaria de la propiedad: I. Ocupación. § 243. II. *Accessión*. § 244. *Accessión* de un inmueble a otro inmueble. § 245. *Accessión* de un mueble a un inmueble. § 246. *Accessión* de un mueble a otro mueble. § 247. III. Especificación. § 248. IV. *Confusión* y *comixión*.

§ 249. V. Protección de la propiedad. § 250. I. *Rei vindicatio*. § 251. Contra quién se ejerce. § 252. Desarrollo del juicio. § 253. Prueba de la propiedad. § 254. Efectos de la sentencia. § 255. II. *Actio Publiciana in rem*. § 256. III. Interdicto *quem fundum* y *actio ad exhibendum*. § 257. *Actio negatoria*. § 258. Publicidad de la propiedad.

§ 259. VI. El condominio. § 260. Reglas que rigen el condominio. § 261. Acciones de partición.

Capítulo 4: *Iura in re aliena*. 143

§ 262. Generalidades. § 263. I. Las servidumbres. § 264. Servidumbres prediales. § 265. Clasificación. § 266. Constitución de las servidumbres. § 267. Extinción de las servidumbres. § 268. Protección de las servidumbres.

II. El usufructo. § 269. Generalidades. § 270. Cosas susceptibles de usufructo. El *quasi usufructus*. § 271. Ejercicio del usufructo. § 272. Constitución del usufructo. § 273. Duración del usufructo. § 274. Extinción del usufructo. § 275. Protección del usufructo. III. El uso, la habitación y las *operae servorum*. § 276. Uso. § 277. Habitación. § 278. Las *operae servorum*.

IV. La superficie y la enfiteusis. § 279. Generalidades. § 280. Superficie. § 281. Situación y protección del superficiario. § 282. La superficie en el derecho posclásico. § 283. Enfiteusis. § 284. Características jurídicas.

V. Garantías reales: prenda e hipoteca. § 285. Generalidades. § 286. I. Fidencia. § 287. II. *Pignus*. § 288. (A) La prenda. § 289. Características de la prenda. § 290. Efectos de la prenda. § 291. (B) La hipoteca. § 292. Características. § 293. Hipotecas tácitas y legales. § 294. Otros casos especiales de *pignus*. § 295. Derechos del acreedor hipotecario. § 296. Extinción del *pignus*.

PARTE CUARTA

LAS OBLIGACIONES Y LOS NEGOCIOS

Capítulo 1: El negocio jurídico. 165

§ 297. Generalidades. § 298. Hechos, actos y negocios jurídicos. § 299. Clasificaciones de los actos y negocios jurídicos.

I. Elementos de los actos y negocios jurídicos. § 300. Clasificación.

II. La expresión de la voluntad. § 301. Formas.

III. Interpretación de la voluntad. § 302. El problema en el Derecho Romano.

IV. Vicios de la voluntad. § 303. Vicios conscientes. § 304. Vicios inconscientes: (A) Error. § 305. (B) Dolo. § 306. (C) Violencia.

V. Modalidades del negocio jurídico. § 307. (A) Condición. § 308. Clasificación de las condiciones. § 309. Efectos de la condición. § 310. (B) Plazo o término. § 311. Clases de plazos. § 312. Efectos del término o plazo. § 313. (C) Modo.

VI. Representación en los negocios jurídicos. § 314. La representación en el Derecho Romano.

VII. Ineficacia de los negocios jurídicos. § 315. Distintos casos.

Capítulo 2: Las obligaciones 181

§ 316. Generalidades. § 317. I. Concepto de obligación. § 318. Elementos de la obligación.

II. Clases de obligaciones. § 319. *Obligatio* y *actio*. § 320. Obligaciones civiles y honorarias. § 321. Obligaciones naturales. § 322. Clases de obligaciones por la prestación: (A) Obligaciones específicas y genéricas. (B) Obligaciones divisibles e indivisibles. (C) Obligaciones alternativas y facultativas. § 323. Clases de obligaciones por las personas intervinientes: (A) Obligaciones mancomunadas. (B) Obligaciones solidarias. (C) Obligaciones cumulativas. (D) Obligaciones ambulatorias.

§ 324. III. Fuentes de las obligaciones. § 325. Contrato. § 326. Pactos. § 327. *Quasi ex contractu*. § 328. Delitos y *quasi ex delicto*.

Capítulo 3: Los delitos 193

§ 329. Noción de delito. § 330. La intención maliciosa. § 331. Acciones penales.

I. *Furtum*. § 332. Características. § 333. Formas de cometer el *furtum*. § 334. Sobre qué puede recaer un *furtum*. § 335. *Animus furandi*. § 336. *Animus lucri faciendi*. § 337. Clases de *furtum*: *Furtum manifestum* y *nec manifestum*. § 338. Penas. § 339. Otros casos de acciones por el *furtum*: *actio furti concepti*, *actio furti oblati*, *actio prohibiti furti*, *actio non exhibiti furti*. §§ 340-341. Ejercicio de la *actio furti*. § 342. Acciones para recuperar la cosa hurtada. § 343. Casos de hurtos como *crimina*.

II. *Rapina*. § 344. Aparición y desarrollo. § 345. *Actio vi bonorum raptorum*. § 346. Otras acciones vinculadas a la violencia.

III. *Damnum iniuria datum*. § 347. El delito de "daño causado injustamente". § 348. Casos previstos por la *lex Aquilia*. § 349. La *iniuria* del daño. § 350. Acciones en favor de quien sufrió el daño: I. *Actio Legis Aquiliae*. II. *Actiones in factum* y *actiones utiles*.

IV. Injurias. § 351. Características de las injurias. § 352. Contra quién pueden producirse. § 353. El dolo en las injurias. § 354. Penas. § 355. *Lex Cornelia de iniuriis*.

V. Actos ilícitos sancionados por el pretor. § 356. Distintos casos. § 357. Los *quasi ex delictis*.

Capítulo 4: Obligaciones que se contraen por la cosa (Los préstamos; contratos reales).....

§ 358. Características. Contratos reales:

I. El mutuo. § 359. Concepto. § 360. Formas de constitución del mutuo. § 361. Acciones. § 362. Intereses. § 363. *Senatusconsultum Macedonianum*.

II. El comodato. § 364. Concepto. § 365. Obligaciones del comodatario. § 366. *Actio commodati*.

III. El depósito. § 367. Concepto. § 368. Contenido del contrato de depósito. § 369. Clases especiales de depósito. § 370. *Actio depositi*.

IV. Pignus (prenda). § 371. Terminología. Concepto. § 372. Derechos y obligaciones del acreedor prendario.

Otras daciones crediticias. § 373. I. *Dationes ob rem*. § 374. Los llamados "contratos reales innominados" § 375. Principales casos: (A) *Permuta*; (B) *Aestimatum*; (C) *Precario*. § 376. II. *Dationes ob causam*. § 377. III. *Dationes "ex eventu"*.

Préstamos pretorios. § 378. Características. § 379. I. *Constitutum*. § 380. II. *Receptum argentarii*.

Capítulo 5: Obligaciones que se contraen *verbis* (Estipulaciones, Contratos verbales). 219

§ 381. Concepto. § 382. Requisitos de la celebración de la *stipulatio* clásica. § 383. Evolución posterior. § 384. Acciones. § 385. Carácter abstracto de la *stipulatio*. § 386. La *exceptio non numeratae pecuniae*.

I. Modalidades de la *stipulatio*. § 387. Distintos casos: (a) Condición; (b) Plazo; (c) Lugar; (d) Alternativa; (e) *Accessio*.

II. *Stipulationes nulas*. § 388. Distintos casos. I. *Stipulatio post mortem*. II. *Stipulatio* en favor de un tercero. III. Caso de la *promissio* a cargo de un tercero.

III. Pluralidad de *stipulatores* o de *promissores*. § 389. Casos de obligaciones simplemente mancomunadas y solidarias. § 390. La *litis contestatio* en las obligaciones solidarias. § 391. El problema del reembolso.

IV. *Stipulationes accesorias*: § 392. I. Estipulación penal. § 393. II. La *adstipulatio*. § 394. III. *Stipulationes accesorias a la promissio: sponsio y fideipromissio*. § 395. Efectos jurídicos. § 396. Leyes especiales. § 397. *Fideiussio*. § 398. Efectos de la *fideiussio*. § 399. Relación entre el acreedor y los obligados. § 400. Relación entre el deudor y los *fideiusores*. § 401. La *fideiussio* en la época de Justiniano.

V. La *intercessio*. § 402. Las mujeres y la *intercessio*.

VI. Promesas de pago unilaterales: § 403. La *dictio dotis*. § 404. El *iusiurandum liberti*.

Capítulo 6: Obligaciones literales (Contratos literales).....

§ 405. Las obligaciones nacidas en forma escrita. los *nomina transcripticia*. § 406. Clases de *nomina transcripticia*. § 407. *Chirographa y syngraphae*. § 408. La *obligatio litteris* en Justiniano. § 409. Consideraciones sobre las obligaciones literales.

207

235

Capítulo 7: Contratos consensuales.....

239

§§ 410-411. Características generales. § 412. Importancia de los contratos consensuales.

I. *Compraventa*. § 413. Evolución de la *compraventa romana*. § 414. Concepto de *compraventa*. § 415. Acciones. I. Elementos esenciales de la *compraventa*. § 416. (A) Consentimiento. § 417. Las arras. § 418. (B) El precio. § 419. (C) Cosas que pueden ser compradas y vendidas. II. Riesgos de la cosa y garantías. § 420. Riesgos de la cosa. § 421. Garantía por vicios jurídicos: la "evicción". § 422. Garantía por vicios ocultos de la cosa. III. Pactos agregados. § 423. Distintos pactos: (a) *lex commissoria*; (b) *In diem addictio*; (c) *Pactum displicentiae*; (d) *Pactum de retroemendo (de retrovendendo)*.

II. *Locación*. § 424. Concepto. § 425. Unidad del contrato: variedades. I. *Locación de cosas*. § 426. Obligaciones del locador (arrendador). § 427. Obligaciones del locatario (arrendatario). § 428. Situación del locatario. § 429. La *locación de cosas en la época de Justiniano*. II. *Locación de obra*. § 430. Concepto. § 431. Formas especiales vinculadas a la *locatio-conductio-operis*: (A) Régimen de la *lex Rhodia de iactu*. (B) Caso de la *mezcla (aversio)*. III. *Locación de servicios*. § 432. Características.

III. *Sociedad*. § 433. Concepto y evolución de las clases de sociedad. § 434. Características de la sociedad. § 435. Distribución de las ganancias y de las pérdidas. § 436. Disolución de la sociedad. § 437. *Actio pro socio*.

IV. *Mandato*. § 438. Concepto. § 439. Representación indirecta en el mandato. § 440. Caracteres. § 441. Contenido del mandato. § 442. Obligaciones y acciones nacidas del mandato. § 443. Excesos en el cumplimiento del mandato. § 444. Cesación del mandato. § 445. *Mandato de prestar dinero (mandatum pecuniae credendae)*. § 446. Gestión de negocio sin mandato (*negotiorum gestio*). § 447. Requisitos. § 448. Acciones. § 449. La gestión de negocios en la época justiniana.

Capítulo 8: Las donaciones.....

263

§ 450. Concepto. I. Donaciones entre vivos. § 451. Derecho clásico. § 452. Limitaciones a las donaciones: *lex Cincia*. § 453. Reformas posteriores. § 454. Revocación de las donaciones. II. Figuras especiales de donación. § 455. I. Donación sujeta a una carga (*donatio sub modo*). § 456. II. Donaciones *mortis causa*. § 457. III. Donaciones nupciales (*remisión*). § 458. IV. Otras liberalidades: (a) la *pollicitatio*; (b) el *votum*.

Capítulo 9: Efectos y extinción de las obligaciones.....

269

§ 459. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. I. La responsabilidad del deudor. § 460. (A) Responsabilidad del incumplimiento del deudor según la naturaleza de la obligación y de la *actio*. § 461. (B) Responsabilidad por infracciones negociales por actos del deudor. § 462. Dolo, culpa y caso fortuito.

II. La responsabilidad por retraso (la mora). § 463. Concepto. § 464. Efectos de la mora. § 465. Mora del acreedor.

III. Revocación de los actos fraudulentos del deudor. § 466. Concepto de fraude. Medidas del pretor § 467. *Actio Pauliana*. § 468. Efectos.

IV. Extinción de las obligaciones. § 469. Concepto y clases. I. El pago. § 470. Concepto. § 471. ¿Qué es lo que se debe pagar? § 472. ¿Quién puede hacer el pago? § 473. ¿A quién se debe pagar? § 474. ¿Dónde se debe pagar? § 475. ¿Cuándo se debe pagar? § 476. Prueba del pago. § 477. Casos especiales de pago: (A) *Solutio per aes et libram*; (B) *Acceptilatio*. II. Novación: §§ 478-479. Concepto. § 480. Requisitos para que haya novación. § 481. *Novatio necessaria*. III. Compensación. § 482. Concepto. § 483. Evolución. § 484. Reforma de Marco Aurelio. § 485. Reformas de Justiniano. IV. Otras formas de extinción: § 486. Remisión de la deuda. § 487. Transacción. § 488. Consentimiento contrario. § 489. Confusión. § 490. Concurso de causas. § 491. Otras causas de extinción: (a) pérdida de la cosa debida; (b) Muerte y *capitis deminutio*; (c) *praescriptio*.

Z

V. Transmisión de créditos y asunción de deudas. I. Transmisión de créditos. § 492. Generalidades. § 493. (a) La delegatio. § 494. (b) La *procuratio in rem suam*. § 495. (c) Concesión de *actiones utiles*. § 496. La transmisión en el derecho posclásico y justiniano. § 497. II. Asunción de deudas.

PARTE QUINTA

DERECHO DE FAMILIA

Capítulo 1: La familia romana 293

§ 498. Concepto de familia. § 499. Parentesco.

Parte primera: Las potestades del *paterfamilias*. § 500. Generalidades. I. *Patria potestas*. § 501. Concepto. § 502. Ejercicio de la *patria potestas*. § 503. Modos por los cuales puede nacer la *patria potestas*. § 504. (I) Concepción en *iustae nuptiae*. § 505. (II) Adopción. § 508. (A) *Adrogatio*. § 507. Adopción hereditaria. § 508. (B) *Adoptio (stricto sensu)*. § 509. (III) Legitimación. § 510. Extinción de la *patria potestas*. § 511. Emancipación.

II. *Manus*. § 512. Concepto. § 513. Formas de adquirir la *manus*. § 514. Matrimonio *sine manu*. III. *Domínica potestas* y *mancipium*. § 515. (Remisión).

Parte segunda: Las relaciones patrimoniales entre el *pater* y los *alieni iuris*. § 516. Principios generales. § 517. Los peculios: (A) *profecticio*; (B) *castrense*; (C) *quasi castrense*; (D) los *bona materna*. § 518. Las *actiones adiecticiae qualitatis*. § 519. (A) *Actio quod iussu*. § 520. (B) *Actio exercitoria*. § 521. (C) *Actio institoria*. § 522. (D) *Actio de peculio et de in rem verso*. § 523. (E) *Actio tributaria*. § 524. Ejercicio excluyente de estas acciones.

Capítulo 2: El matrimonio 311

§ 525. Características generales del matrimonio romano. § 526. I. Definición. § 527. El carácter monogámico. § 528. II. Esponsales. § 529. III. Requisitos para contraer matrimonio. § 530. IV. Celebración del matrimonio. § 531. V. Impedimentos. § 532. Leyes dictadas por Octavio Augusto. § 533. Los impedimentos en el derecho posclásico.

Efectos del matrimonio: I. Efectos personales. § 534. (A) Efectos entre los cónyuges; (B) Efectos en cuanto a los hijos. II. Efectos en cuanto a los bienes. § 535. Generalidades. § 536. (A) Matrimonio *cum manu*. § 537. (B) Matrimonio *sine manu*. § 538. (C) La dote. § 539. Constitución de la dote. § 540. La dote durante el matrimonio. § 541. La dote después de la disolución del matrimonio. § 542. (D) Donaciones matrimoniales: Donaciones entre cónyuges. § 543. Donaciones *ante nuptias (propter nuptias)*.

Disolución del matrimonio. § 544. I. Por muerte de uno de los cónyuges. § 545. II. Por la cautividad en poder del enemigo. § 546. III. Por destierro. § 547. IV. Por impedimento sobreviniente. § 548. V. Divorcio.

Otras uniones licitas. § 549. I. Concubinato. § 550. II. Matrimonio *sine manu*. § 551. III. *Contubernium*.

Capítulo 3: Tutela y curatela 331

§ 552. Generalidades. Tutela. § 553. Concepto. I. Tutela de los impúberes. § 554. Carácter de esta tutela. Clases de dación de la tutela. § 555. I. Tutela testamentaria de los impúberes. § 556. Nombramiento del tutor testamentario. § 557. Comienzo de la tutela testamentaria. § 558. II. Tutela legítima de los impúberes. § 559. Casos especiales. § 560. III. Tutela constituida por el pretor. § 561. Excusaciones.

Ejercicio de la tutela: § 562. I. Obligaciones anteriores al ejercicio. § 563. II. Ejercicio de la tutela: (A) *Gestio*; (B) *Auctoritas*. § 564. Características del ejercicio de la tutela. § 565. Restricciones al tutor. § 566. III. Responsabilidad del tutor: (A) *Accusatio suspecti tutoris*; (B) *Actio rationibus distrahendis*; (C) *Actio tutelae*. § 567. Otros medios de protección del pupilo.

Tutela de las mujeres. § 568. Razón de ser de esta tutela. § 569. Dación de la tutela de las mujeres. § 570. Actuación del tutor. § 571. Decadencia de esta tutela.

Las curatelas. § 572. Concepto. § 573. I. Curatela de los *furiosi*. § 574. II. Curatela del pródigo. § 575. III. Curatela de los menores. § 576. IV. Otras curatelas especiales.

PARTE SEXTA

DERECHO HEREDITARIO

Capítulo 1: Nociones fundamentales 342

§ 577. Concepto de sucesión. § 578. Evolución histórica de la *hereditas*. *Hereditas* y *bonorum possessio*. § 579. *Hereditas*. § 580. *Bonorum possessio*.

Capítulo 2: Herencia *ab intestato* 351

§ 581. Apertura de la herencia *ab intestato*. § 582. I. Sucesión intestada de la Ley de las XII Tablas. § 583. (A) *Sui heredes*. § 584. (B) Agnado próximo. § 585. (C) Gentiles. § 586. II. Sucesión de la *bonorum possessio ab intestato*. § 587. *Bonorum possessio edictalis*. § 588. I. Llamamiento *unde liberi*. § 589. Colación de bienes. § 590. Colación de la dote. § 591. La colación en la época posclásica. § 592. II. Llamamiento *unde legitimi*. § 593. III. Llamamiento *unde cognati*. § 594. IV. Llamamiento *unde vir et uxor*. § 595. Efectos de la *bonorum possessio cum re y sine re*. § 596. *Bonorum possessiones decretales*. §§ 597-598. III. Reformas del Derecho Imperial. § 599. I. Senadoconsulto *Tertullianum*. § 600. II. Senadoconsulto *Orphitianum*. § 601. Constituciones imperiales posteriores. § 602. IV. Sistema de las Novelas 118 y 127. § 603. I. Primer orden: Descendientes. § 604. II. Segundo orden: Ascendientes y hermanos bilaterales. § 605. III. Tercer orden: Medios hermanos. § 606. IV. Cuarto llamamiento: Colaterales. § 607. Casos especiales de otros llamamientos.

Apéndice: V. Sucesión de los libertos.

§ 608. I. Herencia del liberto ciudadano romano: (A) Herencia del liberto ciudadano romano según el *ius civile*; (B) Sistema pretoriano; (C) Ley *Papia Poppaea*; (D) La *adsignatio liberti*. § 609. II. Herencia de los libertos latinos iunianos. § 610. III. Herencia de los libertos que se cuentan en el número de los *dediticios*. § 611. Reformas de Justiniano.

§ 612. VI. Sucesión de un ingenuo emancipado.

§ 613. VII. Sucesión de un *filiusfamiliae*.

Capítulo 3: Herencia testamentaria 363

§ 614. Testamento: concepto y caracteres. § 615. I. Formas de hacer testamento: (A) *Testamentum calatis comitis*; (B) *Testamentum in procinctu*. § 616. *Testamentum per aes et libram*. § 617. Testamento pretoriano. § 618. Testamento en la época posclásica. § 619. Testamentos especiales.

§ 620. II. Capacidad para testar y para ser instituido heredero en un testamento: I. *Testamenti factio activa*. II. *Testamenti factio passiva*. III. *Ius capiendi*.

III. Contenido del testamento: § 621. (A) La institución de heredero. § 622. (B) Sustituciones de herederos: (A) Sustitución vulgar; (B) Sustitución pupilar; (C) Sustitución cuasi pupilar.

IV. Invalidez e ineficacia de los testamentos. § 623. (A) Invalidez; (B) Ineficacia. § 624. Revocación del testamento. § 625. Interpretación de la voluntad de revocar un testamento.

§ 626. V. Apertura del testamento. § 627. VI. Los codicilos. § 628. Clases de codicilos.

Capítulo 4: La sucesión legítima contra el testamento.

375

§ 629. Reglas primeras del *ius civile*. § 630. I. Caso de la preterición testamentaria según el *ius civile*. § 631. II. La *bonorum possessio contra tabulas* de los *liberi*. § 632. Efectos. § 633. III. La *querella inofficiosi testamenti*. § 634. Ejercicio de la *querella inofficiosi testamenti*. § 635. IV. La Novela 115 de Justiniano.

Capítulo 5: Adquisición de la herencia.

383

I. Clases de herederos y formas de aceptación. § 636. Clases de herederos. § 637. I. Heredero necesario. § 638. II. Herederos suyos y necesarios. § 639. III. Herederos extraños. § 640. Aceptación de la herencia: la *pro herede gestio* y la *cretio*. § 641. Clases de *cretio*. § 642. Requisitos de la aceptación de la herencia. § 643. La aceptación de la herencia en Justiniano.

II. Situación del heredero después de la aceptación de la herencia. § 644. Principios generales. § 645. I. Acrecentamiento entre coherederos. §§ 646-647. II. Remedios para la responsabilidad por deudas: § 648. I. Beneficio de separación de patrimonios. § 649. II. Beneficio de inventario.

III. Casos de herencia no adquirida: § 650. (A) Herencia yacente. § 651. (B) *Usucapio pro herede*. IV. Trasmisión de la herencia: § 652. La *in iure cessio hereditatis*. V. Protección jurídica del heredero. § 653. Reglas generales. § 654. I. *Hereditatis petitio*. § 655. II. *Interdictum quorum bonorum*. § 656. III. Acción de partición de herencia.

Capítulo 6: Legados y fideicomisos.

397

I. Los legados. § 657. Concepto de legado. § 658. Clases de legados: (A) Legado *per vindicationem*; (B) Legado *per damnationem*; (C) Legado *sinendi modo*; (D) Legado *per praeceptionem*. § 659. Evolución posterior de las formas.

§ 660. Características de los legados por su objeto: I. Legados de cosas corporales determinadas. II. Legados de cosas genéricas. III. Legados de cosas incorporales: (A) Legado de crédito; (B) Legado de liberación; (C) Legado de deuda. IV. Legado de opción. V. Legado de una parte de la herencia. VI. Legado de peculio.

§ 661. Adquisición de los legados. § 662. Acrecentamiento entre colegatarios.

§ 663. Limitaciones al derecho de legar: *lex Furia*, *lex Voconia* y *lex Falcidia*. § 664. I. A quién se aplica la *lex Falcidia*. § 665. II. Cálculo de la *quarta Falcidia*. § 666. III. Casos excluidos de la *lex Falcidia*.

§ 667. Ineficacia de los legados: I. Por la invalidez del testamento que lo contiene. § 668. II. Invalidez por causas intrínsecas al legado. § 669. Regla catoniana. § 670. Legados a título de pena. § 671. Legados *post mortem* del heredero. § 672. Invalidez por incapacidad del legatario. § 673. Invalidez por voluntad del testador: (a) Revocación del legado; (b) Traslación del legado.

II. Los fideicomisos. § 674. Concepto. § 675. Evolución. § 676. Reglas generales de los fideicomisos. § 677. I. Fideicomisos de herencia. § 678. Régimen jurídico: (A) Formas primeras de cumplimiento. § 679. (B) Senadoconsulto *Trebellianum*. § 680. (C) Senadoconsulto *Pegasianum*. § 681. Reformas de Justiniano. § 682. II. Fideicomisos de cosas particulares. § 683. Asimilación de los fideicomisos de cosas singulares con los legados en la época de Justiniano. § 684. III. Fideicomiso de libertad. § 685. IV. Fideicomiso de familia. § 686. V. Fideicomiso de residuo.

ABREVIATURAS USADAS

A.Gell.: Aulo Gellio, *Noches áticas*.
Afric.: Africano.
Bruns: *Fontes iuris romani antiqui*, 7ª ed., 1909.
C.: Código de Justiniano.
CTh.: Código Theodosiano.
Coll.: *Collatio legum Mosaicarum et Romanorum*.
Const.: Constantino.
D.: Digesto de Justiniano.
Diocl.: Diocleciano.
D.R.P.: Derecho Romano Privado (Álvaro d'Ors), Pamplona, 1977.
E.P.: Edicto Perpetuo (Otto Lenel, *Essai de reconst. de l'Édit Perpetuel*, 1901).
Epit.: Epítome de Gayo.

F.V.: *Fragmenta Vaticana*.
Inst.: Institutas de Justiniano.
Iavol. (Javol.): Javoleno.
itp.: interpolado.
Jul.: Juliano (Salvio Juliano).
Just.: Justiniano.
Lenel: Edicto Perpetuo.
Maxim.: Maximiano.
Mod.: Modestino.
Nov.: Novelas de Justiniano.
Pap.: Papiniano.
Pomp.: Pomponio.
Ulp.: Ulpiano.
s.c.: senadoconsulto.
Scev.: Scaevola.

TABLAS CRONOLÓGICAS

I. La Monarquía

Años a.C.	Hechos políticos	Jurisprudencia
753	Fecha tradicional de la Fundación de Roma por Rómulo.	Pontífices
717-650	Reyes latinos: Numa Pompilio; Tullio Hostilio; Anco Marcio.	
650-510	Reyes etruscos: Tarquino el Antiguo; Servio Tullio; Tarquino (578-535) Servio Tullio (Reformas sociales).	
509	Expulsión de Tarquino el Soberbio. Abolición de la monarquía.	

II. La Res publica

494	Secesión de la plebe.	
471	Los <i>concilia plebis</i> eligen los tribunos.	
451-450	Ley de las XII Tablas.	
445	Ley <i>Canuleia</i> (concesión del <i>conubium</i> a los plebeyos).	
367	Leyes <i>Liciniae Sextiae</i> (Creación de la pretura).	
326	Ley <i>Postellia Papiria</i> (abolición virtual del <i>nexum</i>).	
304	Cneo Flavio publica las fórmulas de las <i>legis actiones</i> y el calendario.	
287	Ley <i>Hortensia</i> (los plebiscitos son considerados leyes).	<i>Ius Flavianum</i>
264-241	Primera Guerra púnica.	
252	Tiberio Coruncanio primer Pontífice Máximo plebeyo.	
242	Creación del pretor peregrino.	
204	Ley <i>Cincia</i> (sobre donaciones). Alrededor de esta época la ley <i>Plaetoria</i> (protegiendo a los menores de 25 años).	
217-203	Aníbal en Italia (Lago Trasimeno: 217; Cannas: 216).	
201	Fin de la segunda Guerra Púnica (batalla de Zama).	
198	Sexto Aelio Peto cónsul.	Sexto Aelio Peto: <i>Ius Aelianum</i> . (<i>Triperitia</i>)
150-130?	Ley <i>Aebutia</i> (procedimiento formulario).	
149	Manio Manilio cónsul.	Manio Manilio
133	Publio Mucio Escévola cónsul.	P.M. Escévola
	Tribunado de Tiberio Graco.	
123-122	Tribunado de Cayo Graco.	
95	Quinto Mucio Escévola (<i>pontifex</i>), cónsul.	Q.M. Escévola
82-79	Dictadura de Syla (leyes <i>Corneliae</i>).	
66	Cayo Aquilio Galo, pretor.	Cayo A. Galo
51	Servio Sulpicio Rufo, cónsul.	S. Sulpicio Rufo
49	Guerra civil (48: batalla de Farsalia).	
44	Asesinato de Cicerón.	
40	Ley <i>Falcidia</i> (limitación al derecho de legar).	
39	Alfeno Varo, cónsul	Alfeno Varo
31	Batalla de Accio (triunfo de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra).	

III. El Principado

27 a.C.	Comienzo del gobierno de Octavio Augusto.	Proculeyanos-Sabinianos
18 a.C.	Ley <i>Iulia de adulteriis</i> .	Labeón A. Capito
	Ley <i>Iulia de maritandis ordinibus</i> .	
17 a.C.	Leyes <i>Iuliae iudictariae</i> .	
2	Ley <i>Fufia Caninia</i> .	
años d.C.		
4	Ley <i>Aelia Sentia</i> .	
9	Ley <i>Papia Poppaea</i> .	
14-37	Tiberio.	Nerva (pater) M. Sabino Próculo Cassio
37-41	Calígula.	
41-54	Claudio. SC. <i>Velleianum</i> ; SC. <i>Claudianum</i> .	
54-58	Nerón. SC. <i>Neronianum</i> ; SC. <i>Trebellianum</i> .	
69-79	Vespasiano. SC. <i>Pegasianum</i> ; SC. <i>Macedonianum</i> .	Pegaso Celio Sabino
79-81	Tito.	
81-96	Domiciano.	Celso (pater)
96-98	Nerva.	Javoleno
98-117	Trajano.	Celso (filius)
117-138	Hadriano (Edicto Perpetuo).	Neracio Salvio Juliano
		Pomponio
138-161	Antonino Pío.	Marcelo Africano
		Gayo
161-180	Marco Aurelio.	Q. C. Escévola
178-	SC. <i>Orphitianum</i> .	Papiniano
180-192	Cómodo.	Ulpiano
		Paulo
192-211	Septimio Severo.	Marciano
211-217	Caracalla. (212: <i>Const. Antoniniana</i>).	Modestino
222-235	Alejandro Severo.	
238-244	Gordiano.	

IV. El Dominado

284-305	Diocleciano. La Tetrarquía.
312	Batalla de Puente Milvio. Conversión de Constantino.
313	Edicto de Milán.
323-337	Constantino. Constantinopla nueva capital.
379-395	Theodosio I.
395-423	División del Imperio: Honorio (Occidente) y Arcadio (Oriente).
408-450	Theodosio II (Oriente).
425-455	Valentiniano III (Occidente).
426	Ley de Citas.
438	Código Theodosiano.
476	Caída del Imperio Romano de Occidente.
506	Breviario de Alarico (<i>lex Romana Visigothorum</i>).
527-565	Justiniano.
529	Compilación justiniana: Primer Código.
533	Institutas y Código.
534	Código nuevo.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS ROMANAS

§ 1. Se acostumbra dividir el desenvolvimiento político constitucional de Roma en cuatro períodos:

a) la *Monarquía* (el *regnum*), que va desde el año 754 o 753 a.C. (fecha tradicional de la fundación de Roma) hasta el año 509 a.C. (cuando ocurre la caída del último de los reyes, Tarquino el Soberbio);

b) la *República*, que abarca desde esta fecha hasta el año 27 a.C., cuando se instaura el Principado, por parte de Octavio Augusto;

c) el *Imperio*, que en su primera fase (Alto Imperio) asume el régimen del *Principado*, hasta la llegada al poder de Diocleciano (año 284 d.C.);

d) y que en su segunda fase se consolida autoritariamente en la figura del Emperador como *Dominus*; será el Bajo Imperio o *Dominado*, que en Occidente abarca hasta la caída de Roma a manos de los bárbaros (año 476 d.C.), y que en Oriente, en el sentido estricto con que se estudia el Derecho Romano, abarca hasta la muerte de Justiniano (año 565 d.C.), quien será el gran consolidador del *Ius*, con su famosa compilación, conocida como *Corpus Iuris Civilis*.

I. La Monarquía.

§ 2. Los romanos son desde su origen un pueblo de agricultores (o en general dedicados a la labor agropecuaria), al mismo tiempo que soldados (para Barrow, el romano es un "soldado-agricultor"). En lo social, Roma está compuesta primigeniamente en familias, las cuales están integradas en grupos más amplios: las *gentes* (sing.: *gens*).

Este vocablo lo podemos entender como una familia amplia (= clan), integrada por las distintas familias pertenecientes al mismo linaje. Se caracterizan por llevar todos sus integrantes el mismo nombre común (*nomen gentilicium*). Este se deriva por la descendencia reconocida respecto de un personaje común, que fue el iniciador de la *gens*. Así, los de la *gens Iulia* aceptan como su fundador a *Julius*; los de la *gens Cornelia* a *Cornelius*; etc.

El vínculo de parentesco que los une no es meramente el natural consanguíneo (*cognatio*), sino el parentesco artificial de la *agnatio*, basado en el some-

timiento de todos los miembros de cada familia a la autoridad de un *paterfamilias*, de acuerdo con las distintas generaciones. Este vínculo se transmite por vía masculina (no femenina). Al mismo tiempo, los integrantes de cada familia, y en su medida de cada *gens*, están incorporados al culto familiar (*sacra privata*), en el cual se reverencia a los antepasados comunes, divinizados como "dioses *Maves*".

§ 3. *Composición política*. En cuanto a la constitución política, Roma era una *civitas quiritaria*, es decir, una entidad política autónoma. *Civitas* no es meramente "ciudad" —en latín la ciudad se denomina *urbs* (urbe); así *urbs Roma*—, sino una comunidad políticamente organizada; es el equivalente, aunque tenga diferencias, con la *polis* griega; lo de "quiritaria" viene de la denominación que los antiguos ciudadanos romanos se daban a sí mismos de *quirites*.

a) En el vértice de la *civitas* está el *rex* (de *regere* = dirigir), quien ostenta la autoridad suprema de la *civitas* (entendida acá como *regnum*), tanto en el aspecto político, como militar, judicial y religioso, puesto que es el que mantiene la relación del *populus* con los dioses.

1. El *rex* puede ser propuesto por el antecesor o por el Senado, que ostenta el *interregnum*. Pero su designación debe ser reconocida por una *lex regia de imperio* y aprobada por los dioses. Esto se lograba por la *inauguratio*, o sea, la consulta de la voluntad divina por medio de los *auguric*. Su cargo era vitalicio.

2. Sus insignias, en las cuales se nota la influencia etrusca, eran la toga púrpura, la corona de oro, el cetro y la silla curul, ornada de marfil. Igualmente contaba en los actos con una guardia de 12 *lictores*, que llevaban los haces (*fascas*).

3. Según la tradición histórica hubo siete reyes: cuatro de origen latino (Rómulo, Numio Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio) y los tres últimos de origen etrusco (Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio).

4. Contaba con colaboradores, tales como el *praefectus urbi*, que cuidaba de la ciudad cuando se ausentaba; los *duoviri perduellionis*, encargados de los procesos de alta traición; los *quaestores paricidii*, que actuaban en caso de homicidios y en las tareas militares con el *magister populi* (jefe del ejército), el

praetor (el que marcha al frente), los *tribuni militum* (tribunos de los soldados) y los *tribuni celerum* (tribunos de la caballería).

b) Estaba también el *Senado* (de *senes* = anciano), que estaba compuesto por los jefes de las gentes (*patres gentis*), designados por el *rex*; de ahí su denominación de *patres conscripti*. En un principio habrían sido 100 miembros, luego 300 (100 por cada tribu) a partir de Tarquino el Antiguo.

1. Sus funciones eran: (i) aconsejar al *rex* (*consilium*); (ii) salvaguardar las costumbres tradicionales (*maiores morum*); (iii) ejercer un control de las decisiones comiciales ratificando sus actos por la *auctoritas patrum*; la *auctoritas* (de *augere* = aumentar) completa y da valor total a los actos; (iv) proponer al nuevo *rex*, si el anterior no lo había hecho, ejerciendo el *interregnum*. Un senador mandaba como *interrex*, durante cinco días, pasando luego a otro. Su misión era el proponer al nuevo *rex*, que debía tomar los *auguria*.

c) Igualmente, estaban los *Comicios Curia* (*curiata comitia*). Constituyen la asamblea del *populus*. Estaba integrada sólo por los patricios, componiendo 30 curias, 10 por cada una de las tribus étnicas (*Ramnenses* = Romanos; *Tatenses* = Sabinos; y *Luceres* = Etruscos). La unidad de voto era la curia.

1. Bajo la proposición del Senado, conceden al rey propuesto el *imperium* (*lex regia de imperio*). Aceptan las *leges* y deciden sobre la guerra y la paz. Pueden intervenir en los juicios cuando un ciudadano recurre a ellos por la *provocatio ad populum*.

2. Con el nombre de *calata comitia* se reúnen dos veces al año (el 24 de marzo y el 24 de mayo), presididos por el *Pontifex Maximus*, ocupándose de actos que hacen al *ius civile* y están relacionados con la religión y la familia: así, en caso de testamentos*, o de una *adrogatio**, o de *inauguratio* de un sacerdote, etc.

d) Estaban también los *colegios sacerdotales*, entre los cuales debemos mencionar, vinculados con temas jurídicos: (i) el de los Pontífices, (ii) el de los Augures, y (iii) el de los Feciales.

1. Los Pontífices se ocupan del culto público (*sacra publica*). Tienen el control del calendario, señalando la sucesión de los *dies fasti* (hábiles) y *nefasti* (feriados)*. Igualmente son los que controlan las fórmulas judiciales y está a su cargo la *interpretatio del ius*.

2. Los Augures son los encargados de anunciar los augurios, haciendo saber si la voluntad de los dioses es favorable para la realización de todo acto

importante: la *inauguratio* del *rex*; la *inauguratio* de un templo, la iniciación de una batalla, etc.

Los auspicios se realizaban mediante la lectura de un espacio en el cielo (*templum*), o la consideración de las actitudes de las aves (su vuelo a la izquierda o a la derecha, el apetito de los pollos de que disponían). Si se trataba de la lectura de las entrañas de los animales (*etrusca disciplina*), intervenían los *haruspices*.

3. Los Feciales se ocupan de los ritos vinculados con el derecho internacional (*ius fetiale*); así, de los ritos de la declaración de guerra (*iustum bellum*)* y de la conclusión de tratados.

§ 4. *Composición social*. La sociedad romana *quiritaria* estaba compuesta por los patricios, los clientes, los plebeyos, los esclavos y los libertos.

a) Los *patricios* son aquellos que pertenecen a las gentes originarias de Roma, y son en principio los que tienen los derechos políticos y los privados reconocidos por el *ius civile*.

b) Los *clientes* son aquellos que sin ser patricios son algo así como vasallos admitidos en las familias gentilicias, participando del culto familiar.

1. Por un lado son protegidos por su patrono con el cual están vinculados por un deber de *fides*. Éste los debía auxiliar cuando se hallaban en dificultades. La ley de las XII Tabas condenaba con la muerte al patrono que fuera infiel a su cliente (8.21). Generalmente, una forma de ayuda es que el patrono, a pedido del cliente (*precarium*), les dé el uso de tierras.

2. Por el otro, los clientes le deben lealtad a su patrono, ayudándole en todo aquello que éste les requiera. En la época republicana, la masa de clientes servirá a los propósitos electorales de su patrono.

c) Los *plebeyos* son definidos por exclusión, es decir, no son patricios, ni tampoco clientes. Su origen es discutido: lo más probable es que provinieran de los extranjeros o pueblos latinos vencidos que se han asentado en Roma. No tienen organización gentilicia ni tampoco *sacra privata*. Tampoco acceso a los comicios. Eran aceptados por los patricios permitiéndoles que trabajaran en Roma y pudieran cultivar tierras. Desde el punto de vista político eran simples espectadores.

d) Los *esclavos* estaban en la familia, pero sujetos al *dominium** del *paterfamilias*. Como su origen era, ya por nacimiento, o por cautiverio en guerra, el número era en esta época bastante pequeño. Cuando se los sacaba de la esclavitud, es decir, se los manumitía, se convertían en libertos*, estando de algún modo ligados a su antiguo dueño, convertido ahora en *patronus**. Su situación era equiparada a la de

un cliente, y en los primeros tiempos no adquiere la ciudadanía romana.

§ 5. *Reformas de Servio Tulio*. Una reforma muy importante es debida al rey de origen etrusco Servio Tulio. Frente a la constitución del *populus* basada en el criterio genealógico y religioso de las curias, sobre cuya base se formaban los *curiata comitia*, estableció un nuevo ordenamiento de la población basado en las unidades militares de las *centurias*, teniendo además en cuenta la fortuna que cada familia poseía.

1. Para poder determinar las diferencias, ordena la realización de un censo (*census*) que se debía actualizar cada lustro (5 años). Se debían inscribir todos los mayores de 18 años, denunciando a qué familia pertenecían, y el *paterfamilias* el valor de su patrimonio. Éste estaba calculado en un principio en la posesión de tierras, aunque más tarde se tradujo su valor en ases. El inscribirse en el censo era obligatorio para los hombres libres; bajo pena de ser azotados, privados de sus bienes y reducidos a la esclavitud.

2. Una vez obtenidos los montos, clasificó a la población en "clases" (primera vez que aparece esta palabra en Occidente), de tal modo que se formaron cinco de ellas.

A la primera pertenecían los que tenían 20 yugadas (medida de tierra equivalente a lo que se podía arar con dos bueyes en una jornada; era = 100.000 ases) o más.

A la segunda, los que tenían 15 yugadas (= 75.000 ases) o más hasta el monto de la primera clase.

A la tercera, los que tenían 10 yugadas (= 50.000 ases) o más, hasta 75.000 ases.

A la cuarta, los que tenían 5 yugadas (= 25.000 ases) o más hasta 50.000 ases.

A la quinta, los que tenían 2 yugadas (= 11.000 ases) o más hasta 25.000 ases.

La conversión de yugadas en moneda, se realiza a partir del año 312 a.C., asimilando la fortuna inmobiliaria a la mobiliaria.

3. A su vez, asignó a cada una de las clases un determinado número de "centurias", de tal modo que la primera tenía 80; la segunda, la tercera y la cuarta, 20 cada una de ellas, y la quinta, 30.

Estas centurias estaban a su vez divididas, por mitades, en centurias de *iuniores* (jóvenes de 18 a 46 años) y de *seniores* (mayores de 46 hasta los 60 años).

Por encima de la primera clase existían 18 centurias de caballeros (*equites*). Entre los que no poseían tierras se formaron cinco centurias más: dos de ellas formadas por artesanos (*fabri*, *ignarii* y *aerarii*) que estaban adscritas a los efectos militares a la segunda clase; otras dos más estaban formadas por músicos (*tubicines*, *cornices*), quienes figuraban adscritos a la quinta clase. Finalmente, existía una cen-

turia formada por los del nivel más bajo, ya que no tenían tierras ni oficios honorables (*proletarii*; sólo cuentan con su prole, *gladiatores*, etc.) y finalmente otros que aparecen en el censo anotados sólo con sus nombres (*capite censi*; *accessi velati*). En total eran, pues, 193 centurias.

1ª clase:	18 centurias de equites
2ª clase:	80 centurias;
	20 centurias + 2 de artesanos
3ª clase:	(<i>tignarii</i> ; <i>aerarii</i>);
4ª clase:	20 centurias;
5ª clase:	20 centurias;
	30 centurias + 2 de músicos
	(<i>tubicines</i> , <i>cornices</i>);
	1 centuria de proletarios
	<i>capite censi</i> .

193 centurias

§ 6. Esta reforma de Servio Tulio servía:

a) Por un lado para organizar el ejército (los *iuniores* llevaban las armas contra el enemigo en primera línea; los *seniores* aguardaban en la retaguardia); como se ve, el ejército era el mismo *populus*; no existen los mercenarios.

b) Además, cada componente de las centurias debía aportar sus propias armas, contribuyendo a los gastos bélicos.

c) Por el otro, desde un comienzo y más seguramente en tiempos republicanos, las centurias constituyeron una nueva asamblea popular: los "comicios centuriados" (*centuriata comitia*), que se reunían convocados por un magistrado con *imperium*, aprobando o rechazando sus propuestas.

1. Según su naturaleza timocrática, no se hacía diferencias entre patricios y plebeyos, lo cual significó un primer paso para la integración de estos últimos en la *civitas*.

2. La unidad de voto es la centuria, de tal modo que primero se vota en ella y se obtiene un voto. Pero había un orden: primero votaban los *equites* con más las 80 centurias de la 1ª clase. De este modo, si estaban de acuerdo, se obtenía una mayoría decisiva de 98 votos, tras lo cual era innecesario seguir votando. Como los *equites* eran patricios o de la clase más adinerada, y los de la primera clase también, el resto de las clases, de fortuna menor, se encontraban con que su voto era difícilmente significativo.

3. Igualmente, Servio Tulio subdividió a la ciudad de Roma en cuatro tribus. Éstas ya no tienen que ver con las tribus étnicas (*Ramnenses*, *Tatenses* y *Luceres*), sino que eran distritos político-administrativos, que configurarían las cuatro tribus urbanas. No se sabe bien si para esta época se agregaron 17

tribus rústicas más. Ya en la época republicana alcanzan a 35 tribus.

II. La República.

§ 7. *Comienzos de la República.* En un momento determinado, que según la tradición se establece en el año 509 a.C., fecha que es objeto de críticas por parte de los historiadores, los patricios, que habían visto menoscabada su posición preeminente, por parte de la familia de los Tarquinos, producen un cambio político importante, derrocando al último de los reyes, Tarquino el Soberbio, e instituyendo un nuevo sistema político conocido con el nombre de *res publica*.

1. Según el relato tradicional, la causa patricia habría tenido su motivación para la rebelión en el famoso episodio de Lucrecia. Ésta era una noble matrona romana, casada con Tarquino Colatino. En ocasión del asedio que el último rey había llevado contra la ciudad de Ardea, se encontraron en una fiesta su hijo Sexto con otros compañeros, entre los cuales estaba Tarquino Colatino. Se planteó una discusión sobre cuál de sus mujeres era más virtuosa y habiendo triunfado como la mejor Lucrecia, ello provocó el furor de Sexto, quien abandonando el campamento partió hacia Roma, y penetrando en casa de ella, luego de amenazarla, la violó. Lucrecia, luego de denunciar el crimen a su padre y a su marido, se clavó un puñal. Tarquino Colatino, acompañado por su primo Junio Bruto, expusieron su cadáver ante el pueblo. La irritación que se produjo determinó la destitución del rey, que estaba fuera de Roma y el destierro de toda su familia. Según la tradición, Tarquino Colatino y Junio Bruto asumieron el poder, desechando la forma monárquica.

§ 8. *Integración patricio-plebea.* Para poder comprender el ordenamiento de la *res publica* hay que hacer referencia al lento y dificultoso proceso de integración patricio-plebea.

Indudablemente, aun dejando a un lado la historia moralizadora de Lucrecia, que tornó odioso para los romanos la palabra *rex*, con la cual aparecía asociada, el cambio de gobierno significó una afirmación del poder patricio, al mismo tiempo que una revuelta contra la hegemonía etrusca. Pero ello arrastraba el problema de los plebeyos, cada vez mayores en número.

1. El conflicto patricio-plebeo, que obedecía a causas más profundas que las meras económicas, resulta muy complejo para narrarlo en su totalidad. Mencionaremos dos de estos episodios, que resultan los más importantes:

2. *La secesión de la plebe.* Los plebeyos, conscien-

tes de su creciente número y del aislamiento político que determinaban los patricios, crearon una fuerza armada plebea, que se juramentó (*lex sacrata*) para formar una comunidad separada. Por ello determinaron una secesión (apartamiento político), retirándose al monte Aventino (*mons sacer*).

Según la tradición, fue un viejo patricio romano, muy respetado, Menenio Agripa, quien logró el acercamiento. Su célebre apólogo del cuerpo humano representó la primera gran lección política en pro de la idea de la concordia (*concordia ordinum*), uno de los temas fundamentales en las ideas políticas romanas. Presentó a los plebeyos el caso de la rebelión de los órganos de un hombre, que estaban enojados porque todos ellos trabajaban para el ocioso estómago que recibía todos los alimentos. Decidieron en asamblea privarlo del envío de sustancias, lo cual terminó con la vida del cuerpo del hombre. De manera muy inteligente, presentaba al estómago (los patricios) frente a las energías de los demás órganos (los plebeyos), demostrando que los unos necesitaban de los otros, es decir, los patricios de los plebeyos y éstos de aquéllos.

La plebe decidió reintegrarse a Roma, llegándose a un pacto juramentado, por el cual los plebeyos obtuvieron la posibilidad de reunirse en asambleas propias (*Concilia plebis*), y el reconocimiento de un magistrado-plebeo: el *tribuno de la plebe* (año 494 a.C.). El tribuno podía convocar a la plebe en dichos concilios plebeyos, tomando decisiones que significaron su reconocimiento político-jurídico. Además, el tribuno podía acudir en auxilio de cualquier plebeo frente a actos arbitrarios de los magistrados patricios (*iūs auxilium*). Y lo que era más importante, tenía el veto respecto de las decisiones de dichos magistrados y aun del Senado (salvo en tiempo de guerra), cuando las decisiones afectaran a los intereses plebeyos (casos de arresto o castigo de un plebeo). El tribuno era inviolable en su persona; gozaba de la *sacrosanctitas*, de tal modo que nadie podía atentar contra él, bajo sanción (*sancitio*) de ser declarado *sacer*, pudiendo el agresor ser matado por cualquiera sin que ello implicara un crimen.

Los tribunos tenían como colaboradores a los "ediles plebeyos", encargados del templo consagrado en el año 493 a la trinidad divina de Ceres, Liber y Libera.

3. El otro episodio importante fue la sanción de la *Ley de las XII Tabas* (nos referiremos a ella en el capítulo siguiente). Esto ocurrió entre los años 451-450 a.C. Su importancia estaba determinada por cuanto se trataba de un texto escrito que se aplicaba tanto a los patricios como a los plebeyos.

4. Poco a poco, los plebeyos fueron alcanzando, paso a paso, la ansiada igualdad. Por la *lex Canuleia* (año 445 a.C.), se concede el *conubium* a los plebeyos, de tal modo que éstos pueden celebrar *iustae nuptiae* con los patricios. Por otro lado, conseguirán los plebeyos el acceso a las magistraturas. Ya en el año 367 a.C. se determina la forma definitiva del consulado, pudiendo uno de los cónsules ser plebeo. Igualmente

accederán a los colegios sacerdotales, y en el año 252 a.C., Tiberio Coruncanio será el primer plebeo que será instituido como *Pontifex Maximus*. Con ello se puede considerar definitivamente alcanzada la integración patricio-plebea.

§ 9. *Composición política.* La constitución política de la *res publica* descansa fundamentalmente en el equilibrio de tres órganos: los magistrados (que ejercen el poder; principio monárquico), el Senado (que mantiene la *auctoritas*; principio aristocrático) y los Comicios (asambleas del *populus*; principio democrático). Se toman todas las precauciones para evitar un poder personalista. Si bien los magistrados son los ejecutivos, son elegidos por el *populus* en los comicios, mientras que el Senado mantiene una función de tutela respecto del gobierno.

A) Las magistraturas.

§ 10. Con la caída de la monarquía, el *rex* fue sustituido por dos magistrados nombrados por el *populus* y ratificados por el Senado. Al comienzo se los denominó *praetores* (de *prae* = ante; *ire* = caminar, marchar; es decir, eran los que iban al frente de la tropa). Pero ya a mediados del siglo V a.C. pasaron a llamarse *cónsules*.

Debido a la complejidad creciente de los problemas, se fueron agregando otros magistrados. Así, los censores (año 435); el pretor urbano (año 367; pretor peregrino año 242), los cuestores, los ediles, aparte de las magistraturas extraordinarias y de las magistraturas plebeyas (tribunado y edilato plebeo).

§ 11. *Caracteres generales:* a) Todos los magistrados gozan de la *potestas* (poder de ordenar desde el punto de vista administrativo). Pero sólo los magistrados mayores (cónsules y pretores) tienen el *imperium* (poder de mando político).

1. El *imperium* comprende facultades de mando militar, que cuando se ejerce en campaña (*militiae*) es pleno, pudiendo ejercer la *coercitio* (aplicar penas corporales e incluso la muerte). Pero estando "en casa" (*domi*), es decir, en Roma o a una milla de ella, la *coercitio* se veía limitada, por cuanto todo ciudadano amenazado con una pena corporal o la muerte puede apelar ante el *populus* (*provocatio ad populum*), derecho ya reconocido en las XII Tabas, y luego de algunas vicisitudes, por la *lex Valeria de provocazione* (año 300).

2. Comprende también el *iūs agendi cum populo* (derecho de convocar a los comicios y proponer leyes y candidatos); el *iūs agendi cum patribus* (derecho de convocar al Senado y efectuar consultas); la *iurisdictio* (el poder "decir" el *iūs* en asuntos civiles, penales, etc.) y el *iūs edicendi* (poder dictar edictos).

3. También todos los magistrados tienen poderes para tomar "auspicios", si bien a algunos (p.ej., cónsul, censor, pretor) les está permitido tomarlos en cualquier lugar (*iūs auspiciorum maiorum*), mientras que los otros, solamente en Roma (*iūs auspiciorum minorum*).

b) Las magistraturas son *electivas*, es decir, deben ser aprobadas por los comicios. Los magistrados mayores (censores, cónsules y pretores) son elegidos en los *comitia centuriata*; los menores (ediles curules y cuestores) en los *comitia tributa*. El tribuno y los ediles plebeyos son elegidos en los *concilia plebis*.

1. Se acostumbra el principio de "cooptación", según el cual el magistrado saliente propone al nuevo, quien deberá ser aceptado en los comicios. El candidato (llamado así por cuanto se presenta con una toga blanca —*candida*—) hacía su campaña ante los electores, interviniendo aquí en forma decisiva la clientela.

2. Estaba prohibido acumular al mismo tiempo dos magistraturas. Un nuevo mandato, en principio, no podía ser renovado sino después de haber transcurrido un intervalo de 10 años; los censores no eran reelegibles.

3. Para poder ser elegidos se deben tomar los auspicios. Ello no ocurre con el tribuno y ediles plebeyos, que son elegidos *inauspiciato*.

c) Las magistraturas son *colegiadas*, es decir, a cargo de dos o más magistrados (salvo las extraordinarias), de tal modo que cada uno de ellos tiene un poder igual al de su o sus colegas. Las tareas se dividían, ya por razón de la materia (así, el pretor urbano y el pretor peregrino) o en forma temporal (así, cada cónsul gobernaba un período, un mes, o estando en campaña militar, un día). En este caso (al igual que los tribunos), el que no está ejerciendo tiene el "veto" (*intercessio*) respecto de las medidas tomadas por su colega. Los magistrados mayores tienen este derecho respecto de los menores.

d) En general, las magistraturas son *anuales* (caso de los cónsules, pretores, ediles curules y plebeyos, tribunos y cuestores). Como excepción, los censores son elegidos cada 5 años, debiendo cumplir sus funciones del censo en 18 meses. El *dictator* sólo podía durar 6 meses.

e) Las magistraturas son *gratuitas*: se considera que era un honor el ser magistrado. De hecho, las personas de escasos recursos quedaban por ello autoexcluidas.

f) Las magistraturas son *responsables*. Debían responder por su actuación: los magistrados *cum imperio* pueden ser llevados ante los comicios que los eligieron. Los censores, los tribunos y los ediles plebeyos están protegidos por

su inviolabilidad. En cambio, no lo estaban los ediles curules y los cuestores, que excepcionalmente podían ser responsabilizados ante los comicios tribados.

§ 12. *El cursus honorum*. El acceso a las magistraturas fue reglamentado (ya hacia comienzos del siglo II, revisado por Sila), de tal modo que había que seguir un cierto orden en la "carrera de los honores" (*cursus honorum*).

Esto representó, mientras se lo observó—declinó hacia finales de la República—, uno de los mayores logros de buena política. En efecto, se procuraba que a medida que se iba recorriendo el "orden honorario" se fuera adquiriendo experiencia y capacidad de comprensión de todos los aspectos del gobierno de Roma. Dado el sistema electivo, sólo aquellos que hubieran demostrado eficacia en el ejercicio público, eran aceptados como magistrados.

1. El aspirante a la magistratura sólo a los 28 años podía iniciarse en el *cursus honorum* (con anterioridad debía haber cumplido con diez levas anuales defendiendo a Roma).

a) Así, a esa edad podía aspirar a ser *cuestor* (2 en el siglo VI; 20 bajo Sylla; 40 bajo César). Estaban encargados de las finanzas, ya como guardianes del Tesoro público (*aerarium*), pago a los soldados y tesoreros de las provincias.

b) Luego venía la posibilidad de ser *edil* (2 curules y 2 plebeyos). Se ocupaban del cuidado de la urbe, su aprovisionamiento, la realización de juegos públicos; los ediles curules se ocupaban de los mercados (tuvo importancia jurídica por los edictos dictados).

c) Los *pretores* (1 en el año 367: pretor urbano; 2, desde el año 242; se agregó el pretor peregrino, y más tarde 3 bajo Sylla y 16 bajo César). Se ocupaban de la administración de justicia. Conservan su *imperium* y reemplazan a los cónsules en su ausencia.

d) Los dos cónsules, que son los magistrados ejecutivos máximos. Convocan y presiden el Senado y los Comicios curiados y centuriados, proceden a la leva de soldados y conducen los ejércitos. Dan su nombre al año (por eso son *epónimos*).

e) Para el caso de vacancia de las magistraturas mayores, el Senado conservó su potestad del *interregnum*. Se designaba a un senador por 5 días, quien debía elegir al nuevo magistrado, y así, en caso negativo, sucesivamente a otro senador, hasta que se produjera el nombramiento.

2. Las mencionadas eran las magistraturas ejecutivas. Luego de haber sido cónsul, se podía aspirar a ser elegido *censor*. Eran dos y se ocupaban:

a) de realizar el censo, anotando a los ciudadanos, el cual debía realizarse en 18 meses;

b) mientras durara su ejercicio de 5 años cuidaban de las costumbres (*cura morum*), pudiendo sancio-

cionar con la tacha de *infamia* (o *ignominia* o nota censoria) a los trasgresores;

c) a partir de la *lex Ovinia* (año 318) inscriben a los nuevos senadores entre los ex magistrados.

Podían culminar su carrera política, si luego era nombrado por un sucesor como miembro del Senado.

3. También, desde el siglo III, los magistrados salidos del cargo eran enviados a las provincias para ejercer una "promagistratura" (ya como *pro-cónsul* o como *pro-pretor*). La *lex Pompeia* (año 52 a.C.) impuso un lapso de 5 años entre la magistratura y la promagistratura.

§ 13. Existían también las magistraturas extraordinarias: a) El *dictador* (*dictator*). Era nombrado por uno de los cónsules cuando el Senado disponía que se estaba ante un grave peligro. Duraba 6 meses y tenía plenos poderes. Cesaban las otras magistraturas.

b) El *dictador* elegía un *magister equitum* (jefe de la Caballería y del Estado Mayor).

1. Desde el año 202, el Senado no pidió más la designación de dictadores, limitándose a dar mayores poderes a los cónsules.

2. Como magistratura extraordinaria y en forma temporaria, para redactar la que fue luego la Ley de las XII Tablas*, se eligió a los *decenviros*.

§ 14. A su vez, existían los *tribunos de la plebe*, elegidos en forma anual (2 o 5 en el año 493; 10, a partir del año 471). Debían ser necesariamente plebeyos. Gozaban de los beneficios acordados luego del pacto juramentado, en ocasión del retiro de la plebe al Monte Sacro (año 494 a.C.). Desde los Gracos (133-121), asumieron un papel más amplio, como defensores de los intereses populares, y no sólo de la plebe. Estaban asistidos por dos *ediles*.

B) Los comicios.

§ 15. Las asambleas del *populus* eran de tres clases: a) *Comicios curiados* (*curiata comitia*). Quedaron como sobrevivientes de la época de los reyes. En la práctica, quedan representadas por 30 *littores* en nombre de las 30 tribus. En general, continúa el predominio patricio. Su papel político quedó reducido a conferir el *imperium* a los magistrados mayores (*lex curiata de imperio*) que eran elegidos en los comicios centuriados. Se ocupaban de situaciones jurídicas vinculadas con la familia (testamentos*, adrogaciones*, etc.).

b) *Comicios centuriados* (*centuriata comitia*). Constituidos conforme a la organización dada por Servio Tulio (aunque modificados los números desde el año 220 a.C.), se ocupaban de: (i) elegir los magistrados mayores; (ii) votar ciertas leyes importantes, así como las declaraciones de

guerra (*lex de bello indicendo*); y (iii) juzgar de la *provocatio ad populum* presentada por un ciudadano romano.

c) *Comicios tribados* (*tributa comitia*). Su origen se deriva de la transformación de los *concilia plebis*, sobre todo a partir del siglo III a.C. (*lex Hortensia*), de tal modo que están agrupados los patricios y los plebeyos. Estaban constituidos sobre la base de los distritos (*tribus*), que eran del número de 35 (4 urbanas y 31 rústicas). Se ocupaban: (i) de elegir a los magistrados menores, y (ii) de hacer votar leyes vinculadas con el *ius privatum* (la mayoría de las que nos interesan); ya desde la ley Hortensia (año 287) los plebiscitos habían quedado equiparados a las leyes.

1. Los comicios centuriados, por ser el *populus* en armas, tienen más bien un significado militar. Por ello es que son ellos los que eligen a los magistrados *cum imperio*, y también a los censores. Se deben reunir y votar en el Campo de Marte. En cambio, los comicios tribados se reúnen en el Foro, si bien para votar lo deben hacer en dicho Campo de Marte.

2. A partir del año 220 se modificaron las cifras que correspondían a cada una de las clases. Así, para la primera clase había que tener una fortuna de 1.000.000 de ases, y luego decreciendo para las otras. A su vez, se buscó una cierta integración con las tribus, de tal modo que siendo éstas 35, debía existir en cada una centuria de *seniores* y otra de *iuniores*. Siendo así, todas las clases contaban con 70 centurias cada una. Sumando las 18 de *equites* y las 5 que estaban fuera de las clases, el total es ahora de 373 centurias.

La primera clase (que comienza la votación con una centuria sacada a la suerte —*centuria praerogativa*—) vota con los caballeros, de tal modo que suma 88 votos, y, por tanto, ya no constituye la mayoría, como era antes. De todos modos, la votación se detiene cuando se logra ésta (el voto concorde de 187 centurias). Vuelto más democrático, sin embargo, las centurias pobres prácticamente no votaban.

3. En los comicios tribados, la constitución primitiva de las urbanas fue siempre de 4, mientras que las rústicas fue de 16, luego 17 (año 493), y después en el año 243 fue de 31. Aparentemente más democráticas, lo que ocurría era que los pobres y obreros vivían en la ciudad y sólo contaban con los 4 votos de las tribus urbanas (los libertos ciudadanos estaban obligados a votar en ellas), mientras que los ricos, que tenían propiedades en el campo, votaban en las tribus rústicas, por lo que constituían mayoría.

4. La costumbre era que los cónsules debían presentar sus proyectos (*rogationes*) ante los comicios centuriados, mientras que los tribunos y los pretores, lo debían hacer ante los comicios tribados. Pero luego, el cónsul, para evitar la *auctoritas patrum*, prefería dirigirse a estos últimos.

C) El Senado.

§ 16. Es el órgano más importante de la República. Fundamentalmente tiene la *auctoritas*, de tal modo que de hecho todas las decisiones políticas importantes deben contar con su aprobación.

a) Al principio de la República su integración dependía de los principales magistrados, pero a partir de la *lex Ovinia* (año 318) son los censores los que hacían la lista (*lectio*) de los nuevos senadores.

1. Toman en cuenta la lista precedente (en un comienzo patricios, denominados *patres*), agregándose luego los otros (ex magistrados, incluso plebeyos, *patres conscripti*), que en un principio no hablaban aunque votaban (criterio que irá desapareciendo). Los censores buscan siempre a personas honorables. Podían separar a aquellos que no respetaban las buenas costumbres (*infamia censoria*). El más antiguo, o el más representativo, era denominado *princeps Senatus*. Era el que dirigía los debates, y, en general, su palabra como líder solía arrastrar el parecer de los demás.

b) Hasta Sylla fueron 300; éste los elevó hasta el número de 600. Bajo César fueron 900 y 1.000 bajo el Triunvirato. A comienzos del Principado se fijó el número en 600. Al principio se determinó para la admisión la edad de 46 años; luego 27 y bajo Sylla 30 años.

1. Solían reunirse en el edificio "inaugurado" de la Curia Hostilia o en el templo de la Concordia (o de Júpiter Capitolino). Pero lo podían hacer en cualquier lugar, aun fuera del *pomerium*. Las puertas estaban siempre abiertas, aunque las sesiones no eran públicas. Podían reunirse tanto en días fastos como nefastos, aunque no en día de comicios.

2. Al reunirse se vestían con la túnica de ancha banda púrpura vertical (*lat clavata*) y en las ceremonias con la *toga praetexta* (bordada con púrpura). Se sentaban en bancos, pero no tenían un sitio prefijado. Establecido el orden del día (*relatio*), según el orden del *album*, comenzando por el *Princeps Senatus*, iban emitiendo su opinión. El voto se hacía llamando individualmente según el orden de la lista (*album*), de tal modo que se iban desplazando (*ire pedibus in sententiam alicuius*), formando grupos. Los que estaban en último lugar no alcanzaban a hablar y apenas si tenían tiempo para ubicarse en el grupo de su preferencia; por ello se los llamaba *pedarii* (se desplazaban a pie).

§ 17. Sus atribuciones eran las siguientes: a) La dirección de toda la política exterior, declarando la guerra o proponiendo la paz; designaba a los embajadores y los recibía para apreciar sus informes.

b) La consulta por parte de los magistrados en todo tema importante para la *res publica*. Si bien eran convocados generalmente por un cónsul (o quien tuviera el *ius agendi cum patribus*), podían autoconvocarse. La costumbre política señalaba la importante *auctoritas* del Senado, puesto que un magistrado que tomara una decisión sin previa consulta al Senado para conocer su opinión (*senatusconsultum*) corría el peligro de estar actuando según su propio criterio, por lo que carecía de peso político. De este modo, el Senado controlaba tanto la política interna como externa.

c) Supervisaba todo lo relacionado con la religión romana y decretaba medidas en caso de peligro público (*tumultus*).

d) Hasta cierta época, debía prestar su *auctoritas patrum* respecto de las decisiones de los comicios y concilios de la plebe. Por la *lex Publilia Philonis* (años 339-338), respecto de las leyes y plebiscitos y la *lex Moenia* (año 289), respecto de las designaciones, se decidió que esta *auctoritas patrum* debía ser prestada con anterioridad a la reunión de la asamblea. Finalmente, con la *lex Hortensia* (año 287), se excluyó la autorización previa respecto de los plebiscitos. Pero, reteniendo el criterio de la consulta, el Senado continuó manteniendo su hegemonía en lo legislativo.

e) Finalmente, ejercía el *interregnum* en caso de vacancia de los magistrados. También era el que designaba a los pro-magistrados en las provincias.

Representando la primera y más elevada clase social y política, el Senado fue el órgano rector y salvaguardador de la *res publica*, papel que cumplió defendiendo el régimen republicano hasta la llegada del Principado.

La designación oficial de Roma era precisamente la sigla S.P.Q.R. (*Senatus Populusque Romanus*), con la cual se resume la organización republicana: "El Senado y el *Populus Romano*".

III. El Principado.

§ 18. La organización del gobierno de la República romana fue una magnífica elaboración política que se adaptaba perfectamente a las características de lo que fue Roma desde la caída de la monarquía (fines siglo VI a.C.) hasta la época de su crisis, a propósito de las guerras civiles (fines siglo II y siglo I a.C.). Pero en el lapso intermedio se fueron dando circunstancias que modificaron profundamente el cuadro de situación.

§ 19 El destino histórico de Roma estuvo deter-

minado por una creciente expansión territorial. De simple ciudad junto al Tíber, se convirtió, por la derrota de todos los pueblos vecinos (Volscos, Equos, Sabinos y Etruscos), en la dueña del Lacio, y con posterioridad extendió su poder a toda Italia (año 265 a.C.).

La lucha victoriosa contra Cartago, su gran enemiga, significó tres guerras conocidas como "púnicas". El punto culminante fue la segunda (218-201), en la cual el cartaginés Aníbal, luego de derrotar a tres ejércitos romanos en la propia Italia, puso en peligro la misma Roma. Pero finalmente fue vencido por Escipión el Africano, en Zama (año 201). Significó un alto costo de vidas, pero le otorgó a Roma el predominio de toda la parte occidental del Mediterráneo. Y prontamente, casi sin desearlo pero forzada por las circunstancias, logrará ampliar su espacio político a Grecia, el Asia Menor y todas las zonas aledañas, avanzando hasta el Mar Negro y el Eúfrates.

De este modo todas las costas del llamado *Mare Nostrum* quedaron sometidas a Roma. Más que una gran potencia, fue la dueña y señora de un territorio amplísimo, al cual se agregarán las Galias, amén de buena parte de lo que es hoy Inglaterra. *Imperium Romanum* es sinónimo de todo el orbe terrestre occidental (*orbis terrarum*; en griego *oikoméne*).

Esto representó un verdadero desafío para los romanos, que lograron conservar la unidad de tan grandes regiones, donde habitaban pueblos de distintas composiciones políticas, diferentes lenguas, costumbres y religiones. Para ello empleó un complejo sistema de alianzas, mediante el cual el genio romano logró mantener la diversidad propia de cada una de las regiones, a las que permitía un cierto grado de autonomía, dentro de la unidad política de la *res publica*. Pero por otro lado, se le planteaba el problema de la crisis de las instituciones republicanas para poder administrar y gobernar semejante espacio político.

§ 20. A su vez, en el ámbito interno de Roma comenzaron a asomar problemas sociales. Superada la vieja división entre patricios y plebeyos, ahora perfectamente integrados, aparecen las controversias entre los pertenecientes a la aristocracia acomodada (*optimates*) y las grandes masas urbanas desprotegidas (*populares*). Las reformas agrarias propuestas por dos aristócratas convertidos en tribunos, Tiberio y Cayo Graco (años 133-121 a.C.), fueron un primer intento que terminó trágicamente para ellos, sin haberse alcanzado un cambio profundo.

Más que luchas entre clases económicas, el problema se trasladó a conflictos por el poder dentro de la aristocracia romana. Este estado de cosas condujo a Roma a las "guerras civiles", asistidas por ingredientes demagógicos y procedimientos taimados y brutales. Primero fue la lucha entre Mario y Syla (años 112-83 a.C.), que terminó con la dictadura de este último (años 82-79). Luego la lucha entre Pompeya y

César, quienes conformaron con Craso el llamado "primer Triunvirato", que terminó con el triunfo de César sobre Pompeyo en Farsalia (año 48). César era plenamente consciente de que Roma necesitaba una profunda modificación de su gobierno, tendiendo a una mayor centralización. Acusado de ir contra los ideales republicanos y quererse convertir en "rey", cayó asesinado por los tradicionalistas en los Idus de marzo del año 44.

Se constituye entonces un gobierno de triunviros (el segundo Triunvirato: Marco Antonio, segundo de Julio César, Lépido, jefe de su Caballería, y Octavio, sobrino nieto de César, adoptado por éste en su testamento). Derrotan en Filipo (año 42) a los conjurados republicanos y se reparten la administración del espacio político. Octavio (que se quedó en Italia) termina venciendo en la batalla naval de Accio (año 31) a Marco Antonio (que se había ido a Egipto y aliado con Cleopatra). Con este triunfo, el joven Octavio, ya sin rivales, quedó como el árbitro de la situación.

§ 21. *Constitución política del Principado.* Haciendo gala de sus notables dotes políticas, Octavio emprendió la tarea de realizar el cambio institucional. Esto no ocurrió de un modo directo, como en principio se podría entender. Al contrario, con mucha sutileza, apeló a las instituciones públicas republicanas, proclamando que su misión era precisamente la restauración de la *res publica*.

Por ello es que mantiene la vigencia de todas las instituciones republicanas (magistrados, comicios y Senado). Pero él se ubica como una especie de tutor de la *res publica*. Ya en el año 28 se inscribe en el album senatorial como *Princeps Senatus* (de ahí el nombre de "Principado") y proclama que está dispuesto a cooperar para que el funcionamiento de los órganos políticos se pueda desenvolver.

Aparte de los títulos honoríficos que le fueron concedidos: *Augustus* (de significación religiosa), de *Imperator* (general de las tropas), de *Pontifex Maximus* y de *Pater patriae* (Padre de la patria), Octavio se preocupó por obtener tres potestades que funcionaban conforme al criterio de "colegialidad" de las magistraturas republicanas:

a) la *potestas tribunicia*, que le daba la inviolabilidad de los tribunos, la facultad de reunir a las asambleas, y el derecho de veto respecto de todos los magistrados en ejercicio;

b) el *imperium proconsulare maius et infinitum*, que le daba poder sobre las provincias, y sobre el ejército (las legiones estaban normalmente en las fronteras). Esto le permitía nombrar "legados" (*legati Augusti*), que serían sus comandantes a sus órdenes.

c) la *potestas censoria*, con lo cual lograba el control del Senado. Por un lado era el *Princeps Senatus*; más adelante, mediante el control de

las costumbres, quedó asimilado al censor, y, de este modo, la *lectio* de los senadores.

1. De este modo, sin violentar las instituciones republicanas, a las que dice respetar —salvo en lo relativo al carácter vitalicio de sus funciones—, Octavio Augusto realiza la más grande de las transformaciones del gobierno romano. Admitiéndose como *magister populi Romani* logra mantener el control de los magistrados, de las legiones y del Senado. Establece como *carator rei publicae* toda una serie de funcionarios burocráticos que lo ayudarán en sus tareas, no sólo en la ciudad de Roma, sino también en las provincias. Al lado del tesoro de la *res publica* (el *aerarium*), Octavio conserva un patrimonio particular (*Fiscus*).

2. Este nuevo poder constitucional de Roma fue ejercido con suma prudencia. Continuaban reuniéndose los comicios, eligiendo los magistrados y reuniendo el Senado, pero sus funciones se fueron prontamente desdibujando, pese a que formalmente el *Princeps* y sus sucesores se dirigían a ellos como si realmente gozaran de poder. Lo curioso es que, pese a los republicanos recalcitrantes que se le oponían, la idea política de Augusto estaba ya presente en los escritos de Cicerón. Y gozó del favor literario del historiador Tito Livio y de los poetas Horacio y Virgilio, que celebraron la nueva Edad de Oro que había advenido. El "siglo de Augusto" y la *Pax Romana*, de casi dos siglos de duración, volcaron en su favor la opinión pública.

3. Desde Octavio el Príncipe se preocupó por hacer participar a la clase senatorial y a la de los caballeros en la tarea de la administración. Comienza así una burocracia que irá aumentando a medida que pase el tiempo; uno de los principales organizadores será Claudio, y luego Adriano. Entre los funcionarios más altos estaban:

a) El *Praefectus urbi* (prefecto de la ciudad), elegido entre los principales senadores del orden más alto (consulares), el cual se ocupaba de todo lo relativo a la tranquilidad y orden de la urbe, teniendo una función jurisdiccional en materia penal.

b) Estaban también los *Praefecti praetoria*, generalmente de la clase de los equites (*solian ser dos*), que eran los jefes de la guardia pretoriana, con competencia militar y civil, eran los representantes del emperador (algo así como viceemperadores); tendrán importancia en la designación de los Césares posteriores.

c) Igualmente, estaba el *Praefectus annonae*, encargado del aprovisionamiento de trigo y víveres en Roma; el *Praefectus vigilum*, una especie de jefe de policía, que se ocupaba de los casos de incendios y disturbios en Roma; y también entre los principales, el *Praefectus vehiculorum*, que era un jefe general de correos.

§ 22. *¿Principado o diarquía?* Algunos autores (p.ej., Mommsen) establecen que esta

nueva constitución política involucra una "diarquía" (gobierno de dos poderes). Se basan en que la administración de las provincias estaba dividida entre el César (provincias tributarias—pagaban un *tributum* que ingresaba en el Fisco del Emperador—; *provinciae Caesaris*) y el Senado (provincias estipendiarias—pagaban un *stipendium* que ingresaba en el *aerarium*—; *provinciae populi Romani*).

Pero, si bien esto era cierto, mirando el nuevo orden constitucional de Roma, resulta más exacto decir que el peso del poder pasaba fundamentalmente por el *Princeps*, ya que el propio Senado, cuyos miembros eran elegidos por el César, salvo esa función administrativa en lo provincial, era políticamente dependiente de Augusto. De ahí que resulta más apropiada la denominación de Principado.

1. El nombre personal del Emperador será el de *Imperator*, o el de *Caesar*, o el de *Augusto*. Tiene derecho a la guardia de 12 lictores (24 después de Domiciano); lleva la corona de laureles y en público la *toga praetexta*. Su mujer tiene derecho al título de *Augusta*, y los príncipes de la familia al de *Caesar*. Esta denominación perdurará, aunque deformada, en el alemán *Kaiser*, en el ruso *Czar*, y en el iraní *Shah*.

2. El Emperador cuenta con su propia Cancillería imperial. Está compuesta de Oficinas (*scrinia* = escritorios) que ayudan al Príncipe en la labor centralizada de la administración del Imperio:

a) Sección *ab epistulis* (correspondencia con las provincias; relaciones con los embajadores); estuvo organizada por un libertado de Claudio;

b) Sección *a rationibus* (asuntos financieros y contables, también organizada por Claudio).

c) Sección *a cognitionibus* (asuntos judiciales, ocupándose de las apelaciones en el procedimiento *extra ordinem*; según algunos, también atendiendo apelaciones en el procedimiento ordinario, pero esto era muy raro).

d) Sección *a libellis* (separada de la *ab epistulis*), que se ocupaba de los pedidos realizados al Príncipe; y también se agregó un cargo especial para la redacción del diario imperial (*a memoria*).

Lo curioso es que estos cargos estuvieron en un principio en manos de libertos, la mayoría de origen griego, que eran muy hábiles en las tareas administrativas. Desde Hadriano, estos cargos son ocupados por caballeros (*equites*).

En la organización de las finanzas imperiales se logró mayor eficacia, superándose el antiguo sistema de recaudación. Los representantes del Fisco debían hacer efectivo el cobro a los deudores ante los tribunales. Desde Hadriano, se nombran *advocati fisci*.

3. En cuanto al gobierno de las provincias, los senatoriales estaban a cargo de procónsules (senadores). Mientras que en las provincias del César, también se acostumbraba designar como gobernadores a

senadores; se llamaban *legati Augusti pro praetore*, y tenían funciones civiles, judiciales y también estaban al frente de las tropas que estaban allí. En provincias más pequeñas, el gobernador era de la clase de los *equites*, llamándose *procurator* (tal el caso de Poncio Pilatos en Judea). Una provincia muy importante era Egipto, por ser proveedora de cereales; se la consideró muy especialmente y estaba a cargo de un *praefectus Alexandriae et Aegypti*, que era un caballero, y no un senador.

La mala administración en las provincias senatoriales hizo que el Senado recurriera al Príncipe, quien envió a ellas un *legatus pro praetore*. De este modo, la distinción, a comienzos del siglo II era nominal, y la centralización imperial se fue imponiendo. Hacia finales del siglo II todos los gobernadores adoptaban el mismo título de *proeses*.

§ 23. El punto más flojo que tuvo este período del Principado fue la determinación de la forma como accedía al poder el nuevo *Princeps* cuando moría o cesaba el anterior. En un principio, se siguió el sistema de la "cooptación" (el vigente elige y propone al siguiente), incluso adoptándolo o asociándolo al gobierno en vida. Pero luego comenzarán a tener importancia como grupo de presión las fuerzas militares. Primero, la guardia pretoriana que rodeaba al emperador, y más adelante los cuerpos de legiones que estaban en las fronteras.

Para recordar los nombres de los emperadores y sus respectivas épocas, podemos establecer el siguiente cuadro cronológico:

I. *Dinastía julio-claudiana* (29 a.C.-68 d.C.), denominada así por emperadores de la *gens julia* y de la *gens claudia*, emparentados entre sí:

1. *Octavio Augusto* (29 a.C.-14 d.C.).

2. *Tiberio* (14-37; muere asesinado por orden de Macrón, Prefecto del Pretorio, a los 78 años).

3. *Caligula* (37-41; muere asesinado a los 29 años por un tribuno de la cohorte pretoriana).

4. *Claudio* (41-54; muere envenenado por su esposa Agripina a los 63 años).

5. *Nerón* (54; en el año 64, incendio de Roma; se suicida a los 31 años, luego de la revuelta de Galba en las Galias, en el año 68).

6. *Galba* (68-69, asesinado por los pretorianos).

7. *Otón* (69; se suicida ese mismo año, luego de la derrota de sus tropas frente a Vitelio, proclamado por las legiones de la Rhenania).

8. *Vitelio* (69, asesinado luego de la revuelta de las tropas de Oriente y del Danubio, movidas por Vespasiano).

II. *Dinastía de los Flavios* (años 69-96).

9. *Vespasiano* (69-79), quien restablece el orden interno. En el año 70, destrucción de Jerusalem a manos de su hijo Tito.

10. *Tito*, (79-81).

11. *Domiciano* (81-96), quien muere asesinado.

III. *Gobierno de los Antoninos* (96-192). No conforman propiamente una dinastía, ya que salvo entre los dos últimos emperadores, no existía vínculo familiar.

12. *Nerva* (96-98), que establece una alianza con el Senado, y de común acuerdo con éste, asocia al que será el primer emperador de origen provincial (Trajano, descendiente de colonos italianos establecidos en Itálica, España).

13. *Trajano* (98-117), uno de los mejores emperadores, quien administrará excelentemente a las provincias.

14. *Hadriano* (117-138). Pacífico y viajero. Estableció el célebre muro (*Vallum Hadriani*) en Escocia. Aumentó la burocracia, sobre todo la vinculada con los juristas (*consilium*).

15. *Antonino Pío* (138-161). Su reinado fue también calmo. Su moderación y su respeto a los viejos cultos romanos, le valieron el agregado de Pío.

16. *Marco Aurelio* (161-180). Adoptado, no mismo que Lucio Vero por Antonino Pío, gobierna juntamente con él, hasta la muerte de este último (169). Gran pensador estoico (su obra célebre son sus *Pensamientos*, escritos en griego).

17. *Comodo* (180-192). Hijo del anterior, se caracterizó como un demente peligroso. Fue asesinado en una conjuración debida a su favorita Marcia.

IV. *Dinastía de los Severos* (193-235).

18. Luego del breve gobierno de *Pertinax* (193) y de la acción del senador *Didio Juliano*, que compró el cargo a los pretorianos, este último es asesinado por *Septimio Severo*, de origen africano.

19. *Septimio Severo* (193-211). Fue un emperador que se alejó de las viejas tradiciones. Se apoyó en el ejército ("Enriqueced a los soldados y burlesco del resto"). Extendió el Imperio hasta el Eufrates.

20. *Caracalla* (211-217). Gobernó al principio con su hermano *Geta*, al que hizo matar a los pocos meses. En el año 212, otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, salvo algunas excepciones (*constitutio Antoniniana*). Se asentó en el ejército, que terminó asesinandolo.

21. Luego del corto gobierno de su asesino, *Macrino*, asumió, gracias a las legiones, un sacerdote sirio, *Elagabalus* (218-222).

A partir de este momento, se inicia un período de anarquía. Los distintos emperadores, de breve duración, son nombrados con intervención de las legiones (*Maximiano I*, de origen godo —225—; *Gordiano I*, *Gordiano II* y *Gordiano III* —238—; *Filipo el Árabe* —244—; *Decio* (249); *Triboniano Galo* (251); *Emiliano*, *Valeriano* y *Galiano* (253); los 30 Tiranos proclamados en las provincias (260); *Claudio II* (año 268), de origen ilirio; *Aureliano* (270); proclamación del senador *Tálcio*, asesinado (275); el ilirio *Probo* (276);

proclamación de *Cáro* (282), y prontamente sus hijos, *Númeriano* y *Carin* (282-284), hasta que llegó al poder *Diocleciano* (284).

El Imperio sufrió una importante anarquía militar, con amenazas de desmembramiento (en Galia había emperadores particulares), así como también peligros exteriores: invasiones germánicas (godos, alemanes, francos), hasta tal punto que se debió pagar tributo a los godos. Por otra parte, los persas amenazaron la frontera oriental: se produjo la humillación inaudita de que un emperador, Valeriano, fue tomado prisionero por el rey persa Sapor, quien lo sometió a suplicio.

IV. El Dominado.

§ 24. *Diocleciano* (284-305). La figura de *Diocleciano*, con su gobierno fuertemente centralizado, operó una reforma muy amplia del Imperio, tendiente a sacarlo del estado anárquico que estaba padeciendo. Ya en su propia designación de *sacratissimus Dominus*, de hecho divinizaba su persona. Se llamó directamente *imperator* en lugar de *princeps*.

1. La persona del *imperator* de este período, se rodeó de todas las circunstancias que eran propias del gobernante oriental, tipo Darío o Jerjes. Aparecía en público con sus vestiduras púrpuras recamadas en oro, luciendo la diadema orlada con perlas. Se comenzó a establecer un minucioso ceremonial, excesivamente ritualista. Quien se presentaba ante el *Dominus*, lo debía hacer con las rodillas en tierra. De ahí la denominación de Dominado. Ya desde *Diocleciano*, el Emperador es tributario de un culto personificado, como un dios.

Para lograr un mejor gobierno y administración del Imperio Romano, considerando la gran extensión de las tierras que lo componían, lo dividió en una parte oriental, con sede en Nicomedia, en la Asia menor, que él se reservó, y otra occidental, con sede en Milán, que concedió a *Maximiano*, a quien nombró su colega. Ambos eran *Augustos*. Pero, al mismo tiempo, ambos designaron a dos *Césares*: *Galerio*, a quien se le asignó el gobierno de Iliria (lo que después será Yugoslavia) y Grecia, y a *Constancio Cloro*, con gobierno en las provincias de Galia, Hispania y Britania. De este modo, se formó lo que se llamó la *Tetrarquía* (gobierno de cuatro). El propósito era solucionar por un lado el gobierno de las diversas regiones, y por el otro, el grave problema de la sucesión, pues se había dispuesto que luego de cierto término, los *Césares* pasarían a ser los nuevos *Augustos*, quienes a su vez debían elegir nuevos *Césares*. Roma quedó como ciudad histórica, capital meramente nominal del Imperio.

1. Todo esto significó un gobierno fuertemente centralizado y sumamente burocrático. A semejanza de los cuerpos de las legiones, aparecen toda una cohorte de funcionarios que dependen directamente de los Augustos. Incluso clasificados jerárquicamente: así, los más altos eran los *illustres* (el *praefectus praetorio*, jefe administrativo; el *quaestor sacri palatii*, consejero supremo en materia jurídica), etc. Luego estaban los *spectabiles*, los *clarissimi* y los *egregii*. El Senado continúa, pero queda convertido en una corporación municipal, de significación nobiliaria, apta para la pompa imperial.

2. Desde el punto de vista económico, el ejercicio de esta burocracia trató, sin mucho éxito, de resolver la crisis por la cual estaba pasando el Imperio. Esta se apreciaba tanto en las fuentes de producción (agricultura, comercio e industria) como en la distribución de las tierras. Fuertes impuestos trataban de sostener la pesada maquinaria burocrática-militar.

3. Un problema muy especial lo tuvo Diocleciano con los cristianos, cada vez más crecientes en número. A pesar de una gran liberalidad en cuanto a la libertad de cultos, lo que resultaba imposible de aceptar para el Cristianismo era el reconocimiento del Emperador como *Dominus*, título sólo debido a Dios. Ello desembocó en tremendas persecuciones —que antes habían sido mas o menos esporádicas y fundadas en la desconfianza de los gobernantes hacia el nuevo culto basado en la caridad hacia los humildes—. Esta es la gran etapa de los "mártires" (testigos) que preferían ofrendar su vida al verdadero Señor, y no a la persona del *Dominus*. En ello, veía Diocleciano un alzamiento contra el poder imperial. Los cristianos, al contrario, veían en su figura una representación de la Bestia apocalíptica.

§ 25. *Constantino* (306-337). Las expectativas de Diocleciano de haber establecido un orden duradero no tuvieron éxito. Luego de 20 años de poder, renunció a su cargo, lo mismo que el otro Augusto, Maximiano, para dejar paso a los Césares. Las disputas personales entre los que mantuvieron los nuevos Augustos y Césares hicieron peligrar el plan político de Diocleciano.

Prontamente la lucha se estableció entre dos personajes hegemónicos: Constantino, que asumió en el año 306, en York, después de la muerte de su padre Constancio Cloro, y el hijo de Maximiano, Majencio, que asumió en Roma. El primero derrotó a éste en la célebre batalla de Puente Milvio (312) y quedó como único árbitro de la situación.

1. Según se dice, la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo un sueño premonitorio, donde se le presentó el signo cristiano de la cruz y una voz que le dijo: *In hac signo vincas* (Con este signo vencerás), razón por la cual lo lucieron sus soldados en los

lábaros (en realidad no era propiamente una cruz, sino el signo de una cruz atravesada por una P). La batalla tuvo por ello una significación religiosa, puesto que Majencio estaba iniciado en el culto militarista de Mithra, luciendo el emblema del *Sol invictus*.

Constantino disolvió la Tetrarquía de Diocleciano, aunque dividió el Imperio en cuatro Prefecturas: Oriente (Bizancio), Iliria (Sirmio), Italia (Milán) y Galia (Tréveris), con 14 diócesis y 117 provincias. Reforzó el ejército y reformó el orden burocrático. Su medida más importante fue el famoso Edicto de Milán (313), por el cual decretó la libertad de todos los cultos. De este modo, el Cristianismo, de perseguido, no sólo pasó a ser admitido, sino que gozó del favor imperial.

1. Constantino será el primer emperador que ejercerá lo que se dará en llamar el "césaro-papismo", que luego se continuará con los sucesores bizantinos, sobre todo con Justiniano. Constantino, como emperador "cristiano" —esté muy discutida su conversión personal, si bien poco antes de expirar se bautizó—, será quien convocará el primer concilio ecuménico, en Nicea (325), reuniendo a todos los prelates cristianos para fijar el Credo y condenar al arrianismo.

2. Establecerá la capital en Bizancio, la que será llamada Constantinopla (330).

3. Los viejos adeptos al culto romano se refugiaron en las aldeas (*pagi*; de ahí su denominación de "paganos"). Tuvieron un fuerte defensor en el emperador Juliano, llamado el Apóstata (361-363), quien trató de reavivar los ritos tradicionales romanos. Murió combatiendo contra los persas.

§ 26. La gran figura posterior fue *Theodosio*, de origen español, llamado el Grande (379-395). De fuertes convicciones cristianas (influencia de San Ambrosio, obispo de Milán), persiguió al paganismo, mientras que el Cristianismo pasó a ser la religión oficial romana (año 391). A su vez, a su muerte, dividió, ya definitivamente, el territorio en el Imperio de Occidente, que dejó a su hijo Honorio, y el Imperio de Oriente, a su otro hijo Arcadio.

1. En la parte occidental, los problemas de las migraciones, en principio pacíficas, de los bárbaros se fueron tornando cada vez más amenazantes. Roma tuvo que recurrir para su defensa a generales y tropas bárbaras romanizadas. Ello no impidió que la frontera del Rin fuera forzada por los suevos, los vándalos, los alanos y los burgundios. Alarico someterá a saqueo a la ciudad de Roma (410). Se tendrá también que soportar al "Diablo de Dios", como se lo llamó a Atila, que depredó la Galia. Y hasta el mismo rey de los vándalos, Genserico, se apoderará de Roma por mar en el año 455.

2. En Occidente, la sucesión de los emperadores fue la siguiente: *Honorio* (395-423), *Valentiniano III* (425-455), *Maiano* (457-461) y *Anthemio* (467-472).

En el año 476, Odoacro destronará al último representante del poder romano, cuyo nombre paradójicamente era Rómulo Augústulo. Con ello finalizará el Imperio Romano de Occidente, y según los historiadores la Edad Antigua.

3. En Oriente reinará *Arcadio* (395-407), seguido por *Theodosio II* (408-450), *Marciano* (450-457), *León*

(457-474), *Zenón* (474-491), *Anastasio* (491-518), *Justiniano I* (518-527) y finalmente *Justiniano* (527-565).

Justiniano I había asociado en el trono a Justiniano, que era su sobrino, al cual había adoptado. Este se casó con una bailarina circense, Theodora, la cual fue elevada por Justiniano a la dignidad de Augusta.

El Imperio de Oriente perduró a lo largo de toda la Edad Media, hasta que los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla, en el año 1451.

CAPÍTULO 2

HISTORIA DEL DERECHO ROMANO

§ 27. Lo que se denomina "Derecho Romano" —en sentido propio— abarca el estudio de las instituciones jurídicas romanas que hacen al Derecho Privado (*ius privatum*), consideradas desde la fundación de Roma (año 754 o 753 a.C.) hasta la compilación realizada por el emperador Justiniano en el siglo VI d.C. (que abarcó entre el año 529 y el año 536), que se conoce con el nombre de *Corpus Iuris Civilis*.

1. Este sentido estricto del Derecho Romano no significó que finalizara luego de Justiniano. En la parte oriental del Imperio continuará su vigencia, no sólo por nuevas disposiciones legales, sino además por escritos doctrinarios o recopilaciones. Esta labor en la "Segunda Roma" (la de Constantinopla, luego de la caída de la ciudad de Roma) durará hasta el saqueo de aquella urbe en el año 1453. A su vez, en la parte occidental, se prolongará su vigencia, gracias a los nuevos estudios realizados por los Glosadores y los Postglosadores (siglo XII), convirtiéndose durante mucho tiempo en el *ius commune* de los pueblos europeos, e influyendo luego en la tarea de codificación emprendida en los tiempos modernos y actuales.

§ 28. *Etapas en la historia del Derecho Romano*. En tan largo período, las instituciones jurídicas fueron variando según los cambios sociales, económicos, políticos y religiosos que se fueron produciendo. Podemos distinguir las siguientes etapas:

a) El derecho antiguo (o *quiritario*; *Quirites* es la vieja denominación que se daban a sí mismos los romanos), y que ubicamos desde la fundación de Roma hasta el año 130 a.C.

b) El derecho romano clásico, que abarca entre el 130 a.C. hasta el 230 d.C. (dentro del cual podemos distinguir una primera etapa, que algunos ubican como "preclásica", durante la República; años 130-30 a.C.; una segunda, el "derecho clásico central"; años 30 a.C.-130 d.C.; y una tercera, el "derecho clásico tardío"; años 130-230 d.C.).

c) El Derecho Romano post-clásico, que va desde el 230 d.C. al 530 d.C., fecha en la cual podemos ubicar la compilación justiniana (528-535), que se continuará hasta la muerte de Justiniano (565).

1. El tema de la división en etapas del Derecho Romano, como todas las divisiones hechas por los historiadores, es relativa. En nuestro caso varía según cada autor. Empezar la tarea de explicar cada uno de los criterios es una labor enciclopédica, que arroja pocos resultados prácticos al estudiante. Aquí hemos seguido el criterio de Álvaro d'Ors, sobre todo porque se emplea una regla mnemotécnica en cuanto a las fechas (130-230-530, etc.), que resulta más cómoda para recordar.

I. Derecho Romano Antiguo (Derecho *quiritario*).

§ 29. El *ius* en un principio no estuvo escrito. Consistía en los denominados *mores maiorum*. Esta palabra sirve para hablar de las "viejas costumbres de los antepasados", como criterios morales de virtud, que se respetaban estrictamente. Pero también para referirse a los "ritos" (palabra intercambiable con *mores*, y que aquí tomamos como "ritos jurídicos").

1. Estos ritos serán en general solemnes. Así, principalmente la *mancipatio** (cuyos efectos son siempre adquisitivos de poder sobre una persona o una cosa) y el *nexum** (que produce efectos obligacionales). Se caracterizan por el empleo del cobre y de la balanza (*per aes et libram*).

2. Los poderes de las familias se ejercen bajo la forma de *potestates* (la patria *potestas** sobre los *filiifamilias*; la *manus** sobre la mujer casada; la *dominica potestas** sobre los esclavos y las cosas; y el *mancipium** sobre otras personas libres).

3. Los conflictos de intereses que dan lugar a un pleito, son resueltos por el procedimiento de las *legis actiones**, sumamente ritual con el empleo de fórmulas orales muy estrictas.

§ 30. *Las denominadas leges regiae*. Para esta primera época se habla de la existencia de ciertas leyes dictadas por los reyes (*leges regiae*). El problema viene por la cita de Pomponio en la sucinta historia del *ius romano* que realiza en el libro I del Digesto (D.1.2.2.2 y 16).

Menciona allí que primero Rómulo y luego los demás reyes promulgaron unas leyes a las que de-

nomina "curiadas" (aprobadas por los comicios curiados?). Estas habrían sido agrupadas por un tal Sexto Papirio, de la época de Tarquino el Soberbio, recopilación que se conoció como *ius civile Papirianum*.

Dicha obra no nos ha llegado, existiendo sólo esta mención de Pomponio, además de otra de Paulo (D.50.16.144) y de dos más de los escritores Macrobio (Sat. 3.11.5) y Servio (ad Aen. 12.836). Se cree que esta recopilación sería muy posterior (hacia fines de la República). Sin embargo, por la mención de diversos autores, aparece cierta la existencia de leyes de Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Servio Tulio. Se las pueden encontrar en los *Textes* de Girard y en las *Fontes* de Bruns.

§ 31. *Ley de las XII Tabas*. A comienzos de la República, y dentro del clima de hostilidad existente entre patricios y plebeyos, se aprobó la famosa Ley de las XII Tabas (años 451-450 a.C.). Los romanos vieron en ella el fundamento de su vida jurídica, tanto en el aspecto público como privado (*sons omnis publici privati que iuris* = "fuente de todo el *ius publicum* y *privatum*"; Tito Liv. 3.34.6). Fue redactada por diez magistrados especialmente creados para este fin, los "decenviros" (*decemviri legibus scribundis*), razón por la cual es también conocida como la "ley decenviral".

1. Según la tradición, en el año 462 a.C., el tribuno de la plebe Cayo Terentilio Harsa propuso un plebiscito para obtener un *ius scriptum* válido para los patricios como para la plebe. A ello se opusieron los patricios, por medio del Senado. Pero, hacia el año 454, accedieron a enviar una comisión de tres miembros a Grecia (¿Magna Grecia, la región sur de Italia?), a fin de estudiar la técnica de leyes escritas (esf, las leyes de Solón). A su regreso, los patricios hicieron votar en los comicios centuriados una ley, suspendiendo todas las magistraturas y entregando el gobierno de Roma a estos "decenviros".

2. Primero se redactaron diez tablas, y como había vencido el plazo de un año que tenían, hubo que nombrar otros "decenviros" (quizá con la presencia de un plebeyo), que redactaron dos tablas más. Entre sus miembros, estaba Apio Claudio, patricio cruel y libidinoso, que quiso perpetuar el decenvirato cometiendo el error de querer apoderarse de Virginia, hija del plebeyo Virginio, reclamándola como liberta suya (el llamado "proceso de Virginia"). Viendo el padre que el juicio no era imparcial, prefirió darle muerte a su hija en pleno Foro. Ello produjo la caída de los decenviros y el regreso al orden constitucional de las magistraturas republicanas.

3. Sólo conocemos en forma fragmentaria el texto de la Ley de las XII Tabas. Las tablas primitivas, en madera, desaparecieron en el incendio de Roma por los Galos (año 390 a.C.). En general, por lo que se ha

conservado gracias a diversos autores (por su forma rimada, los niños la aprendían de memoria en la escuela), no se puede decir que introdujo un derecho nuevo, sino más bien se asentó por escrito los viejos ritos jurídicos y reglas vigentes con anterioridad. No se habla de la organización política romana. Están referidas a los procedimientos judiciales, incluso de ejecución (en tal sentido resultan importantes para conocer las *legis actiones*). También contienen disposiciones del Derecho Penal romano y reglas del derecho hereditario. Al contrario, salvo alguna excepción referida a la *mancipatio*, no hay un tratamiento expreso de los negocios jurídicos.

§ 32. *La interpretatio*. El Colegio de los Pontífices mantenía un exclusivo control del Calendario, donde figuraban los días en que se podía actuar judicialmente (*dies fasti*) y de las fórmulas rituales que debían pronunciarse los litigantes (el que quería actuar debía acudir a ellos). Los Pontífices eran también quienes se encargaban de la "interpretación" jurídica (*interpretatio*) cuando existía alguna duda en la aplicación del *ius*.

Pero este monopolio pontifical sufrió un duro golpe con la publicación de las fórmulas de las *legis actiones* y del calendario. Esto fue debido al hijo de un libertado, que era escriba del censor Apio Claudio *Caecus* (distinto del otro Apio Claudio), llamado *Cneo Flavio*. Esta recopilación fue conocida como *Ius Flavianum* (año 304 a.C.). A esto se unió el hecho de que cuando un plebeyo, *Tiberio Coruncanio*, alcanzó a ser Pontífice Máximo, se dedicó a dar sus interpretaciones (*responsa*) en pública. De este modo, el conocimiento de la ciencia del Derecho quedó totalmente secularizado.

Con posterioridad, siendo cónsul *Sexto Aelio Peto* (año 198), publicó sus célebres *Tripartita*, llamadas así porque contenía tres secciones: la ley de las XII Tabas, la *interpretatio* de ellas y las fórmulas de las *legis actiones*. Se lo denominó *Ius Aelianum*.

§ 33. *Las leyes*. En la época republicana comienzan a figurar como fuentes del *ius* las "leyes" (*leges*).

La *lex* consiste en una disposición jurídica aprobada por el *populus*, reunido en los comicios, a propuesta de la *rogatio* de un magistrado. Por ello es denominada *lex rogata*, a diferencia de la *lex data*, que es aquella dictada directamente por el magistrado.

1. *Concepto*. Los vocablos *lex rogata* y *lex data* corresponden a la *lex publica*. Pero hay que recordar que también existen las *leges privatae*, que son aquellas disposiciones que las partes pueden intercalar en un negocio que les concierne, y a las cuales se deben

someter (p.ej., un pacto comisorio) — *lex commissoria* — en el contrato de compraventa).

Capivo nos dice que *lex est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu* (ley es lo que el *populus* o la plebe establece para todos, a propuesta de un magistrado; Aulo Gell., X.20). Gayo (1.3) la define como "lo que el *populus* ordena y establece". Y en las Institutas de Justiniano (1.2.4) se dice que "ley es lo que el *populus Romanus* establece, a propuesta de un magistrado del orden senatorial, como p.ej. el cónsul".

Se quiere ver en la *lex* una especie de convenio establecido entre el magistrado y el *populus*, a semejanza de lo que ocurre con la *lex privata*. Por ello, Pomponio habla de *communis rei publicae sponsio* (una forma de contrato común de la res publica). Pero si bien el *populus* es el que aprueba la *lex*, el papel predominante es para el magistrado proponente, quien someterá su *rogatio*, casi con la seguridad política, dado el trámite que tenía, de su posterior aprobación.

2. *Procedimiento*. 1. La *lex rogata* es votada en los comicios centuriados y tribados. El trámite era el siguiente:

a) Un magistrado, de entre los que pueden "rogar" al *populus* (*ius agendi cum populo*), como eran el cónsul, el dictador, el pretor, etc., hacía su proposición en forma pública anunciándola en tres días de mercado en el Foro. A esto se llamaba *promulgatio*.

b) La propuesta podía ser discutida en reuniones informales de ciudadanos, llamadas *contiones* (*contio* es una mera reunión pública), a las cuales podía asistir el magistrado proponente o enviar alguien en su nombre.

c) Previa consulta de los auspicios (*auspicatio*), y hasta un determinado momento histórico contando con la autorización senatorial (*auctoritas patrum*), se reúnen los comicios. En ellos no se discute nada, sino que el magistrado hace su *rogatio* al *populus*. La votación se hace en el orden establecido en las centurias o en las tribus. Se empleaban cartones, lo que facilitaba el cómputo. Los que se inclinaban por la afirmativa decían *Uti rogas* (= conforme con lo que establece). Si eran por la negativa, la fórmula era *Antiquo* (= me quedo con lo antiguo, es decir, con la situación anterior).

3. Por lo que se ve, el control del procedimiento lo tiene el magistrado. Este, al presentar su proyecto, trata de interpretar el sentir de los grupos mayoritarios, incluso consultando al Senado; en cambio, el *populus* no puede presentar proyectos de ley. Con las *contiones*, tiene la oportunidad de pulsar políticamente a los futuros votantes, pudiendo hacer las modificaciones que entienda convenientes. De este modo, podía saber, en la mayoría de los casos, cómo votarían los comicios. El "punto de gravedad" pasa, pues, por el magistrado. *Rogatio* (que está emparentado con *rego*, de donde viene *res*) significa más "dictar" que "rogar". La mención del *populus* en las definicio-

nes pasa, por tanto, como un recurso polístico para hacer ver que es él quien "ordena y establece". Lo cierto es que en la realidad política, su única facultad propia independiente era la de oponerse y votar por la negativa.

§ 34. *Partes de la lex*. El texto estaba compuesto de: a) la *prascriptio* (nombre del magistrado proponente, lugar de reunión de la asamblea, nombre de la centuria o tribu, y del ciudadano que votó en primer término); b) la *rogatio* (el contenido propio de la ley); y finalmente, venía la *sanctio*, por la que se fijaba la sanción de los actos realizados en contra de lo establecido en la ley. Por contener una *sanctio*, las leyes son consideradas *sanctae* (Ulp., D.1.8.9.3).

§ 35. *Denominación*. Por lo general se hace por el nombre gentílico del autor, acompañado por el de su colega en el caso de los cónsules, ambos en nominativo femenino. Así, *lex Poetelia Papiria* (ley propuesta por Poetelio, cuando era cónsul juntamente con Papirio; año 326 a.C.).

Si llevan un solo nombre, ello es así por cuanto fue dictada, p.ej., por un *dictator*. Así, *lex Hortensia* (el autor fue el dictador Hortensio). También tuvieron un solo nombre los plebiscitos (luego denominados leyes); así *lex Aquilia* (propuesta por el tribuno Aquilio; año 286 a.C.). Algunas leyes contienen también la mención del asunto tratado; así, *lex Acilia repetendarum* (de represión de los delitos de los magistrados en sus funciones) o la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, por la cual se concedía y reglamentaba la ciudadanía de los Galos cisalpinos).

§ 36. *Clases de leyes*. Según Ulpiano (1.2), las leyes pueden ser: *perfectae*, que son aquellas que contienen en la *sanctio* la pena de nulidad de los actos que sean contrarios a sus disposiciones; *minus quam perfectae*, que son aquellas que en la *sanctio* castigan con penas a los trasgresores, pero sin declarar nulos los actos contrarios a dichas leyes; e *imperfectae*, que son aquellas que no han establecido ninguna *sanctio*.

Por una constitución de Teodosio y Valentiniano se dispuso que todos los actos realizados contra lo dispuesto en una ley "no sólo se los tenga por nulos (*inutilia*), sino también por no hechos (*pro infectis*"); C.1.14.5, año 439. Siendo así, todas las leyes son, desde esta disposición, *perfectae*.

§ 37. *Importancia relativa de las leyes en el ius privatum*. Pese a que en la enumeración de las fuentes del *ius*, la *lex* aparece en primer lugar, debemos aclarar que la mayoría de ellas tratan más bien de temas del *ius publicum*. En cambio, son solamente muy pocas aquellas que se ocupan de temas del *ius privatum* (generalmente votadas en los comicios tribados). Ello sucede cuando la causa motivante

de la *lex* respectiva llevaba a tener que adoptar una solución política. Así, cuando se trataba de algún problema cuya gravedad social superaba la labor propia de la *iurisprudentia*, y que, por sus repercusiones, provocaba la intervención legislativa de los magistrados.

1. Es por ello que existen zonas muy vastas del *ius privatum*, tales como lo vinculado con el matrimonio, la familia, los contratos y demás negocios, el dominio y los *in iura in re aliena*, etc., que no serán sino esporádicamente motivo de tratamiento legislativo. Una cuestión esencial, como la edad para alcanzar la capacidad de hecho, la pubertad, será motivo de discusiones entre las escuelas, y recién con Justiniano habrá una decisión legislativa.

2. La *lex* tiene, pues, un campo de aplicación limitado en lo que atañe al *ius privatum*. No se puede hablar de un "ordenamiento legal". Lo más que podemos admitir es que existen ciertas y determinadas *leges* que de alguna manera han dicho algo en ese campo. Hablando en términos actuales, más que señalar la existencia de "lagunas", es decir, sectores jurídicos no legislados, para ser precisos tendríamos, al revés, que hablar de "islas", o sea, de algunas pocas y escasas materias legisladas, en medio de la vasta superficie del "mar" de lo no legislado.

3. A las *leges* no se les puede aplicar la terminología actual de "normas". La palabra *norma* (escuadra) sólo aparece aplicada en la legislación del siglo IV d.C., en forma muy específica para reglamentaciones fiscales.

§ 38. *Los plebiscitos*. La palabra "plebiscito" se conforma a partir de *plebs* (plebe) y de *scitum* (decidido). La definición dada por Gayo (1.3) es equivalente a la empleada para la *lex*: "Plebiscito es lo que la plebe ordena y establece". En este caso, el *concilium plebis* es convocado por el magistrado plebeyo, es decir, el tribuno, siguiéndose un trámite semejante que para la *lex*.

1. El problema principal estuvo representado por el valor que tenían estos plebiscitos (eran obligatorios sólo para los plebeyos o valían también para los patricios?). Parece ser que debían estar sometidos a la aprobación del Senado. Hubo al respecto dos leyes, la *Valeria Horatiana* (año 448 a.C.) y la *Publia Philonis* (año 338 a.C.), relacionadas con este tema del requisito de la aprobación (quizá primero posterior, y luego, por la segunda anterior). Pero finalmente el problema quedó zanjado con la *lex Hortensia* (año 288-285 a.C., quizá 286), que eliminó la pesadumbre de la *auctoritas patrum*, quedando entonces los plebiscitos equiparados a las *leges*. Por ello, los que conocemos tienen la denominación de *lex*. La posibilidad de los *comitia tributa* tornó obsoleta esta fuente de producción jurídica.

II. Derecho romano clásico.

§ 39. Este período, que hemos establecido en tres etapas (130 a.C.-230 d.C.), es indudablemente el de mayor florecimiento del *ius*. Durante él se constituyó la verdadera ciencia jurídica romana, gracias a la labor de los grandes juristas-consultos. Éstos fueron los que encontraron soluciones técnicas sumamente adecuadas a la realidad socio-económica de la Roma de ese entonces. Significó una superación neta del viejo *ius civile* de la época quiritaria, que sólo interesa desde un punto de vista histórico, y en la medida que siguió perviviendo en algunas cuestiones de este derecho clásico. A su vez, el derecho posclásico no puede ser comprendido sino como una alteración y en algunos casos innovación de las soluciones clásicas.

(A) Comienzos del período del derecho clásico.

§ 40. Desde el año 387 a.C. se había creado la magistratura del *praetor*, pero alrededor del 242 a.C.—debido a la expansión de Roma a Italia— se creó la magistratura del *praetor peregrinus*, que se debía ocupar de los problemas jurídicos existentes entre extranjeros y entre éstos y los ciudadanos romanos, utilizando el *ius gentium*. Se deja subsistente al otro pretor, llamado ahora *praetor urbanus*, encargado fundamentalmente de las cuestiones entre romanos, en las que se aplicaba el *ius civile*.

Un momento muy importante fue la sanción de la *lex Aebutia*, que permitió el procedimiento de las fórmulas escritas ("procedimiento formulario"). Esta ley, de fecha desconocida, era de mediados del siglo II a.C. Aunque tuvo que haber sido sancionada antes del 130 a.C., por las razones dadas, hemos seguido el criterio de fijar este año para señalar el comienzo de este derecho clásico (para algunos "derecho preclásico").

§ 41. *El edicto de los magistrados*. En general, los magistrados con *imperium* gozan también del *ius edicendi*, es decir, de la posibilidad de dirigirse en forma general al *populus*, ya sea por palabra o por escrito. Se dice entonces que el magistrado da su *edictum*.

Acá interesarán fundamentalmente los "edictos" de aquellos magistrados que tienen que ver con la administración de justicia. Éstos son: el pretor—urbano y peregrino—, los ediles curules, que se ocupaban de la regulación de los mercados; y en las provincias, los gobernadores y los cuestores.

§ 42. *Clases de edictos*. Cada pretor, al comienzo de su magistratura, publica su *edictum* en las tablas del *album*, librándolo al conocimiento general. En él figuran las fórmulas de las acciones que con-

cederá a los litigantes, así como otras medidas especiales: decretos, interdictos, etc.

El edicto expira el día en que cesa la magistratura de quien lo dictó; de ahí su denominación de *lex annua*, y más concretamente de *edictum perpetuum*, si bien duraba solamente ese año. El pretor siguiente no estaba obligado a adoptar el mismo edicto. Pero el uso habitual fue el de renovar su vigencia (si así se hacía se lo llamaba *edictum traslativum*; aunque podía agregarle nuevas proposiciones (*pars nova*) a lo que ya existía (*pars traslativa*). De todos modos, la *iurisdictio* del pretor no se agota con la decisión inicial, ya que ante cualquier caso concreto que se le presentaba podía amparar al litigante mediante el dictado de una solución concreta nueva, es decir, un *edictum repentinum*.

§ 43. Importancia del edicto del pretor.

Con la aparición del procedimiento formulario (*lex Aebutia*), el pretor pudo manejar más libremente su *iurisdictio* (el *dicere* = decir, pero en el sentido fuerte de "crear" el *ius*). Si bien no puede modificarse directamente el *ius civile*, respecto del cual corresponde, sin embargo, su *interpretatio*, el pretor comienza a introducir innovaciones, que funcionan como *ius praetorium*. Mediante esta nueva clase de *ius* (llamado también *ius honorarium*), los pretores podían, "por causa de utilidad pública", a veces "ayudar" (*adiuvandi causa*) al *ius civile*, pero también "suplirlo" (*supplendi causa*), y más aún "corregirlo" (*corrighendi causa*); Pap., D.1.1.7.1.

1. De este modo, no se consideraba que el pretor derogaba al *ius civile*, sino que más bien lo afinaba en su aplicación concreta. Por eso, este *ius honorarium* es considerado por Marciano como *viva vox iuris civilis* (D.1.1.8). Esto significaba que al lado del *ius civile*, que seguía marcando la aplicación de la *iustitia* (en el viejo sentido de apego a las reglas fijas y rituales), funcionaba armoniosamente este nuevo *ius praetorium*, que se basaba en la *aequitas* y que permitía la producción de soluciones de justicia mejores. El edicto de los pretores—que normalmente requerían la ayuda de los *iurisprudentes*—sirvió para adecuar el *ius* a los distintos cambios que se producían en la sociedad romana.

2. Del mismo modo, los ediles curules, si bien en menor medida, introdujeron soluciones interesantes para la vida jurídica de los mercados (así, a propósito de los vicios *redhibitorios*; D.21.1). También en las provincias, los gobernadores y los cuestores (en las provincias senatoriales) dictaban edictos que conformaron luego el "Edicto Provincial", comentado por Gayo y por Ulpiano.

§ 44. *Los responsa prudentium*. En la medida en que se laicizó el *ius*, sacándolo de la *interpretatio* de los Pontífices, comenzaron a apa-

recer aquellos que por mérito propio se dedicaban al conocimiento de soluciones de justicia, manejando la *prudentia* en los asuntos jurídicos. Por ello son denominados *prudentes* o también *iurisprudentes*.

El *prudens* era consultado por los particulares en cada caso específico y emitía su *responsum* (respuesta). A su vez, con el advenimiento del proceso formulario, los pretores, que en general cumplían una función en el *cursus honorum* político, se fueron acostumbrando a recurrir a estos *iurisprudentes*.

De este modo, la *interpretatio prudentium* fue de uso común, tal como lo reconocen Cicerón (Top., 5.28), Pomponio (D.1.2.2.12) y Papiniano (D.1.1.7). En los tiempos de Cicerón (*pro Caec.* 23), si bien el magistrado no aparece como obligado, lo común era que se adhiriera a lo aconsejado por estos entendidos, salvo que se presentara una opinión contraria, en cuyo caso optaba por el criterio que considerara oportuno.

§ 45. *Labor de los iurisprudentes*. 1. En cuanto a la actividad de los *iurisprudentes*, abarcaba aspectos más amplios que las respuestas dadas a las consultas del pretor, o del *iudex*, o de particulares. En forma muy breve, podemos caracterizarla como consistente en:

(i) *respondere*: dar consejos, bajo forma de opiniones o sentencias, acostumbrándose a que estuvieran presentes jóvenes *auditores*, que se iban formando jurídicamente;

(ii) *cavere* (prever): consistía en redactar cláusulas que se incorporarían a los negocios jurídicos, asistiendo a los interesados y aconsejándolos en la importancia práctica de las palabras, giros y tecnicismos jurídicos que se empleaban; y

(iii) *agere* (obrar): era la tarea de guiar a los litigantes y a sus defensores (*oratores*), quienes eran los que efectivamente abogaban por las partes.

2. La labor de los *iurisprudentes* era honoraria, por lo menos en un principio. Tuvieron un amplio reconocimiento público por parte de los romanos. Según Cicerón, el domicilio de los *prudentes* era *sine dubio* el de un "oráculo de la ciudad" (*oraculum civitatis*; de orat. 1.45.200). Pomponio habla de ellos como que "fueron de máxima estimación (*dignitas*) para el *populus Romanus*" (D.1.2.2.35). Su *sapientia* es considerada por Ulpiano como *res sanctissima* (D.50.13.1.5).

§ 46. *Primeros juristas*. Entre los primeros juristas debemos mencionar, continuando la labor iniciada por Tiberio Coruncanio y por Sexto Aelio Peto, a Marco Porcio Cato (muerto en el 152, siendo pretor), hijo de Catón el Censor, y a los tres que se consideran los "fundadores": Marco Manilio (cónsul en el 149), Marco Junio Bruto (hijo del cónsul del 147) y Publio Mucio

Scévola. Este último, cónsul en el 133, pertenece a una familia que dio otros juristas célebres como su primo, *Quinto Mucio Scévola*, el Augur (cónsul en el 117) y su propio hijo, *Quinto Mucio Scévola*, el Pontífice (cónsul en el 95). A este último se debe la primera exposición ordenada del *ius civile*, en una obra de 18 libros, donde se aprecia la influencia retórica helenística.

En una etapa siguiente aparecieron dos grandes nombres: *Cayo Aquilio Galo* (pretor en el 66) y *Servio Sulpicio Rufo* (cónsul en el 51); con este último se fortalece la costumbre de formar discípulos, constituyéndose en el fundador de la "escuela Serviana". Precisamente uno de sus grandes adeptos fue *Alfeno Varo* (cónsul en el 39), autor de una obra en 40 libros, llamada *Digesta*, conteniendo *responsa* a casos prácticos (*quaestiones*).

1. La labor de estos juristas se basa fundamentalmente, como ocurrirá con sus continuadores célebres del período clásico central, no en comentar textos legales, sino en analizar cada uno de los casos concretos que se le presentaban. Sus *responsa* descansan en su propia *auctoritas* o en la de otro jurista anterior. Lejos de mostrarse presuntuosos, se expresan en términos muy prudentes: *intelligi* (se entiende), *videri* (se ve), *contineri* (se comprende), o *esse placuit* (place ser) o *est probabilis* (es probable). La opinión dada será mantenida siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias del caso.

2. No obstante que se habla de influencias filosóficas, sobre todo helenísticas (Platón, Aristóteles y la escuela estoica), no existió propiamente una "filosofía del Derecho". Lo que sí pudo haber existido es una influencia individualista, propia del liberalismo helenístico. A pesar de emplear muy moderadamente el método dialéctico de las "distinciones", se mostrarán muy reservados para emitir definiciones. Palabras usuales como *actio*, *dominium*, *possessio*, *obligatio*, *pignus*, *delictum*, *heres*, etc., carecen de definición, anticipando el criterio posterior de Iavoleno (D.50.17.202) de que "toda definición en el *ius civile* es peligrosa". La tarea de sistematizar todo el *ius*, una de las ideas de Cicerón (que no era un *prudens* que maneja el *ius*, sino un orador, que se empeña en la tarea de convencer a los jueces por medio de la retórica), no fue practicada. La obra de Q. Mucio Scévola, no pasa por ser sino una presentación usual de las instituciones. Incluso, aun cuando enuncian una "regla" (*regula iuris*), ella carece de validez lógico-dogmática. Como lo dirá más tarde Paulo (D.50.17.1), "tan pronto como en algo es cambiada (la "causa" o "caso") pierde su eficacia.

(B) El derecho clásico central.

§ 47. Hacia el año 30 a.C. —que hemos tomado como hito— se producen algunos acontecimientos que serán importantes en la histo-

ria del derecho clásico. Por un lado, la formación del nuevo sistema político del Principado; por el otro, el afianzamiento ya obligatorio del procedimiento formulario, permitido por la *lex Aebutia*, pero ahora tornado obligatorio por Octavio Augusto (*leges Iuliae de iudiciis*; año 17 a.C.).

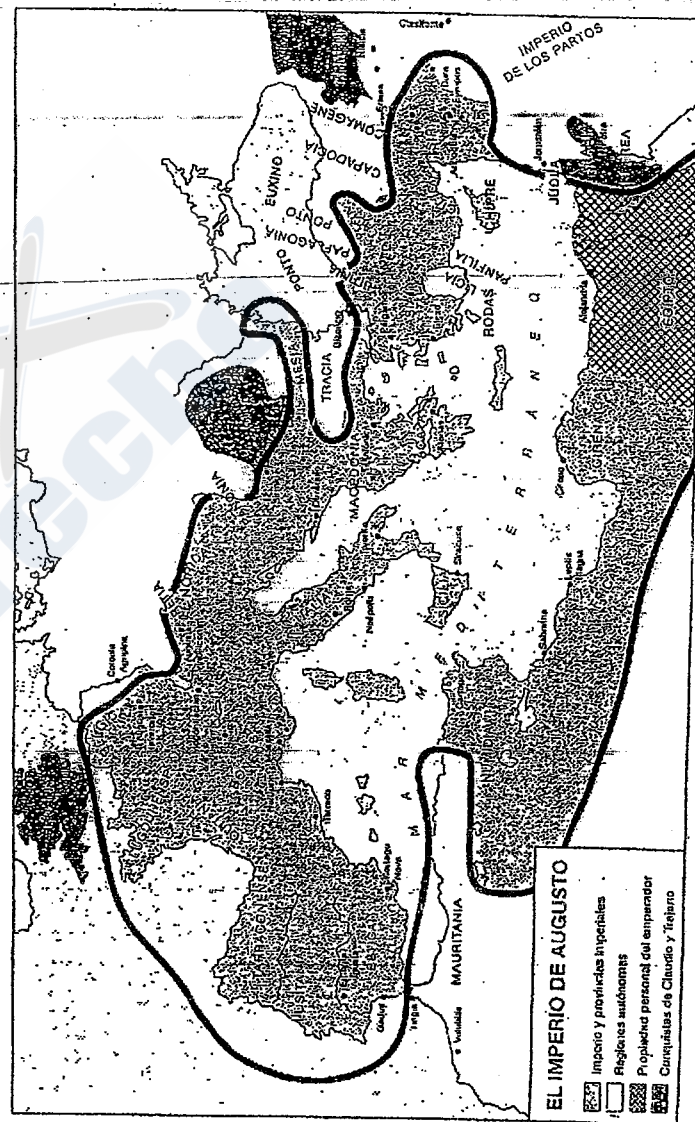
1. Las fuentes del *ius* para los comienzos de esta nueva etapa del "Derecho Clásico", serán fundamentalmente los edictos de los pretores y otros magistrados, así como los *responsa prudentium*. Igualmente, como fuentes autoritarias, durante cierto tiempo continuarán las *leges*, a las que se unirán en una primera época los "senadoconsultos" y más tarde las "constituciones del Príncipe" (o "constituciones imperiales").

2. A comienzos del Principado se continuaron votando leyes en los comicios (así, entre otras, la *lex Aelia Sentia*, la *lex Fufia Caninia*, etc.). Estas continuaron aprobándose hasta la época de Claudio.

3. En cuanto a los "senadoconsultos", la denominación ya existía en la época republicana, puesto que la opinión de este cuerpo político ante la consulta de un magistrado, recibía el nombre de *senatusconsultum*. La característica distinta consistía en que se empleaba la consulta al Senado, aprovechándose del peso de su *auctoritas* para darle fuerza de ley. De este modo se reemplazó la convocatoria de los comicios por la reunión del Senado. Por ello, Pomponio señala cómo el Senado aparece como órgano legislador en lugar del *populus*, de tal modo que lo decidido por este organismo es llamado *senatusconsultum* (D.1.2.9). Tácito (*Ann.*, 1.15) menciona que "por primera vez —en la época de Tiberio— los comicios pasaron del Campo de Marte al Senado". Pero ya con Octavio se practicó esta forma, por lo menos en materia criminal.

§ 48. Los *senadoconsultos*. Según Gayo (1.4) el "senadoconsulto" es definido como "lo que el Senado ordena y establece". Los verbos empleados son los mismos utilizados para definir la *lex* y el *plebiscitum*. Al igual que en ellos, no se trata acá de una labor autónoma del Senado. Los *senatusconsulta* se realizaban a propuesta del *Princeps*. Precisamente en tal carácter, como líder del Senado, pronunciaba —o enviaba a un delegado suyo para leerla— una *oratio* (discurso). Guardaba con ello, en lo formal, un respeto por el Senado, mostrando cómo se conservaban las costumbres republicanas. Pero en lo sustancial el Senado se mostraba sumamente complaciente para con los requerimientos imperiales.

Ya para la época de Hadriano, el texto del s.c. era directamente la *oratio*, siendo aprobada, no ya con una votación estricta, sino mediante la *acclamatio*, los senadores prorrumpan en una



"aclamación" aplaudiendo la medida propuesta por el César. Todo esto adquirió una forma impresionante de adulación reglamentada, lo que contribuyó a su desprestigio, pasándose a sincerar, posteriormente, la forma empleada medianamente la voluntad del Emperador expresada bajo la forma de "constituciones del Príncipe".

1. La denominación del s.c. se solía hacer con el nombre del emperador proponente (p.ej., s.c. *Claudianum*, s.c. *Vespasianum*); otras veces, con el nombre de uno de los cónsules que gobernaba en ese momento (p.ej., s.c. *Trebellianum*, siendo Trebelio Máximo y Anneo Séneca, cónsules).

2. Gayo (I.4) nos dice que el s.c. tiene "fuerza de ley", aunque expresa que esto estaba discutido por algunos. Pero ya en la época de Ulpiano (D.1.3.9): "no se duda que el Senado pueda hacer *ius*".

3. Poco a poco esta fuente irá desapareciendo. Los últimos s.c. mencionados son uno de Alejandro Severo (año 228; D.11.4.1.2, sobre esclavos fugitivos) y otro de Gordiano (año 239; C.2.11.15, sobre disolución del luto legal de las viudas).

§ 49. *Los responsa prudentium*. El *ius publice respondendi*. La fuente jurídica más importante estuvo constituida por la labor de los *iusprudentes*. Sin embargo, una medida tomada por Octavio vino a introducir un elemento alterador de la labor de los *iusprudentes*.

En cierto modo, absorbió la potestad de efectuar *responsa* en su propia persona, pero la delegó en los *iusprudentes*, a quienes les concedió el poder de responder en nombre de su *auctoritas*. Esto se llamó el *ius publice respondendi ex auctoritate Principis*. Según lo dice Pomponio (D.1.2.2.48-50), fue Tiberio quien organizó este sistema, y pese a reconocer el precedente de Augusto, expresa que fue Tiberio el primero que concedió dicho favor al jurista Masurio Sabino.

1. El texto de Pomponio no es muy claro: "El Divino Augusto fue el primero que para que fuese mayor la *auctoritas* del *ius*, determinó que se contestara *ex auctoritate* suya". Podría ser que más que conceder este beneficio a alguien en particular, en ciertos casos, el César agregaba el peso de su *auctoritas* a la respuesta del jurista consultado. De ahí que el texto debía venir firmado y sellado (*signatum*), pareciendo más que probable que se le uniera el sello imperial, para asegurar la procedencia auténtica. El uso no debió ser, en principio, muy frecuente.

2. Pero Octavio —quien gustaba centralizar todo el poder— controlaba en forma personal cada caso, tarea que se volvió muy pesada. Por ello Tiberio resuelve conceder el *ius publice respondendi ex auc-*

toritate Principis como beneficio personal a determinados juristas, comenzando por Masurio Sabino. La obligatoriedad para el pretor no debió haber sido estricta, pero de hecho los magistrados debían sentirse inclinados a aceptar los criterios propuestos por aquellos en quienes el emperador había depositado su confianza y otorgado el calor oficial.

3. Con posterioridad, tanto Claudio como Calígula se mostraron como queriendo reservarse el derecho de los *responsa*, tarea casi imposible de asumir por parte de estos emperadores. Luego de ellos se volvió al sistema anterior.

4. *Reformas de Adriano*. a) Por un lado permitió que cualquiera pudiera responder a una consulta jurídica, siempre y cuando se sintiera con confianza para ello. En tal sentido interpretó la palabra *publice* como que cualquiera del *populus* podía efectuar *responsa* (Pomp., D.1.2.2.49). Pero a algunos les debió haber concedido el favor especial. En un párrafo muy discutido de Gayo (I.7) se habla de aquellos "a quienes se les ha permitido fundar derecho" (*permissio iura condere*), de tal modo que si al magistrado se le presentaban respuestas concordantes por parte de estos juristas, era obligatoria para él ("obtiene fuerza de ley"), pero si se presentaba una discordante, entonces el magistrado era libre de seguir una u otra opinión. Y esto lo atribuye a un rescripto de Adriano.

b) Pero, por el otro lado, este emperador creará un *Consilium* de juristas, que obrará como tribunal de casación de la jurisprudencia. Los juristas integrantes de este *Consilium* son pagados, con lo cual se llega a una burocratización de la labor interpretativa. Esta tarea centralizadora marcha de acuerdo con la otra gran determinación de Adriano, de ordenar confeccionar el Edicto Perpetuo. Por ello, los juristas del *Consilium* tendrán la tarea de interpretar y producir las modificaciones al Edicto cuando mediaba una consulta por parte de los magistrados, dándosele autoridad imperial por la vía de los rescriptos.

5. El último *iusprudente* a quien se concedió el *ius publice respondendi* parece haber sido un tal Inocencio, contemporáneo de Diocleciano. La abolición definitiva parece haber ocurrido con Constantino.

§ 50. *Los iurisconsultos de esta época*. La tarea de los *iusprudentes*, pese a las dificultades creadas por el *ius publice respondendi*, no sólo continuó la tradición de los grandes *iusprudentes* de la época republicana, sino que se mostraron como técnicos eficaces en soluciones ocurrentes y felices que dieron gran brillo al conocimiento del *ius*. Asimismo se dedicaron a la tarea pedagógica, formando discípulos. Durante el siglo I y parte del siguiente, se conformaron dos escuelas: la de los *Proculyanos* y la de los *Sabinianos*.

Escuela Proculyana.

1. El primer gran jurista de comienzos del Principado fue Marco Antistio Labeo (48 a.C.-10-13 d.C.).

Su padre pertenecía al círculo de Bruto, uno de los asesinos de César. Fue discípulo de Trebacio y ejerció el oficio de *iurisprens* con toda dignidad. Desde el punto de vista político mantenía su acendrada prosapia republicana (fue pretor, pero rechazó el consulado), manteniéndose apartado de Octavio. Se dedicó a formar discípulos, que son quienes conformaron la escuela Proculiana.

2. Entre éstos cabe mencionar a los dos *Nerva* (padre e hijo) y a *Próculo* (que dará su nombre a la escuela), todos de la época de Tiberio; y luego a *Pegaso*, de la época de Vespasiano (69-79), a los dos *Caiso*, padre (de la época de Domiciano, años 81-96) e hijo (de la época de Trajano, años 98-117), y finalmente a *Neracio Prisco*, ya de la época de Adriano.

Escuela Sabiniana.

1. Contemporáneo de Labeo fue *Atio Capito*, quien se movió al calor de los favores imperiales, sobre todo de Tiberio. No tiene la importancia jurídica que tuvo Labeo, ni tampoco fue él quien creó una verdadera escuela. Pero por oposición a la escuela de Labeo, que en realidad no tuvo en principio un nombre, ya que la denominación de Proculiana parece ser posterior, aparece como el primero de los juristas oficialistas, al igual que Masurio Sabino, que dará su nombre a la escuela Sabiniana.

2. Precisamente *Masurio Sabino* fue el primer gran autor de esta Escuela. De origen humilde, tuvo siempre escasez de recursos. Tuvo que ser ayudado por sus discípulos, pudiendo alcanzar el rango de caballero en el censo cuando tenía 50 años. Escribió muchas obras, entre las cuales las que le dieron más fama fueron sus tres libros sobre el *ius civile*.

3. *Cayo Cassio Longino* (cónsul en el 30 d.C.) fue discípulo de Masurio Sabino. Provenía de una familia ilustre. Era descendiente del Cassio asesino de César, y al mismo tiempo, por parte de madre, del gran jurista republicano Servio Sulpicio Rufo. Tuvo gran prestigio público, y ello hasta tal punto que esta Escuela suele ser mencionada también como Cassiana.

4. Otros juristas de esta Escuela fueron *Celso Sabino* (de la época de Vespasiano) y *Iavoleno Prisco* (de la época de Nerva). Y sobre todo *Salvio Juliano*, que fue el otro gran jurista del nivel de Labeo. Nacido en Hadrumentum, África, hacia el año 100 fue cónsul en dos oportunidades y gobernador de la Germania inferior. Integró el *Consilium* de Adriano, y luego de Antonino Pío y Marco Aurelio. Igualmente fue el redactor del Edicto Perpetuo y de una obra *Digesta* (90 libros) que contiene respuestas y resoluciones que demuestran su gran sapiencia jurídica. Tuvo un buen discípulo en *Sexto Cecilio Africano*.

5. Un nombre muy especial es el de *Gayo*. En realidad, no fue un *iurisprens*, ya que no se le conoce ningún *responsum*. Fue en cambio un maestro, enseñante del Derecho. Vivió bajo Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Es el autor de sus célebres Institutas, obra didáctica en la cual con

suma sencillez y sin faltarle elegancia, trata de las instituciones de la época clásica. Esta obra gozó de gran predicamento por parte de quienes se iniciaban en el conocimiento del *ius*, y ello hasta tal punto que las Institutas de Justiniano tomarán a las de Gayo como modelo.

(C) La última etapa de la época Clásica.

§ 51. *Características*. Desde el gobierno de Adriano comienza un giro francamente centralizante y burocrático de la labor jurídica. Este efecto nuevo surge de las dos medidas tomadas, una la de crear el Edicto Perpetuo, y la otra, la creación del *Consilium* de juristas.

1. *Edicto Perpetuo*. Adriano encomendó al jurista *Salvio Juliano* la codificación ordenada del edicto de los pretores, obra que se conoce como el *Edictum Perpetuum*, reconstruido hoy día por el monumental trabajo de Lenel. Este Edicto se tornó obligatorio, de tal modo que los pretores y jueces debían seguir única y exclusivamente sus prescripciones. Para darle obligatoriedad, lo presentó al Senado, quien lo aprobó bajo la forma de senadoconsulto. En él se expresa que "si algo no se encontraba consignado en el Edicto, pudiera resolverlo una *nova auctoritas*, según las reglas, conjeturas y analogías de aquí" (C.1.17.18). El mismo *Salvio Juliano* (D.1.3.11) estableció que en caso de duda o laguna del Edicto, se remediara el problema *via interpretatio* o por una *constitutio optimi Principis*.

2. Se ve así como la sanción del Edicto Perpetuo está plenamente vinculada con la creación del *Consilium*. Los magistrados estaban obligados a hacer observar el Edicto, pero ante un caso de duda en cuanto a la aplicación, o propuesta de reformas, la consulta debía ser hecha ante el Príncipe mediante un escrito (*libellus*). La Secretaría de la Cancillería imperial pasaba la cuestión a los juristas del *Consilium*, y la respuesta adquiría fuerza obligatoria por medio del *rescriptum* dictado por el emperador.

§ 52. *Constitutiones Principis (Constitutiones imperiales)*. De este modo surge una nueva forma de legislación, que será conocida más tarde con el nombre de "constituciones imperiales". Ulpiano nos define la *constitutio principis* de este modo: "Aquello que le gustó admitir al Príncipe, tiene fuerza de ley" (*Quod principi placuit, legis habet vigorem*).

Las formas que podía tener una constitución imperial eran variadas:

a) Podía ser un *edictum*, o sea, una disposición de carácter general a todos los habitantes del Imperio, o de alguna provincia.

b) O un *rescriptum*, tal cual vimos que se aplicó con cierta profusión a partir de Adriano. Consistía en la respuesta dada a una consulta de un magistrado o de un particular.

c) O un *decretum*, o sea, una resolución judicial del emperador en un juicio, ya por grado originario o por apelación. Si bien tiene sólo valor para el caso planteado, sirve, al igual que los *rescripta*, para casos similares.

d) A ellos podemos agregar los *mandata*, o sea, órdenes dadas a magistrados provinciales.

1. Esta nueva forma de legislar, llamada vulgarmente *constitutiones* (Ulp., D.1.4.1.1), es diferenciada de la *lex*; por eso no se dice que son *leges*, sino que tienen "fuerza de ley". Su fuente radica en que este poder legisferante le nace al emperador desde el momento en que le es concedido el *imperium*; Gayo, I.5; Ulp., D.1.4.1. Ya en la última época posclásica son denominadas directamente *leges*.

Por el otro lado, estas disposiciones, principalmente los *rescripta*, tendrán suma importancia en su aplicación al nuevo procedimiento cognitorio (o *extra ordinem*) que significará la desaparición de la figura del pretor.

§ 53 Los grandes juristas de esta época.

Después de *Salvio Juliano* prácticamente desaparece la división de las escuelas. Ello se pudo haber debido al gran prestigio de este autor, que zanjó viejas cuestiones y además al hecho de ir perdiendo la vigencia del *ius publice respondendi*. Los juristas de esta época aparecen vinculados al *Consilium*, luciendo como funcionarios de la Cancillería Imperial.

En tal carácter continuaron, sin embargo, siendo clásicos en cuanto al método y a las soluciones. Pero a diferencia de sus antecesores, tienen un cierto gusto por apreciar al *ius* de una manera más general. Así, aparecen los grandes comentarios que se realizan ya a la obra de *Masurio Sabino* (*ad Sabinum*), o ya al Edicto Perpetuo o Provincial (*ad Edictum*), como también obras de Instituciones, de carácter pedagógico. Hay en los autores una cierta inclinación, luego muy del gusto de los bizantinos, por establecer ciertas generalizaciones (*regulae, definitiones*, etc.). Nos encontramos aquí con juristas muy reconocidos y apreciados, tales como *Pomponio*, *Marcelo*, *Cervidio Scévola*, *Papiniano*, *Ulpiano*, *Paulo*, *Marciano* y *Modestino*.

• *Pomponio*, contemporáneo de *Salvio Juliano*, aunque más joven que él. Fue el autor de una obra elemental conocida como *Enchiridion*, cuyo conocimiento es bastante complicado, ya que se depende de ciertos párrafos del Digesto. Parece haber sido escrita en dos libros, habiéndose dedicado a relatar una historia del Derecho Romano. Esta aparece en el libro I del Digesto (2.2), en párrafos lamentablemente muy interpolados. Además escribió en forma resumida comentarios *ad Edictum*, *ad Q. Mucium* y *ad Sabinum*.

• *Marcelo* fue miembro del *Consilium* bajo Antonino Pío y Marco Aurelio. Fue autor de 31 libros de su obra *Digesta*, y de un libro sobre *Responsa*, así como de un comentario de la *lex Iulia et Papia Poppaea*, y de otra sobre el Oficio de los cónsules.

• *Cervidio Scévola* fue contemporáneo y consejero de Marco Aurelio. Escribió una obra sobre *Responsa* (6 libros), otra sobre el Digesto (40 libros) y una tercera sobre *Quaestiones*. Igualmente se dedicó a temas de derecho provincial y cuestiones de familia.

• *Papiniano*, originario de Siria, fue asesor del *praefectus praetorio* en la época de Severo, y él mismo llegó a ocupar ese cargo. Esto era importante porque desde él se dominaba en esta época la administración de justicia y las cada vez más crecientes consultas jurídicas. Dentro de un estilo muy sobrio escribió sobre *Responsa* (19 libros), sobre *Quaestiones* (37 libros) y *Definitiones* (2 libros). Se lo consideró el "príncipe de la jurisprudencia". Fue condenado a muerte por Caracalla, en el año 212, por negarse a justificar el asesinato de dicho emperador a su hermano Geta. Su muerte lo rodeó de la aureola de mártir de la justicia.

• *Paulo* fue un discípulo de Scévola y trabajó como asesor de Papiniano. Es autor de numerosas obras: así, comentarios a diversas leyes, tales como la *Iulia et Papia Poppaea*, la *Fufia Caninia*, etc. También sus Comentarios al Edicto (80 libros), sus Comentarios *ad Sabinum* (16 libros), etc.

• *Ulpiano*, nacido en Tiro, Fenicia, trabajó con *Paulo*, ambos como asesores de Papiniano. Fue un autor muy prolífico. *Ad Edictum* (83 libros), no sólo respecto del Edicto del Pretor Urbano, sino también, en los últimos dos libros, sobre el Edicto de los Ediles Curules; un comentario *Ad legem Aquilianam*, otros *Ad legem Aeliam Sentiam*, *Ad legem Iuliam de adulteriis* y muchos otros más. Será el jurista más citado en el Digesto de Justiniano. En sus últimos años fue *praefectus praetorio*, pero habiéndose dedicado a la política, murió asesinado en el año 228 por los pretorianos.

Tanto *Paulo* como *Ulpiano* fueron juristas muy significativos, pero inferiores en cuanto a la creación jurídica a *Salvio Juliano* y a *Papiniano*. Su importancia mayor fue la recopilación y ordenamiento de todo el gran material clásico. *Paulo* se manifestó más independiente que *Ulpiano*; a diferencia de éste, dedicado más bien a los amplios comentarios, *Paulo* escribió, al estilo clásico central, obras sobre *quaestiones* y *responsa*. Y ya desde éstos, la jurisprudencia posterior fue de figuras menores, entre los cuales debemos recordar a *Marciano* y a *Modestino*.

• *Marciano* fue de la época de Septimio Severo. Escribió unas Institutas, inacabada, y que servía como preámbulo a otra obra cuya, los *Digesta*.

• *Modestino* también de esta época (se desempeñó como *praefectus vigilum* entre el 228 y el 244), fue un autor prolífico. Con él se cierra el período de grandes juristas clásicos.

III. El derecho romano posclásico.

§ 54. Con el advenimiento de Diocleciano (284-305) y con su continuador Constantino (306-337) el gobierno de Roma fue ya el de una monarquía absoluta. Sin embargo, si bien históricamente se suele situar con él el comienzo del Dominado, hay que reconocer que ya desde la dinastía de los Severos (192-244) se había abandonado la fachada republicana que tan puntillosamente había elaborado Octavio Augusto.

En cuanto a lo jurídico, asistimos a una declinación de la jurisprudencia, por lo menos tal como había existido en los tiempos clásicos. Esto se produjo ya desde mediados del siglo III. Por un lado, los juristas aparecen totalmente burocratizados, pasando a ser funcionarios *ad gustum Domini*, debiendo acatar, en forma casi servil, las intenciones del Emperador. Por el otro, la costumbre de los rescriptos como medio de evacuar las consultas, ya desde la época de los Severos, fue de tal importancia que terminó ahogando la libre iniciativa de los juristas. De este modo se perdió la lozanía y la energía espiritual en la ciencia jurídica, que pasó a manos de juristas, la mayoría desconocidos y anónimos.

El Emperador —se ha perdido ya la designación de *Princeps*— Diocleciano será designado como *dominus iustitiae aequitatisque rector* ("señor de las leyes, rector de la justicia y de la equidad").

No cabe entonces sorprenderse, por tanto, que *el ius* (es decir, su interpretación por parte de los *responsa*) es asumido ahora por los *rescripta*, al mismo tiempo que su voluntad autoritativa se manifiesta en las ahora decididamente llamadas "constituciones imperiales", y en términos más generales *leges*.

1. Los juristas vivirán del "legado clásico". Con espíritu nuevo, sobre todo por la influencia de la gramática y de la retórica, tratarán de lograr la comprensión de los juristas clásicos, pero desde un enfoque *dogmático*.

2. Se componen obras elementales que circulan bajo el nombre de autores clásicos. Así, se da forma a una obra atribuida a Paulo denominada *Sententiarum et filium libri V* (Sentencia al hijo, en cinco libros). Igualmente, atribuida a Ulpiano aparecen las "Reglas de Ulpiano" o *Epitome Ulpiani*. Y finalmente, también una obra atribuida a Gayo, pero lo más probable de autor desconocido, llamada *Res cottidianae* (asuntos de la vida diaria), llamada también *Aurea* (Reglas de oro), que son una refundición de las Institutas de este autor. Durante mucho tiempo, se creyó que estas gran obras del período clásico, pero en realidad son reelaboraciones de ellas, donde a veces se respeta lo dicho por los autores atribuidos,

pero en otras, ya por simplificación o por interpolación, se hacen agregados que no son auténticos.

3. Otro género de obras son florilegios de extractos de autores clásicos. Los dos principales son los *Fragmenta Vaticana* (llamados así porque se conservó el manuscrito en la Biblioteca Vaticana); contiene párrafos de Papiniano, Paulo y Ulpiano. Y la *Collatio legum Mosaeicarum et Romanarum*, en la cual se hace una comparación entre la ley mosaica y los principios romanos de autores como Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y algunas constituciones imperiales. El propósito era hacer ver una cierta aproximación entre lo que se decía en la Biblia y lo que habían determinado los juristas y emperadores paganos, sobre todo ante los estudiosos, que ahora eran cristianos.

§ 55. El Derecho Vulgar. Durante el siglo IV, la ciencia jurídica, muy decadente, practicó lo que se dio en llamar el Derecho Vulgar (o Vulgarismo).

Las tendencias de la época fueron: a) por un lado una clara tendencia a la simplificación, las obras asumen el nombre de "epitomes" (resúmenes abreviados), tales como el *Epitome Gaii*, el *Epitome Ulpiani*, etc. Obras como las Institutas de Gayo lucen como demasiado complicadas y extensas, y es del gusto del Derecho Vulgar el evitar las cuestiones oscuras y ambiguas

1. Todo ello llevó al desdibujamiento de las instituciones clásicas. Con su afán de simplicidad, desaparecieron las distinciones entre propiedad, posesión, usufructo y demás *iura in re aliena*. Lo mismo ocurrirá con el cuadro de los contratos, donde todo parece resumirse en la idea de convención. La compra-venta se transformará, de contrato consensual, en contrato real, determinándose su perfeccionamiento recién con el pago del precio por la cosa vendida, etc. Todo ello complicado con el agregado de cierto derecho de costumbres vigentes en cada provincia.

2. Es de citar acá, como muestra del estudio simplificado del Vulgarismo, una obra de fines del siglo V o comienzos del VI, a la cual Cujaccio puso el nombre de *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (Consulta de un juristaconsulto antiguo). Su autor es desconocido, pero debía ser del sur de las Galias. La obra es breve y en ella se dan respuestas a casos, citando textos de Paulo y de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano.

b) Se le asignará un valor preponderante a la voluntad en la interpretación de los actos y negocios jurídicos, lo cual reconoce una nota influencia de los bizantinos.

1. Ya entre los clásicos existió la cuestión del conflicto entre las palabras expresadas (*verba*) y la voluntad real (*voluntas*), tal como ocurrió en el caso

de la *causa Curiana*. Pero los clásicos no admitieron una regla dogmática sobre el predominio de las *verba* o de la *voluntas*. En cambio, ahora los juristas se inclinarán más por la segunda.

c) Una clara tendencia moralizante, a la cual no es ajeno el Cristianismo. Se busca soluciones de justicia en las cuales predomina el criterio de la *benignitas*, de la *humanitas*, del *favor libertatis*, y de la *aequitas*. Estas ideas estuvieron presentes en los clásicos, pero la novedad está ahora dada por la incidencia de las soluciones de acuerdo con el nuevo concepto de *ius*, que ahora, por la influencia dominante de las fuentes autoritativas, se inclina más a ser propiamente "derecho" (*directum*).

§ 56. Las Escuelas de Derecho. Una circunstancia que hay que destacar es el comienzo de estudios jurídicos organizados. Desde el siglo IV, aparecen escuelas donde se estudia, casi en forma universitaria, la ciencia jurídica. Hubo una escuela en Roma, y otra más importante en Berytus (la actual Beirut), a la cual se agregó en el año 425 la de Constantinopla. Lo importante que tuvieron estos estudios fue el redescubrimiento de los textos clásicos, a los cuales se les presta especial importancia.

1. Justiniano alabaré a estos tres centros de estudio (*Const. Omnem*, 5.7). Saliendo de la decadencia de los años anteriores, lograron restablecer los textos clásicos, cumpliendo un papel semejante al de la escuela de los Glosadores en la Edad Media. Ello tendrá suma importancia para la gran recopilación justiniana, que no habría podido aplicar los textos del Digesto o del Código en una cantidad tan grande.

2. Se trabajaba con los textos de los autores, muchas veces resumidos, pero siguiendo una línea interpretativa exegética, reuniendo textos paralelos y analizando las discrepancias habidas entre los autores. Lamentablemente, la obra estaba —sobre todo en Berytus y Constantinopla— en manos de griegos bizantinos. De ahí el carácter frío y falta de vida de sus análisis, precisamente todo lo contrario de la energía vital de los grandes clásicos.

3. Podemos conocer el plan de estudios, por lo menos de las dos escuelas orientales, el cual abarcaba 5 años:

(i) Los alumnos del primer año (llamados en la jerga estudiantil *dupondii*, es decir, el valor de dos monedas, algo así como "novatos"), leían seis libros: dos de ellos eran las Institutas de Gayo (sólo dos de sus libros o una edición abreviada en dos libros?), siendo los otros cuatro *libri singulares* (*de re uxoria*, *de tutelis*, *de testamentis* y *de legatis*), ignorándose sus autores.

(ii) En el segundo año, las lecturas eran sobre el Edicto, empleándose posiblemente los comentarios ad

edictum de Ulpiano; los alumnos eran denominados *edictales*.

(iii) En el tercer año, se continuaban las lecturas sobre el Edicto, a lo que se agregaba la de ocho libros de los *Responsa* de Papiniano; los alumnos eran llamados *Papinianistae*.

(iv) En el cuarto año, se leían en forma no pública, sino privada con la ayuda de profesores, los *Responsa* de Paulo. Los alumnos eran llamados *Lytae* (en latín *solutores* = "solucionadores"), porque debían solucionar cuestiones dudosas y dificultosas.

(v) Finalmente, en el quinto y último año, se estudiaban las constituciones imperiales, también en forma privada, sin lecturas públicas.

§ 57. La Ley de Citas. Uno de los grandes problemas del derecho de esta época consistió en demostrar la autenticidad de los textos jurídicos que se invocaban, ya fueran los correspondientes a las *leges*, ya las obras de los distintos juristas.

1. Así, los textos de las constituciones imperiales se llevaban en los archivos oficiales. Pero no siempre resultaban confiables. Comenzó a aparecer el uso de rescriptos falsos (C.9.22.3(2), año 227; Modest., D.48.10.33; Paulo, 1.12.1). Un problema semejante ocurría en los textos del Edicto y las obras de autores clásicos.

2. La costumbre era que la parte presentara en juicio el libro donde aparecían las constituciones (*recitatio legum*) o las citas de estos juristas. Pero, para evitar dudas había que traer otros textos para cotejar con el primer ejemplar (*collatio codicum*). Había aquí problemas de copiado, y también de agregado de notas, que se atribuían a otros autores. Todo esto tornaba muy confuso el problema de las citas.

3. Fue necesaria la intervención imperial para poner un poco de orden. Por una constitución de Constantino (C.Th. 1.4.1, año 321) se devolvió la autenticidad a los *Responsa* de Papiniano, quitándole una serie de notas atribuidas arbitrariamente a Paulo y a Ulpiano, depurando de este modo lo que había dicho Papiniano. Por otra constitución, del año 327, el mismo Constantino confirmó como válida toda la obra de Paulo, y especialmente las *Sententiae*, pese a que en realidad el texto no era el originario, sino que había sido manipulado por una mano posclásica (C.Th. 1.4.2).

§ 58. La medida más importante fue la llamada "ley de Citas", debida a Theodosio II y Valentiniano III, la cual figura en el Código Teodosiano (1.4.3; año 426).

En su redacción originaria se ordenaba a los jueces que en sus sentencias sólo se debía atender a las opiniones de un grupo restringido de juristas clásicos: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino (todos ellos *iurisprudentes*) y Gayo (que

no lo era). Eran los únicos que gozaban de *auctoritas*. Si existía alguna discrepancia, había que seguir el criterio de la mayoría. Y si había un empate de opiniones, el juez se debía inclinar por la del grupo donde estuviera Papiniano. El juez sólo era libre de seguir la opinión oportuna cuando hubiera un empate y no hubiera participado Papiniano.

Pero, en un segundo momento, según luce en la redacción definitiva que figura en el Código Theodosiano, se agregaron también las opiniones de aquellos otros juristas que estuvieron mencionadas por alguno de los cinco principales.

1. De este modo, para ganar en certeza y seguridad, el *corpus* de la jurisprudencia clásica se redujo a un *canon* más estrecho. Sólo se podía decidir por las opiniones de este pequeño grupo. El *iuris*, de esta forma, se torna obligatorio en virtud de una resolución "legal". Irónicamente, se lo denominó —con posterioridad— "Tribunal de muertos", ya que todos los juristas mencionados habían fallecido entre el siglo II y la primera parte del siglo III. Y eran ellos los que decidían el litigio.

2. El agregado de los autores citados por el grupo principal desvirtuó la medida. Debía haber existido alguna constitución posterior que quitó valor a las *notae* de Ulpiano, Paulo y Marciano a Papiniano, puesto que luego Justiniano volvió a autorizarlas (const. *Deo auctore*, 6). Esta Ley de Citas figuró en la primera edición del Código de Justiniano (año 529). Pero con la promulgación del Digesto, se tornó obsoleta, y ya no figura en el nuevo *Codex* (año 534).

§ 59. *La tarea de la codificación.* En esta época posclásica se trató de ordenar, depurar y compilar todo el material jurídico existente. Para ser completas, estas compilaciones debían comprender tanto las obras de la jurisprudencia —ahora llamados *iura*— como las constituciones imperiales —ahora denominadas *leges*—.

En cuanto a la compilación de *leges*, existieron dos obras debidas a la iniciativa privada: las compilaciones Gregoriana y Hermogeniana, y otra oficial: el Código Theodosiano.

1. La palabra "código" (*codex*) designa, ya en el siglo III, la nueva práctica de agrupar distintas páginas ensambladas, de tal modo que es de aquí que llegaremos al libro. Se reemplaza así la forma anterior de los rollos (*volumen*) y la de las tablas enredadas. Con el *codex* se tornaba más fácil el manejo de la obra y su lectura.

A) La compilación Gregoriana, llamada *corpus*, y más tarde *codex Gregorianus*, es debida a un tal Gregorio, personaje desconocido del

tiempo de Diocleciano. Contena constituciones dictadas entre los años 196 y 295.

B) La compilación Hermogeniana (el *corpus Hermogenianum*, más tarde llamado *codex Hermogenianus*), es debida a un desconocido Hermógenes, de fines del siglo III o comienzos del IV. Recoge constituciones producidas entre los años 291 y 324.

1. Ambas compilaciones, muy medidas en cuanto al tiempo, hace pensar que sus autores tuvieron acceso a los archivos oficiales por ser funcionarios imperiales.

No nos han llegado directamente a nosotros, sino que figuran citadas en obras posteriores, tales como los *Fragmenta Vaticana*, la *Collatio*, la *Consultatio* y las leyes romano-bárbaras de los visigodos y burgundios.

C) Mucho más importante fue el *Codex Theodosianus*. Se trata de una compilación ordenada por Theodosio II, efectuada en el año 438, para entrar en vigencia en Oriente desde el 1 de enero del año 439. Valentiniano III le dio vigencia para el Occidente Romano.

La comisión encargada de su redacción recibió facultades para realizar las variantes o cambios en los textos legales, de tal modo que sirvieran para ser aplicadas en la práctica de su época.

Constituían 16 libros, que contienen constituciones de Constantino y de Theodosio II (van desde el 313 al 437). En forma curiosa, salvo los libros II, III, IV, V y VIII, donde figuran constituciones relativas al derecho privado, el resto de los libros se refieren al derecho público, incluso 3 de ellos al derecho fiscal.

1. No se ha conservado ningún ejemplar del *Codex Theodosianus* en forma directa. Una parte principal se conservó en el Breviario de Alarico (506), y si Mommsen (en parte tomando el trabajo de Krüger) lo ha reconstruido, ello fue posible por cuanto Justiniano, que lo derogó (en Oriente en el 529 y en Occidente en el 554), conservó en el Código las constituciones desde Constantino, tomadas del Código Theodosiano.

2. En el *Breviarium Alarici* se agregaron otras constituciones de Theodosio y sus sucesores, posteriores al 439, a las que se conoce como *Novellae posttheodosianae*.

§ 60. *Las leyes romano-bárbaras.* Durante el siglo V, ya varias tribus germánicas estaban habitando la parte occidental del Imperio. Estos pueblos, a su modo "romanizados" y reconociendo las virtudes jurídicas de las obras romanas, demostraron sumo interés

en aplicarlas. Es por ello que se las conoció posteriormente como "leyes romano-bárbaras".

I. *Lex Romana Wisigotorum.* En el año 506, Alarico II, rey de los Visigodos, que gobernaba el Sur de las Galias y el Norte de Hispania, realizó una compilación, que abarcaba tanto algunos *iura*, como también *leges*. Se la conoce como *Lex Romana Wisigotorum* o "Breviario de Alarico".

Contiene un extracto de las compilaciones Gregoriana y Hermogeniana, y en mayor medida partes del Código Theodosiano, al que se agregaron constituciones posteriores (*Novellae Posttheodosianae*). Pero también un resumen de la obra de las Institutas de Gayo (*Epitome Gaii*), textos de las *Sententiae* de Paulo y un fragmento de Papiniano.

1. El *Breviarium Alarici* resultó muy importante para la historia jurídica occidental. Gozó de mucho favor, ya que gracias a él se podía conocer tanto las instituciones de la época clásica como posclásicas. El *Epitome* de Gayo tuvo relevancia hasta el descubrimiento del texto de las Institutas, realizado por Niebuhr en la Biblioteca de Verona (1816). Fue una de las fuentes del Derecho, no sólo en España, donde estuvo vigente hasta la publicación del *Liber iudiciorum*, en el siglo VII, sino además en Francia, Alemania e Inglaterra medievales. Luego del redescubrimiento del *Corpus Iuris Civilis* (siglo XI-XII), perdió la importancia primitiva, pero resulta siempre interesante para los investigadores.

II. *La lex Romana Burgundiorum.* Fue dada a comienzos del siglo VI, por Gondobago, rey de los burgundios, que se habían establecido en la zona de la actual Borgoña. Se aplicó tanto a su pueblo como a los romanos que habitaban el territorio.

1. Contenia constituciones de las compilaciones Gregoriana, Hermogeniana y del Código Theodosiano, así como de sus *Novelas*. También, fragmentos de las *Sententiae* de Paulo, de las Institutas de Gayo y ciertas leyes de costumbres de los burgundios.

III. *El Edictum Theodorici.* Fue dictado, luego de la caída de Roma, hacia el año 500, por el rey ostrogodo Theodorico. Este se consideró gobernador de Italia, diciendo actuar en nombre del Emperador de Oriente, y regía sobre toda la población existente en sus dominios.

1. Contenia 154 artículos, basados en general en las mismas fuentes que los otros ordenamientos romano-bárbaros —si bien fue anterior a ellos—, pero sin cita de fuentes, y recurriendo muchas veces a la paráfrasis.

§ 61. *La compilación de Justiniano.* Fue finalmente el emperador Justiniano (527-565) quien realizó la compilación definitiva, superando netamente a todas las anteriores, ya que no solamente recopiló las *leges*, sino también los *iura*. Su obra será conocida más tarde —no en su época— como *Corpus Iuris Civilis*. Esto se debió a los estudiosos posteriores de Occidente, siendo Godofredo quien le dio este nombre cuando editó la obra en el año 1583. De este modo lo contraponían al *Corpus Iuris Canonici*, donde estaba la legislación canónica eclesiástica.

1. Por medio de la constitución *Haec quae necessario* del año 528, Justiniano encargó a una comisión de 10 miembros, presidida por Juan, ex cuestor de Palacio e integrada entre otros por Triboniano, *magister officiorum*, y Teófilo, profesor de la escuela de Constantinopla, la tarea de redactar un Código, poniendo al día las compilaciones anteriores. Esto se llevó a cabo en el 529, si bien esta edición del *Codex* fue luego reemplazada por otra.

2. Luego, en el año 530, por la constitución *Deo auctore*, encomendó a Triboniano, ahora cuestor del sacro Palacio, que formara una comisión para recopilar los *iura*. Entre sus colaboradores estuvieron los profesores Teófilo, Doroteo, Cratino e Isidoro, así como Constantino, *comes sacrarum largitionum*, y 11 juristas. La tarea fue cumplida en sólo tres años, y Justiniano la puso en vigor por medio de la constitución *Tanta* para entrar a regir desde el 30 de diciembre de dicho año. Se la llamó *Digesta* (= "distribuido ordenadamente") o en griego *Pandectas* (= "libros que lo contienen todo").

3. Aún en curso esta segunda obra, le encomendó a Triboniano, a Teófilo y a Doroteo, la redacción de una obra para uso escolar. Será denominada *Institutiones* (vulgarmente *Institutas*), comenzando a regir, junto con el Digesto, por la constitución *Tanta*.

4. Con posterioridad al Código, teniendo en cuenta innovaciones legislativas producidas, entre ellas las *Quinquaginta decisiones* (50 decisiones que dirimían cuestiones doctrinarias), gracias a Triboniano, Doroteo y tres juristas más, publica una nueva edición del mismo (*Codex repetitae praelectionis*), el cual es puesto en vigencia por la constitución *Cordi novis*, para regir desde el 29 de noviembre del año 534.

5. Como la labor legislativa justiniana continuó, fue necesario compilar estas nuevas constituciones, que serán conocidas como *Novelas* (*Novellae*), si bien en vida de Justiniano, éste no las ordenó en un libro único, lo que será llevado a cabo por particulares.

§ 62. *Las interpolaciones.* A diferencia de lo que había ocurrido en la época del derecho vulgar, en Justiniano y en los bizantinos que lo acompañaron se nota un "clasicismo" pronunciado, tratando de rescatar el momento de mayor

esplendor del derecho romano. Sin embargo, estaba la necesidad de tener que adecuar los textos para su época, por cuanto debían ser aplicados por los jueces en sus sentencias. Por ello es que les otorgó a los compiladores facultades para producir alteraciones, modificaciones, sustracciones y omisiones de los textos auténticos. Estas son las conocidas "interpolaciones" (o *emblemata Triboniani*).

1. Lo que trató de realizar Justiniano es una obra que resultara coherente, evitando las contradicciones de los autores originarios, para lo cual las interpolaciones, que en la constitución *Tanta* (10) nos dice que son "muchas y grandes" (*multa et maxima*), resultaban necesarias, porque desde ahora, todo el texto compilado, incluida la interpretación de los juristas, debía ser acatada como expresión de la *auctoritas imperial*.

2. Ello no obstante, estas interpolaciones representan siempre un motivo de inquietud para el romanista, que busca ir siguiendo el itinerario de cada una de las instituciones, para descubrir los distintos momentos por los cuales fue atravesando. Ciertamente que muchas de estas alteraciones ya se habían venido produciendo durante el período pre-justiniano, lo que complica más el estudio, por cuanto hay que recurrir a establecer los estratos temporales de cómo se fue produciendo la transformación de las soluciones jurídicas.

§ 63. Considerando la unidad de su obra, de manera impresionante, sobre todo por su precisión detallista, Justiniano tomó medidas para evitar que por el camino de la interpretación se pudiera traer de nuevo incertidumbre respecto de lo dispuesto. En la constitución *Deo auctore* (12) expresa la prohibición de interpretarla: "sin que en lo sucesivo se atreva ningún jurisconsulto a aplicarle comentarios, ni a introducir confusión con su vana palabrería en el mencionado código". Lo único que permitirá será la confección de *paratitla* (lista de pasajes paralelos, *Deo auctore*, 12), o de reproducciones textuales "al pie de la letra" (*Tanta* 21, *hacit potest*). Su desvelo llega a tanto que hasta sanciona como falsarios a aquellos que contradigan esas prohibiciones (*Tanta*, 21), penando igualmente a los "libreros" que vendan esas obras de interpretación consideradas prohibidas (*Omnem*, 8).

1. De este modo, Justiniano quería lograr una total "certeza". Pero al mismo tiempo, estaba petrificando el ius. El Derecho busca siempre dar respuestas de justicia a cada solución concreta en una realidad que es siempre cambiante. El develamiento de estas soluciones de justicia exige siempre la prudente tarea de interpretar. Esta sólo florece cuando se le permite a los *iurisprudentes* sentar sus reales en forma fresca:

lozana y vigorosa. El corsé fabricado por Justiniano para no innovar era algo así como pretender detener la existencia misma de la vida social, que dentro de ciertos principios que hay que mantener, resulta siempre cambiante.

Y quien primero comprenderá esto, fue el admirado colaborador Teófilo, quien compondrá una obra llamada no "Comentario", sino *Paratitla*. En realidad es precisamente un comentario de las Institutas. Para los lectores u oyentes resultaba un elemento esclarecedor del texto justiniano, pues era una interpretación "auténtica". Así, de entre la maraña de las prohibiciones legales, la *iurisprudencia* recobraba bríos, y se instalaba nuevamente en el lugar que le correspondía.

§ 64. *El Corpus Iuris Civilis*. La obra compilatoria de Justiniano se compone de cuatro partes: el *Código* (recopilación de las *leges*), el *Digesto* (recopilación de los *iura*), las *Institutas* (manual para estudiantes) y las *Novelas* (es decir, las nuevas constituciones posteriores al Código).

1. El orden que seguimos es el de su elaboración histórica. La presentación usual en las ediciones es la siguiente: primero figuran las Institutas, luego el Digesto; en tercer lugar el Código y por último las Novelas.

I. *El Código*. Contiene las constituciones imperiales habidas desde Adriano hasta Justiniano. Muchas veces estos textos han sido interpolados.

1. Tal como lo indicamos, esta recopilación de *leges* fue el primer propósito de Justiniano. Ya en el 529 se publicó el *Codex Iustinianus*, cuyo texto no nos ha llegado a nosotros. Antes de realizar la recopilación de los *iura*, en el año 530, Justiniano solucionó el problema de las dudas doctrinales, mediante la constitución *Quinquaginta decisiones* (puesto que eran del número de 50).

Por ello, viendo que con ello, lo mismo que por otras constituciones posteriores, se alteraba el texto del Código, se llega a una nueva edición (*Codex repetitas praelectionis*), que es el que actualmente figura en las ediciones del *Corpus Iuris Civilis*. En la constitución que lo torna obligatorio (*Quod nonis*) se prohíbe invocar ante los jueces la constitución *Quinquaginta*, así como las constituciones posteriores, debiéndose estar sólo a lo que indica este nuevo Código.

El Código consta de 12 libros, los cuales están divididos en títulos. En ellos se señala al principio la materia de que se trata. Luego vienen numeradas las *leges*, cada una de las cuales contiene —por orden cronológico— una constitución imperial, con la designación del emperador

que la produjo. Cuando el texto es largo, se lo divide en párrafos, de los cuales el primero es el *principium* y luego viene el párrafo 1, 2, etc. Al final viene la indicación de la fecha de publicación.

2. Así, en el libro I, el título II lleva la rúbrica (el nombre deriva del color de la tinta roja que allí se empleaba: "De las sacrosantas iglesias, y de sus bienes y privilegios"). La primera constitución corresponde al emperador Constantino, agregándose al final que fue promulgada "en Roma, a 5 de las Nonas de Julio, bajo el segundo consulado de los Césares Crispo y Constantino" (año 321).

3. Los medievales acostumbraban citarlo empujando por la ley, luego el párrafo, y después el título y el libro. Así, en el ejemplar citado así: *Ecce habet unusquisque licentiam* (las primeras palabras de la constitución), C. de sacros. eccl. (1.2).

Otra forma posterior establecía ley I, Cod. Inst. lib. I tit. II.

Estas maneras de citar, dando prevaencia a la ley, provoca confusiones para el estudioso actual. Hoy día se prefiere citar (forma filológica) de mayor a menor, yendo del Código al libro y luego a la ley así, C. (o C.J.) 1.2.1 (año 321). Se trata de evitar los números romanos, más propicios a errores tipográficos.

II. *El Digesto* (los *Digesta* o *Pandectas*) contiene la mención de los *iura*. Es la parte más importante del *Corpus Iuris Civilis* no solamente por su extensión (cerca de 9 000 fragmentos), sino porque con su lectura tenemos la interpretación de muchos juristas de la época clásica (39, de los cuales tres son de la época republicana). Entre ellos figuran principalmente Ulpiano (aproximadamente un tercio del Digesto), Paulo, Papiniano, Gayo, Marciano, Modestino y Juliano.

En total son 50 libros —que siguen el orden del Edicto Perpetuo— divididos en títulos (salvo los libros 30, 31 y 32, donde se habla de los legados y de los fideicomisos). Figuran los fragmentos en forma personalizada, con el nombre del jurista y la mención de la obra de la cual proviene dicho párrafo.

1. Respecto de la cita de un párrafo, los medievales seguían la forma de dar preferencia a la materia. Así, D. o Dig., *finium regundorum*, 3, *quo casu opus*, lo que significa Digesto, título *finium regundorum*, fragmento 3, que comienza con las palabras *quo casu opus*.

En el caso de las citas del Digesto que efectúa Vélez Sarsfield, prefiere mencionar L.3, Tit. I, Lib. 10. Lo preferible es seguir el mismo método "filológico" ya señalado, resultando conveniente comenzar por la mención del autor: así, Gayo, D 10.1.3, evitando los números romanos.

Precediendo al Digesto, se agregó un *Index* en el

cual están señaladas las materias por orden alfabético, lo que facilita la búsqueda.

Ha llamado siempre la atención la extraordinaria rapidez con la cual los compiladores bizantinos redactaron la obra (menos de tres años). Al respecto se han mencionado varias teorías, pareciendo probable que pudieran contar con compilaciones más o menos elaboradas, aunque la existencia de un "pre-Digesto" no resulta admisible.

2. Una de las teorías fue explicitada por el romanista alemán Blühme. Según ella, los compiladores se dividieron el trabajo sobre la base de tres masas bien diferenciadas: una tenía por base los comentarios *ad Sabinum* (masa Sabiniana), otra los comentarios *ad Edictum* (masa Edictal) y la tercera los comentarios a los *Responsa* de Papiniano (masa Papiniana), amén de un Apéndice que comprenda a otros autores que no figuraban en las masas anteriores.

En cambio, los romanistas alemanes Peters y Hoffmann creen en la existencia de una obra compilatoria privada del siglo V, aunque reconociendo el método de las "masas" en la elaboración de este Pre-Digesto. En general, esta tesis no es aceptada, continuando vigente la división de materias en las "masas", lo cual explicaría algunas repeticiones, contradicciones, etc.

3. El manuscrito más antiguo que conservamos es el llamado "Pisano" (por haber estado hasta comienzos del siglo XV en Pisa) o también "Florentino" (*littera Florentina*), ya que fue trasladado y se conserva en la Biblioteca Laurentina de Florencia. Con posterioridad aparecen copias, denominadas "Vulgata".

III. *Las Institutas* (*Instituta*) o *Institutiones*. Es un libro dedicado a los estudiantes, que contiene nociones generales sobre las diferentes instituciones.

1. La fuente principalísima fueron las célebres *Institutas* de Gayo, siguiéndose el mismo método expositivo. Todo el ius aparece dividido en: personas, cosas y acciones. Se tuvieron en cuenta también las *Res cotidianae*, atribuidas a Gayo, pero se intercalan también referencias de Paulo, Ulpiano, Marciano y Florentino, aparte de citas o referencias a *leges* y a textos del Código.

2. Están divididas, como las de Gayo, en cuatro libros. La forma de citar normal es la referencia a la obra, seguida de la del libro, título y fragmento. Las otras formas anteriores, análogas a las ya mencionadas en el Código y el Digesto, se han tornado obsoletas.

IV. *Las Novelas* (*Novellae*). Si bien Justiniano dijo por terminada su labor compilatoria con la sanción de las tres partes anteriores, en la

constitución *Cordis novis* (año 534) dejó aclarado que las leyes ya establecidas en el Código podían sufrir modificaciones ulteriores, las cuales no serían agregadas a este texto, sino que figurarían como "nuevas constituciones" (*...novellarum nomine constitutionum significatur*). Estaban depositadas en los archivos imperiales. Pero Justiniano nunca las agrupó en una obra, siendo ello tarea reservada a los particulares.

1. El mismo Justiniano ordenó una promulgación parcial de estas nuevas constituciones, cuando en el año 534, tras haber reconquistado Italia, accedió a una petición del Papa Vigilio, y a fin de restaurar el derecho romano en la península, promulgó una *sancitio pragmatica*, conocida con el nombre de *Pro petitione Vigilii*, poniendo en vigor no sólo el Digesto, el Código y las Institutas, sino también las novelas publicadas hasta esa fecha.

2. La colección más antigua fue debida a un profesor de Constantinopla, llamado Juliano. Se la conoce como *Epitome Iuliani*, y abarca 124 novelas, debiendo haber sido editada hacia el 555. Era una versión abreviada de la anterior.

3. El *Authenticum* es una colección de 134 novelas (del 535 al 556). El nombre le viene de los Glosadores, que afirmaron su autenticidad, luego de haberla tenido por falsa. Luego se redujeron a 96 las propiamente "auténticas" y el resto fue considerado como "extravagantes", insertándolas en el Código e Institutas.

4. La más amplia de todas es una recopilación efectuada, en griego, bajo Tiberio II. Comprende un total de 168 novelas, casi todas de Justiniano, salvo 4 de Justino y 3 de Tiberio II. Nos ha llegado por un manuscrito de Venecia (siglo XIII) y otro de Florencia (siglo XIV). Es la que figura en las ediciones actuales del *Corpus Iuris Civilis*, agregándose como apéndice 13 edictos de Justiniano y 9 leyes "extravagantes".

§ 65 *El derecho romano en Oriente después de Justiniano*. Hay que recordar que en la Edad Media, la vigencia del derecho romano se mantuvo por espacio de 900 años después de Justiniano. Si bien en un comienzo estaban en vigencia las disposiciones prohibitivas del emperador Justiniano, se fueron realizando no sólo índices, sino también glosas y comentarios.

a) Como ya lo dijimos, Teófilo publicará, pocos meses después de haber terminado las Institutas, una *Paráfrasis* de ellas, en la cual, con un estilo llano y claro, irá más allá de la tarea de parafrasear —"decir lo mismo con otras palabras"— para realizar una verdadera glosa de dicha obra, y ello hasta tal punto que su contenido es aproximadamente tres veces más que el texto de Institutas.

b) Igualmente aparecerán índices de las Pandectas (Doroteo, Cirilo), del Código (Taleo, Anatolio,

Isidoro y Teodoro) y de las Novelas (Teodoro, Escolástico y Anastasio). Una Suma del Digesto, de autor desconocido (el Anónimo), completada por un tal Enanotifanes, aparecerá en el siglo VII.

c) En dicho siglo VII, el emperador León el Isáurico y su hijo Constantino Coprónimo, publican una *Ecloga legum* (colección selecta de leyes), tendientes a volver más comprensible la compilación justiniana.

d) Ya hacia fines del siglo IX, Basilio el Macedónico mandó hacer dos obras abreviadas del *Corpus Iuris Civilis*: el *Procheiron* y la *Epanagoge*. El problema principal de la obra justiniana era que estaba redactada en latín, lengua que ya pocos conocían en Oriente (el Imperio abarcaba Grecia, Macedonia y parte del Asia Menor), y además se tornaba complicada debido a su extensión. Por ello inició la publicación de las *Basílicas*, que no terminó, siendo completadas por su hijo León el Sabio.

En esta obra, escrita en griego, se refunde todo el texto del *Corpus Iuris Civilis*, de tal modo que en 60 libros se ordena de manera nueva y más resumida todo el material, agregando parte del Anónimo y de los índices ya mencionados.

1. Las *Basílicas* reemplazaron prácticamente la vigencia de la obra de Justiniano. Ya en el siglo X, debido quizá al emperador Constantino Porfirogeneto, se le agregaron algunos comentarios (*scholia* = escolios), que tuvieron fuerza legal. Incluso, considerándola extensa se hicieron obras abreviadas donde se extractaba el texto de las *Basílicas*. Así, aparecieron una *Synopsis Basilicorum* (siglo X), otra más breve (*Synopsis minor*) y un índice o repertorio que facilitara la búsqueda de las instituciones: el *Tipicus* (siglo XII, literalmente "donde está").

2. Otro extracto doctrinario, debido a un juez de Tesalónica, Constantino Harmenópulo, fue el *Hexablos* (porque consistía en 6 libros). Fue publicado en el siglo XIV, y aun después de la caída de Constantinopla, estuvo vigente en Grecia donde fue ley positiva desde 1835.

§ 66 *Supervivencia del derecho romano en Occidente*. La caída de Roma (año 476) no significó la desaparición del derecho romano. Los bárbaros, reconociendo la superioridad de éste respecto de sus costumbres, lo incorporaron en las leyes romano-bárbaras. La reconquista por parte de Justiniano de Italia, determinó la sanción de la constitución *Pro petitione Vigilii*, por la cual el *Corpus Iuris* se tornó de vigencia obligatoria. Muerto Justiniano, se produjo la invasión de los lombardos que se apoderaron de Italia, salvo el Exarcado de Ravena y algunas otras ciudades, que quedaron bajo el poder bizantino. Y a

pesar de la pérdida posterior de mucha parte de este territorio, hubo ciudades, tales como Nápoles, Pisa y algunas otras del Sur, que hasta el siglo VIII continuaron siendo bizantinas.

Durante esta época, los escritos que existieron de derecho romano resultaron muy fragmentarios: comentarios sobre el *Epitome Iuliani*, o sobre el Breviario de Alarico, o sobre partes determinadas del *Corpus Iuris*. Para un resurgimiento total habrá que esperar al siglo XII.

§ 67 *Escuela de los Glosadores*. A fines del siglo XI y comienzos del siglo XII, se produjo un movimiento de renovación de los estudios romanísticos, que tuvo su centro en la Universidad de Bolonia. Allí, auspiciado por la condesa Matilde, un monje profesor de gramática, llamado *Incerno*, se dedicó a estudiar el manuscrito del *Corpus Iuris* que había descubierto en la Biblioteca de Pisa (año 1094). Prontamente atrajo a una pléyade de juristas que se sintieron movidos a la lectura y al comentario de la obra de Justiniano. Fue así que se formó la *escuela de los Glosadores*.

Este nombre le vino por el método exegético empleado, que significaba un respeto total a la letra de lo escrito por los bizantinos y a la autoridad de Justiniano. A la lectura, seguía una exégesis de cada uno de los textos. Como era necesaria la explicación de cada una de las palabras importantes, realizaban una pequeña glosa, es decir, un breve comentario en el cual se ampliaba el concepto de cada palabra o bien de una frase completa. Estas glosas figuraban, ya al margen (glosa marginal), o si eran más breves, intercaladas en el propio texto (glosa interlineal).

1. En una primera etapa, los principales discípulos de Imerio fueron: *Búlgaro*, *Martino*, *Jacobo* y *Hugo*. Con un gran esfuerzo de paciencia, siguiendo siempre el método literal exegético, produjeron las primeras glosas. Más tarde se lució *Placentino*, quien se trasladó luego a la ciudad francesa de Montpellier, para fundar la primera escuela francesa de Derecho (1180), tarea en la que colaboró su discípulo *Azón* (1200). Y también *Vecario*, quien luego se trasladó a Oxford donde fundó una escuela de Derecho Romano (1144).

2. A este primer período continuó luego otra fase de asentamiento y recopilación de las distintas glosas que se habían venido escribiendo. En esta tarea, la figura indiscutible fue *Accursio* (1182-1260), autor de la *Magna Glosa* (también llamada *Glosa Accursiana*). En la edición de esta obra aparece el texto de cada una de las partes del *Corpus Iuris* (en el centro) y rodeándolo, las distintas glosas, anotaciones o comentarios que se habían venido dando, más las propias de Accursio.

§ 68 *Escuela de los Comentaristas*. En el siglo XIV apareció otra pléyade de estudiosos. Entre ellos, los nombres principales son *Bartolo de Sassoferrato*, *Baldo de Ubaldis* y *Cino da Pistoia*.

1. Estos estudiosos, conocidos como "comentadores" y también como "bartolistas", continuaron la labor de los Glosadores ("post-glosadores"). Pero el método es ahora distinto. La tarea de apego a la letra de los textos romanos, es decir, el método exegético, es reemplazado por el modelo escolástico. Se trabajan los textos pero buscando establecer generalizaciones de las materias, con ampliaciones, divisiones, subdivisiones y clasificaciones que atendieran a los problemas vigentes en su época, sirviendo a los jueces y a los estudiantes.

2. Pese a ciertas exageraciones metodológicas, los comentaristas, y entre ellos la figura eximia de Bartolo, sirvió para establecer en Europa el Derecho Romano como "Derecho Común". Por ello se consideraba que "ningún jurista era bueno, a menos que sea bartolista" (*nullus bonus jurista, nisi sit bartolista*). Un buen conocedor del Derecho de esta época, no sólo debía saber el Derecho Romano, sino además el Derecho Canónico, que estuvo recopilado en el Decreto de Graciano (*Decretum Gratiani*; siglo XII). La unión de los dos derechos formaba el *utrumque ius* (ambos derechos).

§ 69 *La escuela humanista*. Con la llegada del Renacimiento se produjo también un cambio de actitud en los estudios romanísticos. La forma de estudiar los textos, tanto de los Glosadores como de los Comentaristas, pese a las diferencias, tenía en común el respeto a la obra justiniana, a la cual se consideraba perfecta en sí misma. Esta manera de estudiar fue llamada el *mos italicus*, y frente a ella aparece otra, de carácter "culto", que fue denominada el *mos gallicus*, ya que sus principales representantes fueron juristas humanistas franceses.

1. Entre ellos descuellan Jacques Cujas (o Cujac; 1522-1590) y Hugo Doneau (o Donelo; 1527-1591). Lo que buscan en el estudio del Derecho Romano no es ya el apego a la letra de los textos, sino tratar de utilizarlos de manera más amplia, por un lado como un derecho histórico (por lo que lo une a estudios literarios, arqueológicos e históricos), y por el otro dar soluciones a los problemas de su época.

2. Ya no se apoyan en la autoridad imperial legislativa de Justiniano, sino más bien en la "razón de ser" intrínseca del Derecho Romano. Por ello se puede decir que se abandona la *ratio imperii* (la razón imperial que daba autoridad a la obra justiniana), para buscar el *imperium rationis* (el imperio de la razón de ser que tenía dicha obra).

§ 70. *La escuela del Derecho Natural.* Yendo todavía más allá, los representantes de esta escuela se alejan aún más del criterio de autoridad de los textos romanos. Estos pueden servir como mera experiencia histórica de un pueblo. Pero para ellos el Derecho es fundamentalmente un producto de la "Razón", entendida ahora como la "razón humana" que busca establecer los mejores criterios jurídicos. Por ello, si bien son llamados jusnaturalistas, no hay que confundir su noción con la del Derecho Natural clásico que provenía de la antigüedad grecorromana. La diferencia principal era la impronta racionalista con la cual trabajan. Este racionalismo, del cual son tributarios todos sus autores, trata de buscar, examinar y aceptar en los textos romanos, solamente aquello que pueda ser considerada la *ratio scripta*.

1. Este racionalismo, muy al modo cartesiano, encontró sus principales cultores en Holanda. Así, hay que destacar a Hugo Grocio (1583-1645), quien publica entre sus obras más importantes una "Introducción a la ciencia del Derecho holandés" (1641); *De mare libero* (1609), donde defiende la libertad de los mares, y *De iure belli ac pacis* (1625), las cuales serán importantes en los estudios de Derecho Internacional.

En Alemania se destacan Puffendorf (1623-1694), Christian Thomasio (1655-1728) y Christian Wolff (1679-1754).

§ 71. *La escuela histórica.* Como una reacción contra la escuela de los jusnaturalistas modernos, hacia fines del siglo XVIII surge en Alemania un movimiento nuevo: la *Escuela Histórica*. Brevemente, los autores de esta escuela conciben el Derecho; no tanto como una expresión producida por la razón humana, sino más bien como el producto vivo nacido del "espíritu del pueblo" (*Volksgeist*). Por ello descreen de reglas jurídicas permanentes, ya que es el propio espíritu popular el que las va creando. Desde este punto de vista, el estudio del Derecho Romano es ahora entendido como una expresión jurídica peculiar que estuvo vigente en Roma. Pero, yendo más allá de dicho Derecho, están atentos a las nuevas formas jurídicas que el pueblo va estableciendo. Involucrados en general dentro de una corriente evolucionista, ven que el Derecho ha conocido una infancia, una adolescencia, una juventud y una madurez. Para este último estadio es que se sienten llamados sus adeptos.

1. Esta escuela prendió especialmente en Alemania. Hay que recordar que en esa nación; a partir de 1495 se produjo la Recepción del Derecho Romano. En virtud de ella el *Corpus Iuris* era el derecho positivo, es decir, el aplicado por los jueces en

la solución de los litigios. Esto duró hasta el año 1900, en que se sancionó el Código Civil alemán (*Bürgerliches Gesetzbuch*, o en forma abreviada el B.G.B.).

2. Entre sus seguidores debemos mencionar a Gustavo Hugo (1764-1844), profesor en Göttinga, quien fue considerado su fundador. Pero la gran figura fue indudablemente Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), considerado el más célebre jurista de su época. Publicó a los 24 años un tratado sobre la posesión ("*Derecho de la posesión*"), obra que tuvo una amplia aceptación, por lo menos hasta la aparición de la polémica obra de Rudolf von Ihering: "*De la voluntad en la posesión*". Estas obras, pese a basarse en forma muy minuciosa en los textos romanos, demuestran la gran distancia del tratamiento de este instituto en los autores clásicos romanos. La posesión fue en Roma una creación pretoriana, que se buscó aplicarla casuísticamente en aquellas oportunidades en que alguien merecía ser protegido. En cambio, tanto Savigny como Ihering tratan de elaborar una "teoría general de la posesión", lo cual demuestra que eran en cierta medida tributarios del sistema racionalista, pese a la negación genérica de la Escuela Histórica hacia ese pensamiento.

3. Tuvo también mucha importancia su trabajo "*De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y ciencia del derecho*", en la cual se opone a la codificación del Derecho en Alemania, disputando contra Thibaut, que la auspiciaba.

4. Pero su obra principal fue su "*Sistema del derecho romano actual*", obra llamada a tener una importancia especial en su tiempo y aún largamente después. Fundó la "Revista para la Ciencia Histórica del Derecho", que bajo el nombre de "*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*" perdura en la actualidad.

5. Otro gran autor de esta Escuela Histórica fue el sucesor de Savigny en la cátedra de Berlín, Georg Friedrich Puchta (1798-1846), quien con su "*Manual de Pandectas*" estableció las bases de la Pandectística alemana.

§ 72. *La Pandectística alemana.* Debiendo, por las razones dadas, los juristas alemanes estudiar el Derecho Romano, que era su Derecho positivo, la Pandectística se basó en los textos justinianos, pero en su interpretación fue tributaria de todas las ideas modernistas del Iluminismo (la *Aufklärung*). La lectura y aplicación de las obras romanas se ven con ideas que no eran propiamente romanas: así, la noción obstinada del hombre como "sujeto de derecho", la visión de los "derechos subjetivos" y fundamentalmente una filosofía jurídica netamente voluntarista.

1. Entre sus principales seguidores encontramos a Vangerow (1808-1879), a Brinz (1829-1888), a Bek-

ker (1827-1916), a Dernburg (1829-1907). Y principalmente al más célebre, Bernard Windscheid (1817-1892).

2. Otro autor célebre fue Rudolf von Ihering (1818-1892), de pluma ágil y muy amena. Su obra principal fue "*El espíritu del Derecho Romano*", en la cual veía el desarrollo historicista del Derecho Romano, sin perjuicio de conceptualizaciones. Escribió obras como "*El fin en el Derecho*", "*La lucha por el Derecho*", "*Jurisprudencia en broma y en serio*", aparte de su obra sobre la posesión, etc.

Frente a la tendencia general de la Pandectística, que se expresaba por la llamada "Jurisprudencia de Conceptos" (*Begriffsjurisprudenz*), de tendencia bien racionalista, Ihering defendió la "Jurisprudencia de Intereses" (*Interessenjurisprudenz*), de orientación más sociológica, dando importancia al Derecho como "lo que es útil al pueblo".

§ 73. *Situación actual de los estudios.* En la actualidad, los estudios de Derecho Romano han continuado con renovado vigor. Si bien durante todo el siglo XIX y buena parte de los comienzos del siglo XX, los principios modernistas de la Pandectística tuvieron especial prevalencia para la lectura de los textos romanos, lentamente se ha ido conformando un "sentido crítico" que busca, como lo dice el francés Pierre Noailles, "mirar con ojos nuevos" el Derecho Romano. Por de pronto, de lo que se trata es de buscar el sentido genuino de las instituciones y de las soluciones jurídicas romanas. A diferencia de las escuelas anteriores, que partían directamente del análisis de las instituciones tal cual figuraban en su etapa última, la del *Corpus Iuris Civilis*, ahora se prefiere conocer el desarrollo histórico de las instituciones, con un sentido absolutamente integral, ubicándolas en el momento histórico respectivo, para lo cual las fuentes literarias, históricas, epigráficas y arqueológicas contribuyen de manera más que interesante.

De este modo, la preferencia de muchos estudiosos se centra en el momento del Derecho Clásico Romano, el cual, como punto intermedio, sirve al estudioso para ver cómo se superó el Derecho Romano quirritano o primitivo, y por el otro, para tener un

punto de comparación con el Derecho Postclásico, bizantino y justiniano.

El estudio del Derecho Romano resulta parte esencial para la formación de los juristas, no solamente de los países propios del área romanística, sino también de otros que parecería en principio que poco o nada tuvieran que ver. Así, los estudios en Oxford y Cambridge, los realizados en el área otrora llamada "socialista" (caso de Hungría, Polonia, Rumanía, la ex Yugoslavia e incluso en Rusia). También en el Japón y en China. Baste decir que, en colaboración con el *Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano*, establecido en Roma, se está trabajando en una traducción al chino del Digesto.

§ 74. *El Derecho Romano en la Argentina.* En nuestro país, la primera cátedra de Institutas surgió en la Universidad de Córdoba (1791). Importancia especial tuvo la enseñanza del Derecho Romano por parte de Dalmacio Vélez Sarsfield, profesor en Córdoba y más tarde en Buenos Aires. La influencia romana en el Código Civil redactado por él es innegable, no sólo en gran cantidad de sus artículos, sino también en las muy instructivas notas.

Hay que destacar que en el terreno de la traducción, hay obras argentinas demostrativas del interés de sus profesores. Aparte de mi traducción anotada de las *Institutas de Goyo*, hay que recordar la de los seis primeros libros del *Código Theodosiano*, realizada en Córdoba por un grupo de profesores bajo la dirección del gran romanista que fue Agustín Díaz Bialek, la de las *Reglas de Ulpiano*, debida a la profesora Nina Ponnasa de Miguens y la de la *Comparación de las Leyes Mosaicas y Romanas*, realizada por el profesor cordobés Silvino A. Pautasso. Más reciente, la edición bilingüe de las *Sentencias de Paulo*, debida al profesor, también cordobés, Santos A. Carninos.

Está constituida la *Asociación de Derecho Romano de la República Argentina*, la cual agrupa a los profesores romanistas de todo el país, reuniéndose en encuentros bienales. Igualmente, los profesores argentinos se han venido destacando en los *Congresos latinoamericanos de Derecho Romano*, que reúne a estudiosos de toda Latinoamérica, así como de Italia y España, también cada dos años.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO ROMANO

§ 75. *Ius y Derecho*. Generalmente la palabra *ius* es traducida como "Derecho". Sin embargo, los romanos no hablaban de "derecho" sino de *ius*. Este vocablo vincula de una manera más directa lo jurídico con la *iustitia*. De ahí que en forma muy amplia podemos establecer que *ius* = "lo justo". En cambio, la palabra "derecho" (*directum*) alberga un sentido moralizante, en el sentido de que la conducta justa es aquella que sigue el camino recto. Comenzará a ser empleada por los autores cristianos de la tardía época del Bajo Imperio. Pero no trascenderá a lo jurídico, donde siempre se utiliza el vocablo *ius*.

§ 76. *Etimología de ius*. Para los autores de los siglos anteriores resultaba oscura la proveniencia de *ius*.

a) Algunos lo derivaban del verbo *iungo* (= unir), en el sentido de significar que los hombres quedan unidos en los negocios, como los bueyes por el yugo.

b) Otros lo hacen ascender a *iurare* (= jurar), para relevar una relación religiosa; es curioso que en su forma primitiva se escribía *iouis*, por lo que se la vincula con *Iouis* (la designación de *Iuppiter*).

c) Pero hoy día parece pacífica la vinculación de *ius* con el vocablo indoeuropeo *yauis*. Este era usado, sobre todo en los textos indios (*yóh*) e iránicos (*yaos*), para significar como una persona o una cosa, a partir de una "situación normal" o "profana", podía obtener un valor "máximo" u "óptimo", por medio de la realización de ritos determinados. Por la relación lingüística indoeuropea, pasa a Roma, aplicada ahora a las relaciones jurídicas.

Esto explica cómo en el viejo *ius* la aplicación está dada más que por la aplicación del sustantivo, por la del adjetivo *iustus*, -a, -um, para referirse a que una situación "normal" (así, la adquisición de una *res mancipi*), se podía tornar "máxima" u "óptima", es decir, "justa", mediante un rito (*mancipatio*). Por ello el propietario adquirente podía decir respecto de la cosa: *mea esse aio ex iurē Quiritium* = "digo ser mía conforme al *ius* de los Quirites". Si no se realizaban los ritos, el propietario lo era de hecho, pero no estaba en situación justa.

Del mismo modo, *iustum* significa lo "justo ritual", así *iustum testamentum* = testamento justo por

haberse hecho conforme a los ritos, *iusta manumissio** = manumisión justa de un esclavo hecha por una forma solemne, y también *iustum bellum* = "guerra justa", es decir, la declarada ritualmente por los ritos de los feciales, etc.

§ 77. *Etimología de Derecho*. Los romanos conocen *rectus*, -a, -um, pero su aplicación es:

a) ya geométrica, para designar la línea recta, es decir, la que une directamente dos puntos, a diferencia de la "curva", donde la unión es combada, es decir, "no recta";

b) ya gramatical, para designar el "hablar en forma directa"; así, expresar algo con *directa verba* ("palabras francas y directas"), es decir, no con circunloquios y palabras "oblicuas";

c) ya moral, para expresar al hombre moralmente recto, es decir, que no conoce "doblez": *vir rectus et sanctus*.

1. *Derecho*, en el sentido de conducta moralizante, comienza a aparecer en la tradición judeo-cristiana. Así, Cassiodoro emplea el latín vulgar *directitudo*. Lo que ocurre es que en la tradición bíblica se puede hablar de conducta recta, utilizando el parámetro de la "ley divina" (los Mandamientos, llamados "Tablas de la Ley"). De este modo, puedo decir que mi conducta es recta si la comparo con lo ordenado por Dios. Como en la recta, existen acá dos puntos que permiten hablar de una dirección encaminada, que será "recta" si acato la voluntad divina, y "torcida" (*prava*) si ello no ocurre. Así, en San Agustín, *Enarr. ad ps. 35.16*: "De este modo, no quieres dirigir tu voluntad a la voluntad de Dios, sino que quieres curvar la de Dios hacia la tuya. Aquella es la recta, pero tú la curvas: eres tú quien debes corregir tu voluntad hacia la divina, no que ésta se deba curvar hacia tí; y así tendrás recto el corazón".

2. Como los romanos no conocieron, por lo menos hasta la época cristiana, una ley dictada por la Divinidad, ellos emplearon la palabra *ius*, cuya significación es "lo justo", que debía ser encontrado en cada situación dada. El triunfo posterior del Cristianismo es lo que nos ayuda a comprender que la palabra predominante en el Occidente posterior será *Derecho* (*Droit, Diritto, Recht, Right*, aunque también *Law*). Incluso, la laicización modernista, reemplazando Dios por Estado, seguirá la misma línea de aplicación: es "derecho" todo aquello que se acomode a la voluntad

estatal expresada en las leyes. Pese a ello, vocablos derivados de *ius* continuarán vigentes, sobre todo por su vinculación con justicia: así, jurista, jurisprudencia, jurídico, etc.

3. Pese a esta precisión establecida entre *ius* y Derecho, por una cuestión de comprensión, seguimos hablando de Derecho Romano. En la explicación de las instituciones emplearemos la palabra "derecho", pero cabe recordar la distancia existente entre ambos vocablos.

§ 78. *Distintas acepciones de la palabra ius*. La palabra *Ius* preferimos traducirla, genuinamente, siempre como "lo justo". Pero a través de las distintas etapas del desarrollo jurídico romano, su sentido irá variando.

a) Así, en la época primitiva, la calificación de "justo" será tributaria de su sentido etimológico. Ello explica el carácter fuertemente ritual de los actos y negocios jurídicos, así como en el antiguo procedimiento para resolver los juicios (caso de las *legis actiones*).

b) Ya en la época clásica, la más esplendente, se supera el viejo ritualismo, de tal modo que *ius* (= lo justo) adquiere un sentido más complejo, como lo es la búsqueda de las "soluciones de justicia" en cada caso específico.

De ahí la célebre definición de Celso (hijo): "El *ius* es el arte de lo bueno y de lo equitativo" (*Ius est ars boni et aequi*; Ulp.-Celso, D.1.1.1 pr.).

1. Esta definición ha sido criticada por los modernistas, como "incomprensible" (Prigheim), como una "vacía frase retórica" (Schulz), o en general en ciertos manuales como "ingenua" por cuanto no se resalta el carácter de "ciencia" que tiene el Derecho. Pero en ella encontramos la esencia misma del *ius*, por lo menos el de la época clásica.

2. La palabra *ars* podría ser entendida como una "técnica" (en griego *techné*), pero siempre que le demos a este vocablo, no el sentido de un "mero hacer", sino uno más elevado (como en "bellas artes"). El jurista, es decir, el *iurispudens*, lo que busca es "producir" la "solución justa" en cada caso. Éste es el sentido griego de *poiesis*. El *ius* es, pues, alguna cosa poética. Lo que se trata de producir (es decir, diseñar algo y traerlo —ducere— ante sí) es algo que corresponda al *bonum* (el bien, es decir, que trascienda lo meramente pragmático, que sea moralmente bueno y aprovechable para el hombre) y al *aequum* (lo equitativo). Recordemos que la expresión *ex bono et aequo* la encontramos en la fórmula de los *bonae fidei iudicia*.

3. Se trata de un *ius* abierto, donde se trata de "crear el *ius*" (*condere ius*). Nos lo recuerda Ulpiano (D.1.3.13): "Pues, como dice Peño, siempre que por la ley se ha introducido una u otra disposición, es buena ocasión para que o por la *interpretatio* (la de los

iurispudentes) o ciertamente por la *iurisdictio* (la de los pretores), se suplan las demás que tienden a la misma utilidad". Y Pomponio exalta la labor de los prudentes al reconocer que el *ius* no puede tener existencia (o consistencia) si no es por la intervención de algún *iuris peritus*, quien con su empeño cotidiano (*cottidie*) pueda "producir" soluciones que tiendan a "mejorar" el propio *ius* (D.1.2.2.13).

c) En la última época, sobre todo con Justiniano, la palabra *ius* (o mejor los *iura*) hace referencia a las sentencias y opiniones de los jurispudentes. Pero habiéndolas dotado Justiniano de fuerza legal, en el fondo significará "lo justo obligatorio", con lo cual nos aproximamos al sentido posterior de Derecho.

§ 79. *Diversos empleos del vocablo ius*. En lenguaje jurídico modernista, una de las ideas centrales es la diferenciación del Derecho en una doble significación:

a) como *Derecho objetivo* (= ordenamiento jurídico, conjunto de leyes y reglas que componen el Derecho); así cuando hablo del Derecho argentino, o francés, o inglés; y

b) como *derecho subjetivo* (= poder o facultad que tiene una persona para hacer algo que le permite el Derecho en sentido objetivo); así, cuando hablo de "mis derechos".

En Roma, estas expresiones no existen, por lo menos con toda la carga modernista. Incluso, las propias palabras *subiectum* y *objectum* funcionan en forma distinta de lo que será entre los racionalistas la relación "sujeto-objeto". Los juristas hablan en general de *ius*, y si bien cabe observar aspectos "objetivos" y aspectos "subjetivos", la diferenciación no será tan tajante como lo vemos en la actualidad.

§ 80. Sin pretender agotar las muchísimas tonalidades del vocablo *ius*, podemos señalar estas aplicaciones:

a) A veces el sentido es claramente "objetivo". Así, p.ej., "el *ius* que se usaba por el *Populus Romanus*" (*ius quo Populus Romanus utebatur*; Gayo, 2.40) Acá se está refiriendo al conjunto de reglas, instituciones, etc., que utilizaba el *Populus*.

Obviamente, en su caso, será un ciudadano quien podrá usar de este *ius*. Pero acá ese ejercicio no está cargado del sentido voluntarista moderno, sino que representa el aspecto "subjetivo" de su utilización. Precisamente el *ius* está constituido "por causa de los hombres" (*hominum causa omne ius constitutum sit*; Hermogeniano, D.1.5.2). Por eso el *ius* es usado por los hombres, ya que es algo esencialmente humano.

b) Otras veces aparece un aspecto "subjetivo". Así, p.ej., *ius neum*, respecto del cual se emplean los verbos "obtener" (*obtinere*), "peticionar" (*postulare*),

"perseguir" (*persequi*), etc. Pero obsérvese también el empleo de la expresión *fundus cum iure suo* (el fundo con su *ius*; Ulp., D.33.7.12.42; Modest., D.33.10.8; etc.). Si traducimos todo esto como "mi derecho" (en el sentido subjetivista moderno), nos encontramos con la dificultad de que hablando del "fundo", resulta incongruente hablar de que una cosa tenga "su derecho" (siempre en el sentido modernista).

Más bien, los autores (Gioffredi, Kaser, Villey, d'Ors) traducen acá *ius* como la "posición" o "situación jurídica" (o "justa") en que se encuentra una persona o una cosa.

c) Un sentido donde se ve esta ambivalencia objetivo-subjetiva, se da en el "dar a cada uno lo suyo" (*ius suum cuique tribuere*) y en la potestad del pretor del *ius dicere*. En la función de hacer justicia, lo que se debe determinar es el *ius suum*, que acá no es el "derecho suyo", en el sentido moderno, sino más bien "lo justo suyo", determinando el magistrado la "situación" o "posición justa" de cada uno de los litigantes.

d) En el caso de los *iura in re aliena*, más que "derechos subjetivos sobre la cosa ajena", vemos la designación de la "situación" en que se halla la cosa, que determina ventajas en favor de otro. Así, *ius altius tollendi* no es el "derecho de elevar más alto", sino "la posición justa de edificio elevado"; *ius utendi fructus* es "la posición justa de uso y de disfrute"; *ius tigni immittendi* no es "la facultad de apoyar la viga en el fundo vecino", sino "la posición justa de edificio que apoya su viga en el fundo vecino", etc. Recuérdese que el *dominium* no es un *ius in re*, sino "la situación justa de una cosa de la que puedo decir que es mía".

e) En expresiones como *ius successionis* o *ius obligationis*, que Gayo (2.14) ubica entre las *res incorporales*, el sentido exacto es "posición justa de sucesor" y "posición justa de obligatoriedad", precisamente en este último caso, resultaría incongruente hablar de que el obligado tiene un derecho subjetivo.

1. Lo que podría llamar la atención es que en el viejo *ius*, sobre todo en la familia, se hable de *potestates*, lo que podría hacernos pensar en fuertes "derechos subjetivos" (recordar aquello de que el *pater* tenía el *ius vitae necisque*). Pero acá, no obstante la energía y el vigor jurídico de la *patria potestas*, ésta no es "el derecho subjetivo del *pater* sobre los *filiifamilias*", sino "la posición justa, en tanto que adscrita por el *ius*, del *pater* en la familia", que engendra no sólo poderes, sino también obligaciones. Del mismo modo, no se puede hablar de "derechos subjetivos públicos", entendiendo por tales el *imperium* o la *potestas* de los magistrados.

2. Por tanto, nos aproximamos mucho más al verdadero espíritu romano en estos casos de beneficio particular, si entendemos por *ius* la "posición o situación justa" en que se hallan los beneficiarios. El considerarlo "derechos subjetivos" es una intelección *avant la lettre* de la posición filosófica modernista,

surgida dentro del protestantismo sobre todo por la Escuela Holandesa del Derecho Natural.

§ 81. *El fas*. Junto al *ius*, sobre todo en el derecho antiguo, se emplea la palabra *fas*. Generalmente se lo entiende en los manuales como el "derecho divino". Si con ello hacemos referencia a un *ius* de los dioses, en contraposición con el *ius* de los hombres, la idea no resulta exacta. La expresión *Fas* es más bien alusión al fundamento natural y divino, que debe ser respetado por el *ius*. De ahí que no aparezca enfrentado, sino unido a éste. Así, en la expresión *ius fasque est*, para referirse a algo que resulta obligatorio por estar establecido por el *ius* y fundamentado por el *fas*.

1. La etimología de *fas* está discutida. Para algunos proviene de la raíz *Bha* = "hablar". Para otros, de *Dha* = "colocar", "establecer". Quizá no haya que excluir a una por la otra, por cuanto se pueden dar aplicaciones igualmente válidas.

Así, por la primera, vemos que quedan definidos los *dies fasti* (aquellos en los cuales se podía actuar en justicia, por cuanto el pretor podía "hablar" y decir las palabras procesales rituales: *do, dico, addico*). *Nefasti* *dies* son, en cambio, los días en que no se podía pronunciar dichas palabras y en consecuencia actuar ante el pretor.

En cuanto a la segunda, el *fas* señala el fundamento que resulta infranqueable respecto del *ius*. Así, se dice que *nefas est* que los comicios centuriados se celebren dentro del ámbito (*pomerium*) de la ciudad (Aul.Gell., 15.27.4), o que el *flamen Dialis* (sacerdote de Júpiter) jure. Es también *nefas* celebrar nupcias incestuosas, profanar los lugares sacros, etc.

En una época posterior, las expresiones *fas et nefas* quedan bien limitadas al ámbito de lo religioso. Para lo jurídico, el límite del fundamento estará dado por el *ius naturale*: "lo que está prohibido por las cosas de la naturaleza no es confirmado por ninguna ley" (Celso, D.50.17.188.1).

§ 82. *Definiciones básicas*. a) *Iustitia*. Según Ulpiano la justicia queda definida como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo jurídico" (*Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; D.1.1.10 pr. = Inst.1.1.pr.).

1. El concepto corresponde a una vieja tradición griega (Platón, *Rep.*, 331 e). El "dar a cada uno lo suyo jurídico", criticado por algunos por cuanto no se indicaría con precisión qué es lo suyo de cada uno, se corresponde plenamente con la tarea de los prudentes, que tratan de discernir "lo equitativo de lo ilícito, lo lícito de lo ilícito" (Ulp., D.1.1.1.1). No hay recetas preestablecidas, salvo aquellos pocos casos determinados por las usanzas leyes, las cuales eran

igualmente tarea de análisis en cada caso concreto. Cicerón (de inv. 2.53.160) establece que la justicia se da "en el dar a cada uno lo suyo, según su dignidad" (*suum cuique tribuens dignitatem*).

b) *Aequitas*. No hay una definición propia de la "equidad". Para los juristas y para los magistrados era muy importante para la solución de cada caso. Cuando se presentaba un litigio, que de observarse meramente lo que resultaba de las *leges* o de las reglas rituales del *ius civile*, se podía llegar a una solución "iniqua" (*in-aequa*), entonces el pretor corregía el *ius civile* por la aplicación de la *aequitas*, ya otorgando una *actio* o una *exceptio*. Si el prudente considera que hay que aplicar el *ius*, entonces dirá que la solución *iusta est* o como en el viejo lenguaje *ita ius esto* (que así sea el *ius*). Cuando declara que algo *aequum est* lo que quiere significar es que algo es el *ius* (lo estricto) y está esta otra decisión que quiere ser en contra del *ius*. Así puede decirnos Cicerón que "muchas veces se decide por la *aequitas* en contra del *ius*"; de orat., I.56.240).

1. La *aequitas* romana guarda diferencias con el análogo concepto griego de la *epiēkeia*. Este es según Aristóteles (*Eth.Nic.*, V.1137 b) "un correctivo de la justicia legal: 'La causa de ello es que toda ley es universal y que hay casos en los que no es posible tratar las cosas realmente de un modo universal'. En cambio, para los romanos, el problema era distinto. Ante un caso concreto, siguiendo una lógica finalista que mirara los resultados finales, se decidía o por la aplicación directa del *ius civile* o por la solución de *aequitas*, concediendo el pretor una *actio in factum*, en favor del actor o una *exceptio* en favor del demandado.

2. Decidir por la *aequitas* es recurrir al *arbitrium* del magistrado, lo cual no significa abandonarlo a su arbitrariedad. Las soluciones no eran caprichosas ni subjetivas. La "leyenda" de la arbitrariedad se debe a casos aislados. Así, la decisión de Calpurnia de reemplazar la *iurisprudencia* por la *aequitas* (Suet., *Caes.*, 34) es algo que desnaturaliza el verdadero concepto romano. Luego, en los tiempos medievales se recurre a la célebre *aequitas cerebrina*, nacida del "ingenio" del juez (*ex ingenio suo*). Ello transformó el "arbitrio" prudente en pura "arbitrariedad". Nos explicamos así la reacción de los habitantes de Saboya que reclamaban del conquistador rey francés Francisco I, que prohibiera que las causas se resolvieran por "equidad". O el dicho que corría en el *Ancien Régime* de que "Dios nos guarde de la equidad del Parlamento". En cambio, una versión más "romana" la tenemos en la aplicación de la *equity* del *Common Law* inglés.

c) *Principios fundamentales del Derecho*. Según Ulpiano (D.1.1.10.1), hay tres principios que fundamentan el *ius*:

1. *Honeste vivere* (Vivir honestamente).

1. Este principio luce como moral. Pero, dada la interpenetración entre las costumbres (*mores*) y el *ius*, el no vivir en forma honesta puede arrastrar consecuencias jurídicas. Así, p.ej., la inobservancia de los *mores* podía traer la tacha de infamia, por la nota censoria; precisamente los censores tenían el deber del cuidado de las costumbres (*cura morum*). También, a los efectos del divorcio causado, la conducta deshonesta de la mujer por adulterio u otra injuria, ocasionaba consecuencias de retención de una parte de la dote que debía devolver el marido (*retentio propter mores*).

2. *Alterum non laedere* (No dañar a otro) o también *Neminem laedere* (No dañar a nadie).

1. La conducta de todo hombre no debe ocasionar daños a otro. Una aplicación primera de esto es la configuración del delito de "daño" referido a las cosas (*damnum iniuria datum*), penado por la *lex Aquilia*. Igualmente el daño a una persona libre, ya de palabra o de hecho, configura el delito de injurias (*iniuriae*).

3. *Suum ius cuique tribuere* (Dar a cada uno lo suyo jurídico).

1. Estamos acá en relación directa con la definición de *iustitia* dada por el mismo Ulpiano.

d) *Iurisprudencia*. Ulpiano (D.1.1.10.3) define la *iurisprudencia* como "el conocimiento de las cosas divinas y humanas, con la ciencia de lo justo y de lo injusto" (*Iurisprudencia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*).

1. La mención de las "cosas divinas y humanas" es una referencia a toda la realidad. El conocimiento del *iurisprudens* debe ser integral. Pero a diferencia del *sapientis*, que inquiere la verdad de la realidad, el *iurisprudens* lo que busca es la "solución justa". Por ello su virtud no es la *sapientia*, sino la *prudentia*. Esta consiste, según Cicerón, en la *rerum expendarum fugiendarum scientia* (el conocimiento de aquello que se debe hacer y de lo que se debe evitar; de off., I.43.153).

Por ello es que el conocimiento de toda la realidad debe ser efectuada "con" (preferimos traducir *scientia* como ablativo y no como nominativo, a fin de evitar dos frases aisladas en la definición) la "ciencia" —en el sentido de conocimiento— "de lo justo y de lo injusto".

Clasificaciones del *ius*:

§ 83. *Ius publicum - Ius privatum*. El Derecho moderno distingue entre Derecho Público y Derecho

Privado. El primero es el que regula la constitución de los poderes del Estado, así como también la relación de las personas privadas respecto de aquél, en situación de subordinación. En cambio, el segundo regula las relaciones que tienen las personas entre sí, actuando en un pie de igualdad.

Esta distinción no se da en Roma de una manera tan clara y tajante. Lo que ocurre es que en su orden constitucional no se da la idea de Estado. Y ello es explicable, por cuanto este concepto es netamente moderno. De lo que hablan los romanos es de *Populus Romanus*, pero funcionando políticamente como la *res publica*, es decir, la "cosa o el asunto que interesa a todos los ciudadanos que la componen". Dicho de otro modo, el *populus* no es considerado nunca una "persona jurídica".

De ahí que durante la época antigua, pasando por la republicana y aun durante buena parte del Principado, la diferencia entre el *populus* y los ciudadanos es muy distinta de lo que ocurre en el pensamiento actual. Así, en lo que se refiere a las personas, las decisiones tomadas en los comicios (*leges*) o en los *concilia plebis* (plebiscita) deben ser acatadas por cuanto han sido sancionadas por el *populus*, es decir, por todos (o la mayor parte de los ciudadanos). Del mismo modo, en cuanto a las cosas, las *res publicae* son aquellas que pertenecen en forma comunitaria a todo el *populus*, sin pertenecer a alguien en particular, como ocurre con las *res privatae* (Gayo, 2.11).

1. En este derecho la distinción entre lo "público" y lo "privado" aparece como la diferencia entre "lo que es de todos" y "lo que es propio de los particulares". Al no existir la idea de Estado, no hay una "persona jurídica" que tenga su existencia separada. Así, un ciudadano puede apelar, así por una pena capital, por la *provocatio ad populum* ante los comicios. Pero esto debe ser entendido como una apelación "a todos los ciudadanos".

2. Ciertamente es que lo decidido por el *populus* es considerado *lex publica*, y en tal sentido no puede ser modificado por los particulares. La regla general es que "el *ius publicum* no puede ser alterado por pactos particulares" (Papin., D.2.14.38). Del mismo modo, hay temas en los cuales, por "interesar a todos" (utilidad pública), ellos se comportan necesariamente como obligatorios (*ius cogens*). Así, la *libertas* (no es cosa privada, sino pública; Marciano, D.40.5.53 pr.); el régimen de excusas de la tutela (Papin., D.27.1.30.3); la responsabilidad de los transportistas marítimos (Ulp., D.14.1.1.20); etc.

3. Como una situación intermedia entre lo "público" y lo "privado" encontramos la expresión técnica *popularis*. Así, según Labeyrie, los *popularia sacra* son aquellos ritos "que hacen todos los ciudadanos, y no

son atribuidos a familias determinadas" (Festo, 298 L.). Y Varro (en *Schol.Pers.*, 1.72) nos dice que las fiestas de los *Parilia*, celebradas el 21 de abril, "son para los rústicos, tanto privadas como públicas".

§ 84. Ulpiano, ya en su época, establece la mención de *ius publicum* distinta del *ius privatum* (D.1.1.1.2). El primero es el que "se refiere al estado de la *res Romana*" (*quod ad statum rei Romanae spectat*), mientras que el segundo se refiere "a la utilidad de los particulares".

1. Acá el empleo de *status* no debe ser entendido como el Estado político, sino que vale tanto como *status personarum*, *status libertatis*, etc. Entre los ejemplos que da de temas relativos al *ius publicum* menciona los sacra, los sacerdotes y los magistrados. Cicerón, en cambio, dice que los sacerdotes del *populus Romanus* son "privados" (de inv. 1.40.89). También los *municipia* son a veces vistos como "privados", aunque la mayoría de las veces, como "públicos". Como se ve, si bien continúa la diferencia entre los asuntos que "hacen a todos" o a la "mayoría" (Ulp., D.50.17.160), que se tornan obligatorios, y los que "hacen a los particulares", la distinción romana no tiene el carácter decisivo que tiene en el Derecho actual.

Recién con la aparición de los organismos administrativos, como la Cancillería imperial, lo relativo a la administración en general, el gobierno de las provincias, los temas fiscales y criminales se tornan más claramente públicos, ya en un sentido más cercano al moderno.

§ 85. *Ius commune, ius singulare, beneficium, privilegium*. 1. Sin tener mayor importancia, se contraponen el "derecho común" (*ius commune*) y el "derecho excepcional" o "singular" (*ius singulare*). Este último será entendido por Paulo como "aquel que ha sido constituido por la autoridad a causa de la utilidad particular de alguien" (D.1.3.16). La terminología no parece clásica. Sería el caso del *ius* que se aplica a los soldados, a quienes se les permiten ciertas situaciones especiales (p.ej., hacer testamento como quieran o como puedan).

2. Este concepto de *ius singulare* no se confunde con el de *beneficium*. Este aparece, dentro del derecho Justiniano, para designar ciertas ventajas otorgadas a algunas personas. Así el *beneficium competentis* (que ciertos deudores puedan pagar sólo hasta el límite de sus posibilidades económicas), el *beneficium abstinendi* (que ciertos herederos forzosos se puedan abstener de aceptar la herencia), el *beneficium inventarii* (que los herederos voluntarios o extraños sólo respondan de las deudas del causante hasta el límite del monto activo de la herencia); etc.

3. También existe la noción de *privilegium*. En los primeros tiempos era algo que iba en contra de

una persona (de *privus* y de *lex*). La ley de las XII Tablas prohibían los privilegios (9.1). Cicerón lo define todavía como "ley contra un individuo" (de *leg.*, 3.19). Pero en la época posclásica, aparece como una excepción al Derecho común, por lo que se llama *privilegium* cuando se favorece a una persona. Tiende a aproximarse y confundirse con el *ius singulare* (así, se habla de *privilegium* a propósito del testamento de los soldados).

§ 86. *Ius civile* - *Ius gentium* - *Ius naturale*. Por *ius civile* se entiende el Derecho que es propio de cada nación (*civitas*). Así, el Derecho usado por los atenienses como propio, es su *ius civile*, respetado en principio por los romanos para solucionar los problemas entre atenienses. El Derecho usado en Alejandría será también el *ius civile* de los alejandrinos. Pero, en general, cuando se habla directamente de *ius civile*, entendemos por tal el "ius propio de los romanos".

1. Este *ius civile* está contenido en el *ius scriptum* de las *leges* (y de las otras fuentes con valor análogo: plebiscitos, senadoconsultos, constituciones imperiales), pero también en el *ius non scriptum* de las instituciones propias de los romanos (así, la *patria potestas*, la *manus*, etc.), como de los ritos jurídicos (*mancipatio*, *in iure cessio*, etc.).

2. Se aplica a los ciudadanos romanos, pero también a los latinos que tienen el *commercium* y el *conubium*, según la categoría a la cual pertenecen. A medida que se va extendiendo la ciudadanía, la aplicación del *ius civile* se irá ampliando.

§ 87. *Ius gentium* - *Ius naturale*. Gayo (1.1) establece que todos los pueblos se rigen, al mismo tiempo, en parte por un *ius* que les es propio (*ius civile*) y en parte por un *ius* que es común a todas las naciones (*ius gentium*). Y nos dice que este "derecho común" tiene su fuente en la "razón natural" (*naturalis ratio*).

1. De este modo, la división de Gayo es bipartita, y al parecer lo que denominó *ius gentium* se confundió con el *ius naturale*. La expresión *naturalis ratio* aparece como un recurso extraído de la filosofía, quizá de los estoicos, que hablaban del *orthós Logos* (recta razón natural) y de *Logos spermatikós* (el que pone sus semillas en toda la naturaleza). Lo que sí parece sensato es que esta expresión se refiere a la "razón de ser de las cosas y entes naturales", y no debe ser entendida en el sentido modernista subjetivista de la "razón humana".

§ 88. Con Ulpiano (D.1.1.3 ss.; Inst.1.2 pr. y 1) aparece una distinción tripartita. Distingue entre el *ius naturale*, que es "aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este *ius* no es propio del género humano, sino común

a todos los animales que nacen en la tierra o en el mar, y también las aves", p.ej., la unión de sexos y la procreación; el *ius gentium*, como aquel que "usan todos los pueblos humanos" y el *ius civile* como el propio de cada *civitas*.

1. Ulpiano pone más el acento en los seres a los cuales se aplica cada *ius*. Así presentados, la correlación se podría hacer en tres círculos concéntricos: el círculo más amplio sería el *ius naturale* derivado de la *ratio divina* y aplicable a todos los seres vivos; el círculo segundo representaría el ámbito más restringido del *ius gentium*, aplicable a todos los hombres de todas las naciones, incluidos los romanos; y finalmente, el más interno significaría el *ius civile*, es decir, el propio de cada *civitas*.

Para dar un ej., la mera unión de sexos y la procreación corresponde al *ius naturale*. Pero la unión sexual concebida como "matrimonio", fundado en el Derecho Natural, es del *ius gentium*. Y a su vez, el matrimonio propio de los romanos (*iustus nuptiae*) es propio del *ius civile*.

La oposición mayor se da entre el *ius civile* y el *ius gentium* (que muchas veces se identifica con el *ius naturale*, pero en otras se opone; así, según Florentino (D.1.5.4.1), la esclavitud es "una constitución del *ius gentium*, por la cual alguien está sujeto contra la naturaleza al dominio ajeno").

2. La vigencia del *ius gentium* se tornó necesaria a los romanos para dar solución a los problemas jurídicos entre extranjeros o entre éstos y los romanos, e incluso para admitir para éstos la vigencia de instituciones que no figuraban en su *ius civile*. Surgen así figuras contractuales (p.ej., la compraventa, la locación, la sociedad, etc.) que son usadas por todos los pueblos. También formas de adquisición del dominio que irán reemplazando las del *ius civile* (*mancipatio*, *in iure cessio*) como la tradición.

3. Algunos autores (p.ej., el P. Ramírez, "El Derecho de Gentes") le han objetado a Ulpiano que haya concebido a los animales como "sujetos de derecho". Pero la crítica no es aceptable. Si Ulpiano menciona a los animales, es porque perteneciendo a la naturaleza, ésta les ha participado del instinto de procreación, y bajo esa circunstancia están dentro del "orden natural", puesto que corresponde a un apetito nacido de la ley natural. El mismo Ulpiano (D.9.1.1.3) nos dice que un animal que carece de razón no puede obrar en forma contraria al *ius* (aplicado en este caso a que no puede cometer *iniuria*).

4. Digamos también que en algunos párrafos del Digesto (así, D.41.1.5.7; D.50.7.1.7) está preanunciada la variante que luego se establecerá en el mundo occidental del *ius gentium* = "Derecho internacional". Igualmente, anotemos como curiosidad que con posterioridad, en el Decreto de Graciano (I.1.1) *ius naturale* es definido en sentido netamente cristiano como "aquello que se contiene en la Ley (los Mandamientos) y en el Evangelio".

§ 89. *Ius praetorium* o *ius honorarium*. El *ius civile*, entendido como el propio de los romanos, sobre todo caracterizado por la rigidez de sus reglas, se contraponía al *ius praetorium* o *ius honorarium*, que es aquel que por una finalidad de "utilidad pública" introdujeron los pretores para "ayudar" (*adiuvandi gratia*), o para "suplir" (*supplendi gratia*), o para "corregir" (*corrighendi gratia*) el *ius civile* (Papin., D.1.1.7.7), quien agrega que es llamado "honorario" en "honor" de los pretores.

1. Este *ius praetorium* no desplaza directamente al *ius civile*, pero de algún modo lo complementa y hasta lo corrige, estableciendo un "ius paralelo" que trata de encontrar soluciones de equidad para los distintos casos.

Así, p.ej., la *hereditas* es una institución del *ius civile*. Cuando se producen, por cambios en la sociedad romana, situaciones que deben ser amparadas, el pretor crea una institución análoga, la *bonorum possessio*. Vemos, pues, funcionar dos instituciones que conviven en distintos planos. En cuanto a la *hereditas*, el pretor no puede crear herederos, pero a ciertos herederos familiares que no lo son por el *ius civile*, les concede la "posesión de los bienes hereditarios" (*bonorum possessio*), institución pretoriana. En los llamamientos edictales de la *bonorum possessio ab intestato*, el pretor llama en primer lugar a los *fili*

in potestate del causante (aquí "confirma" el *ius civile*), pero para evitar la iniquidad de que quedarán fuera los hijos emancipados, también los incorpora (aquí "corrige" el *ius civile*), y luego de haber llamado a todos aquellos que eran herederos civiles, agrega también a los parientes "cognados" y al "cónyuge superstite" (aquí, "suple" el *ius civile*).

El *ius honorarium* tendrá una importancia decisiva para producir los grandes mejoramientos del *ius civile* y el hallazgo de las mejores soluciones jurídicas. Este *ius praetorium* es un *ius* que *in sola prudentium interpretatione consistit*. Y Pomponio, al decir esto, agrega que este *ius honorarium* es el "proprium *ius civile*" (D.1.2.2.12). No hay en ello una contradicción, sino una delicada tarea de complementación de ambos derechos. Por ello, también Marciano (D.1.1.8) puede decir que "este mismo *ius honorarium* es la viva voz (*viva vox*) del *ius civile*".

2. De ahí que uno de estos derechos funciona mientras no lo haga el otro. Ello se ve en la dualidad de instituciones que podemos encontrar; así, hay un dominio *ex iure Quiritium* y un dominio *in bonis*; está el vínculo civil de la *agnatio* y el de la *cognatio*, que será amparada por el pretor; y del mismo modo, la *hereditas civil* y la *bonorum possessio pretoriana*. Y así, muchas otras aplicaciones.

PARTE PRIMERA
EL PROCEDIMIENTO ROMANO

CAPÍTULO 1

LA ACTIO

§ 90. *Generalidades.* En el Derecho actual se distingue entre lo que es propiamente el Derecho Privado y el Derecho Procesal. En el primero figuran todas las instituciones sustantivas (prej., los negocios, los contratos, las obligaciones, las herencias, etc.). El segundo consiste en la forma como tramitan los juicios en los cuales dos partes estén disputando sus derechos en torno de alguna de dichas instituciones. De ahí que se suela decir que uno es el Derecho sustantivo y el otro el Derecho adjetivo, o más propiamente, que uno es el Derecho de fondo y otro el Derecho de forma.

1. Esto ocurre así, porque en la sustancia de esta diferenciación está presente la noción modernista de "derechos subjetivos"; la constitución de ellos, permitida por el Derecho objetivo, necesita su protección para los titulares, y ella se da mediante las normas del Derecho Procesal.

Los romanos no conocieron propiamente la noción modernista de los "derechos subjetivos". Para ellos, las distintas situaciones jurídicas que sean litigiosas, sólo tienen relevancia en tanto y en cuanto que resulten amparadas por el magistrado encargado de administrar justicia. El pretor, al admitir la protección de una determinada situación, está propiamente creando lo que hoy día se llama Derecho objetivo. Por ello es que no conocieron una diferenciación sistemática entre el Derecho Privado y su protección jurisdiccional. El *ius* es para ellos una unidad, de tal modo que las situaciones de fondo están íntimamente expresadas en las "acciones" y otras medidas de amparo que considere oportuno el magistrado. Por ello se ha dicho con razón que el Derecho Romano es un "Derecho de acciones".

2. Así, si tomamos el Derecho clásico, la preocupación de los juristas no es ocuparse tanto de los derechos, deberes u obligaciones que podía tener alguien que ocupaba una situación jurídica (ser propietario, ser acreedor, ser heredero), como de las condiciones en las cuales podía haber el ejercicio de las acciones, a los efectos de proteger a quien goza de esa situación.

De ahí la unidad existente entre las instituciones

y la protección judicial que éstas puedan tener. Por ello es que se habla de "Derecho de acciones", y no "de derechos subjetivos". Quien creía estar justificado para defender su posición jurídica, lo que busca es que el pretor le ofrezca respuestas a preguntas tales como: ¿puedo yo en esta situación accionar con probabilidades de éxito?, o ¿puedo yo defenderme contra esta acción? El pretor no era el mero aplicador de las leyes, puesto que: a) éstas eran muy pocas en materia de derecho privado; y b) él se dedica más bien a considerar el caso concreto que las partes le presentan, tratando de encontrar una "solución de justicia".

Él es quien tiene la *iurisdictio*, es decir, la potestad de *dicere* (= decir, pero en el sentido fuerte de "crear") el *ius*. Por ello es que, al otorgar una de estas medidas de amparo, está creando, para hablar en términos modernos, Derecho objetivo. Como se ve, por ser un magistrado jurisdiccional, aquí la *actio* o la *exceptio* entran en el ámbito de lo sustantivo y de lo formal, conformando una unidad. La expresión Derecho Procesal no es romana, sino moderna.

2. Ello es lo que permite hablar del *ius* como de un "Derecho de acciones", expresión que nos resulta más adecuada que "sistema de acciones" ("sistema" es una palabra moderna), puesto que muchas veces este "Derecho de acciones" aparece más como asistemático, que como totalmente organizado. Ello tampoco puede significar que todo el *ius* se reduzca al procedimiento judicial. Hay muchas instituciones que viven su vida jurídica en forma apartada de los juicios: así, la adquisición y pérdida de la *patria potestas*, el matrimonio, la celebración de los negocios, la confección de testamentos, la adquisición del dominio, etc. Y ello es así hasta que se genere un litigio.

§ 91. I. *Actio.* La palabra *actio* (deriva de *agere* = actuar, obrar) tiene el sentido general de "acto"; pero técnicamente está referida a la actividad jurisdiccional, y por ello la llamamos "acción". Es la vía por la cual alguien puede lograr el amparo jurídico de su situación particular. Quien ejerce la *actio* es el *actor* (demandante); aquel contra quien se dirige es el *reus* (demandado). El juicio en sí es la *res de qua agitur*; o también *lis* (litigio) o *causa*.

1. Celso (D.44.7.51) nos trae una definición de *actio*: "la acción no es otra cosa que el *ius* de perse-

guir en juicio lo que se nos debe" (cfr. Inst. 4.6 pr.). No resulta pacífico traducir el *ius persequendi*. Sería estar en situación o posición jurídica admisible para iniciar un juicio. Si la traducimos por "derecho", se podría traicionar el vocablo, máxime si por ese camino caemos en que se trata de un "derecho subjetivo", y menos aún en el sentido moderno de "derecho subjetivo procesal" (el *Anspruch* —pretensión— del cual hablan los alemanes). Más bien es el "poder de obrar" para obtener un resultado judicial. Pero este poder sólo es válido cuando es admitido por el magistrado, puesto que es el pretor quien "da o deniega la *actio*" (*dat aut denegat actionem*).

2. La definición de Celso parece que está dirigida sólo a las acciones para cobrar una obligación. Esto obedece a una cierta tendencia de la última época clásica, en la cual, si bien se acepta un sentido genérico de la *actio* para designar a cualquier acción, se la reservaba más específicamente para designar la *actio in personam*, empleándose la palabra *petitio* para nombrar la *actio in rem*, y luego *persecutio*, para el caso de su uso en el procedimiento *extra ordinem* (Ulp., D.50.16.178.2; Papin., D.44.7.28).

II. Clasificación de las acciones. Hay varios criterios para su clasificación:

§ 92. *Acciones in rem* - *acciones in personam*. a) En la *actio in rem* el actor reclama para que se declare en la sentencia, ya que una cosa es suya, o que le corresponde un *ius* (así, un usufructo o una servidumbre) o también que está en una posición jurídica personal que debe estar protegida respecto de todos (Gayo, 4.3; Inst., 4.6.1-2). Así, p.ej., la *rei vindicatio*, que le es concedida al propietario quiritario cuando alguien lo desconoce como tal.

b) En la *actio in personam* el actor reclama contra alguien que le está obligado a tener que pagar una obligación. Así, p.ej., la *condictio* (*actio*) *certae creditae pecuniae*, por la cual el demandado puede ser condenado a tener que pagar una suma determinada de dinero al actor.

1. La diferencia establecida es, pues, de orden técnico. En la *actio in rem* lo que se reclama es más propiamente "la cosa" o la "posición jurídica que se tiene respecto de una cosa". Y la declaración de que el actor tiene razón tiene un valor genérico respecto de todos (efecto *erga omnes*). Por eso en la fórmula de la época clásica la *intentio* contiene solamente la afirmación de esa "posición jurídica" (así, "que la cosa es mía"), sin nombrarse al demandado, el cual aparece recién en la *condemnatio* (donde se lo condena, p.ej., a restituir la cosa, o a pagar su valor). Siendo así, el demandado no queda obligado a continuar el juicio, pudiendo optar entre retener la cosa reclamada o detenerlo en cualquier momento abandonando la posesión de la cosa, dejándosela al actor.

2. En cambio, en una *actio in personam*, el nombre del demandado aparece necesariamente en la *intentio* de la fórmula. ("Que N.N. deba dar, hacer o prestar algo": la expresión *Dare facere praestare oportet* señala sin dudas una *actio in personam*). Y por supuesto, llevado el juicio contra él no podría apartarse del resultado de la condena, si no es pagando (cfr. Furio Anthus, D.6.1.80; Ulp., D.50.17.156 pr.).

3. Sería erróneo entender las *acciones in rem* y las *acciones in personam*, traduciéndolas por las actuales "acciones reales" y "acciones personales". Esta nueva terminología, que tendrá sus primeros delinamientos con los comentaristas medievales, trata de afirmar que la moderna "acción real" tiende a proteger un "derecho real", mientras que la "acción personal" a proteger un "derecho crediticio", con lo cual estamos haciendo funcionar la idea modernista de los "derechos subjetivos patrimoniales".

4. Debido a esta técnica procesal, las *acciones in rem* se suelen dar para que se afirme el dominio de una cosa o uno de los *iura in re aliena*. Pero sería erróneo decir que las *acciones in rem* son todas aquellas que protegen un *ius in re*. Así, la *actio legis Aquiliae* (para penar el daño en la cosa propia) y la *condictio furtiva* (para que el ladrón devuelva la cosa hurtada) bendan a proteger el dominio, y sin embargo son *acciones in personam*.

5. Igualmente, siendo el propósito de la *actio in rem* una declaración que valga contra todos (*erga omnes*), no queda relegada a los modernos "derechos reales", sino también a otras situaciones, así, las *quaestiones status*, como, p.ej., los debates judiciales sobre el *status*, la libertad y la calidad de ingenuo; o el ser hijo legítimo. Todas ellas son *acciones praedictas* y son consideradas *acciones in rem* (Inst., 4.6.13.1). Y si son tales es porque lo que interesa saber es si el demandado asumirá la defensa de su posición o se inhibirá de continuar el juicio.

6. También, aunque no sea una idea clásica, aparece la noción de *actio in rem scripta*, como, p.ej., la *actio quod metus causa* (Ulp., D.4.2.9.6; D.44.2; Ulp., 11.1).

7. Las *acciones in personam* son también llamadas por Gayo *condictiones*, así como las acciones *in rem* son llamadas *vindicationes* (4.5), aunque ello no es totalmente exacto. Así la *actio ex testamento* o la *actio ex stipulatu* son siempre llamadas "acciones", y no *condictiones*.

§ 93. *Acciones reipersecutorias, penales y mixtas*. a) En una acción reipersecutoria (*actio rei persequendae causa*) se persigue solamente la obtención de una cosa. Ello puede ocurrir tanto en una *actio in rem* (así, en la *rei vindicatio*), como en una *actio in personam* (así, en caso de comodato, depósito, mandato, compraventa, locación, etc.: Gayo, 4.7; Inst., 4.6.17).

b) En una acción penal (*actio poenalis*) se reclama solamente una pena, como ocurre en el

caso de los delitos. Así, p.ej., la *actio furti*, la *actio vi bonorum raptorum* o la *actio iniuriarum* (Gayo, 4.8; Inst., 4.6.18).

1. Así, en el caso del *furtum*, el que ha sufrido la sustracción de la cosa tiene por un lado acciones reipersecutorias (como la *condictio furtiva* o la *rei vindicatio*) para recobrar lo hurtado, pero también la *actio furti*, que es "penal", ya que por ella podemos lograr que el ladrón nos pague además, como pena, el *duplum*, el *triplum* o el *quadruplum* del valor de la cosa.

c) Son denominadas *acciones mixtas* (*actiones mixtae*) aquellas por las cuales perseguimos tanto la obtención de una cosa como también una pena. Ello ocurre excepcionalmente cuando accionamos por el *duplum* contra un adversario recalcitrante (*adversus infittantem*), es decir, respecto de aquel que se niega a reconocer lo que reclamamos y pierde luego el juicio. Así, p.ej., en la *actio iudicati**, en la *actio depensi**, en la *actio legis Aquiliae** o en la de los legados dejados por *damnationem* por un monto determinado (Gayo, 4.9; Inst., 4.6.19).

1. Justiniano altera esta denominación de "acciones mixtas". Así, entiende que la *actio vi bonorum raptorum** es mixta porque en la pena del *quadruplum* está comprendida la persecución de la cosa, no siendo la pena más que del *triplum*. Igualmente, la *actio legis Aquiliae*, no sólo por la razón dada acá por Gayo (pena contra el demandado recalcitrante), sino además porque eventualmente se puede responder por un valor superior al de la cosa dañada. Esto es así porque hay que considerar el "mayor valor" dentro del último año (o de los últimos 30 días), así, si el esclavo muerto quedó tuerto desde hace seis meses, hay que pagar el valor del esclavo como si estuviera íntegro. Y finalmente dice que es mixta la *incoada* contra los que, por legados o fideicomisos a las iglesias o entidades piadosas, retardan la entrega hasta ser demandados en justicia, ya que en ese caso serán condenados a la entrega de la cosa o suma legada, más otro tanto a título de pena, de tal modo que la condena es por el *duplum* (Inst., 4.6.19).

2. En un sentido distinto, Justiniano habla en Inst., 4.6.20, de acciones mixtas (*tam in rem quam in personam*) referidas a las acciones de partición (*actio communi dividundo**, a *familiae eriscundae** y a *finium regundorum**). Tal carácter surge de que en parte se adjudica a cada uno la parte que le corresponde en la cosa común (aspecto *in rem*), pero además, por lo que en más recibiere alguno queda obligado por una suma de compensación (aspecto *in personam*).

§ 94. *Acciones perpetuae y acciones temporales*. Las acciones que tienen su fundamento en el *ius civile*, es decir, las *acciones civiles*, por lo general, pueden ser ejercidas sin limitación de tiempo (*acciones perpetuae*). En cambio, las acciones que corresponden al derecho pretoriano son, por lo general, anuales (Gayo, 4.110; Inst., 4.12 pr.).

1. Para la época de Cassio (cónsul año 30 d.C.), todas las *acciones civiles* son perpetuas, así como también las honorarias reipersecutorias (caso de la *Publiciana**), mientras que las acciones penales honorarias son anuales (Paulo, D.44.7.35).

2. Respecto a las del *ius civile*, podemos anotar algunas excepciones. Así, la *actio auctoritatis*, concedida por la ley de las XII Tabas contra el enajenante que no fuera dueño de la cosa vendida, la cual fenecía al cumplirse los plazos de usucapión (Paulo, 2.17.1). También la ley *Furia de sponsu* liberó a los fiadores en Italia al cumplirse dos años (Gayo, 3.121). Igualmente, la acción prejudicial de la ley *Cicereia*, que expiraba después de los 30 días (Gayo, 3.123).

3. En cuanto a las acciones pretorianas, la regla es la anualidad, ya que el *imperium* del pretor sólo dura un año (Inst., 4.12 pr.). Si se iniciaba una acción fuera del año, el demandado tenía una *exceptio annalis* (EP, § 273). Es dudoso saber la forma de cómputo del año. Se habla de *annus utilis*, pero el problema es saber si se debía contar el año en forma continua (*annus utilis ratione initii*) o solamente computando los días útiles, es decir, sin contar aquellos en los cuales existió algún impedimento, ya de parte del actor, del demandado o del magistrado (Ulp., D.44.3.1: *annus utilis ratione cursus*).

4. Ya en la época de Gayo, algunas acciones honorarias, "imitando al *ius civile*", son concedidas a perpetuidad: así, las de los *bonorum possessores* y también la *actio furti manifesti*; esta última porque sustituyendo la pena capital de las XII Tabas, el pretor otorgaba una pena pecuniaria.

En la época posclásica, todas las acciones prescriben a los 30 años (Theodosio; CTh. 4.14.1; C.7.39.3; año 424), salvo la acción hipotecaria que en principio fue perpetua, pero Justiniano la declaró prescrita a los 40 años (C.7.39.7; año 525).

5. También prescriben a los 40 años las acciones en favor de las iglesias y fundaciones piadosas (Nov.111), notándose una prescripción de 50 años para la acción de repetición de deudas generadas en juegos prohibidos (C.3.43.1.2). El viejo sentido de perpetuas se sigue conservando para la *vindicatio in libertatem* (C.7.22.3) y para el reclamo fiscal de los impuestos (C.7.39.6), que de este modo resultan imprescriptibles.

CAPÍTULO 2

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ROMANO

PORTE PRIMERA

I. EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ANTIGUO. LAS LEGIS ACTIONES

§ 95. El primer procedimiento judicial fue el de las *Legis actiones*. Consistía en dos etapas: primero (etapa *in iure*) con la realización de ritos solemnes y la intervención de fórmulas orales que debían ser pronunciadas de manera escrupulosa ante el pretor —posiblemente en una época anterior ante el *rex*—, tras lo cual (etapa *apud iudicem*, o *in iudicio*) el caso era llevado ante un juez que era una persona privada (*iudex privatus*) que resolvía el litigio. En un comienzo el *iudex* es designado inmediatamente. Pero luego, por una ley *Pinaria*, se estableció un plazo de 30 días para dar el *iudex* (Gayo, 4.15).

1. La fuente principal en este tema son las Institutas de Gayo (4.11 ss.). Según él la designación de *legis actiones* (acciones de la ley) derivaba ya por el hecho de haber sido creadas por leyes, ya porque el rigorismo de las palabras empleadas era semejante a la redacción inmutable que tenían las palabras legales. Hay que aclarar respecto al establecimiento de estas vías por leyes, que por lo menos el *sacramentum* y la *manus iniecio* debieron existir con anterioridad a la ley de las XII Tablas. Igualmente, la *pignoris capio* estaba en algunos casos basada en las costumbres.

2. No hay que confundir la palabra *actio* con *legis actiones*. Por *actio* se entiende siempre la posibilidad de amparo judicial de una situación o posición jurídica en un caso determinado (así, la *rei vindicatio* en defensa del propietario quiritalio). En cambio, *legis actiones* hace referencia a las vías procedimentales solemnes por las cuales debe transitar la *actio*.

§ 96. Características generales: a) Las partes deben estar presentes, y si se trata de una *actio in rem*, también la cosa de ser ello posible, o al menos alguna parte representativa de ella (así, un terrón de tierra del fundo, el pelo del animal, una teja del edificio, etc.; Gayo, 4.17).

b) Sólo se puede actuar judicialmente en días determinados (*dies fasti*).

c) Las fórmulas orales, cuyos depositarios eran los Pontífices, consistían en palabras ciertas y solemnes (*certa et sollemnia verba*), que debían ser pronunciadas sin error, bajo sanción de perder el juicio. Gayo nos cuenta el caso, que debió ser un ejemplo antológico, de alguien a quien se le habían cortado viñas propias. Debía actuar por la *actio de arboribus succisis*, de tal modo que debía decir la palabra "árboles" (*arbores*); en su lugar dijo "vidas" (*vites*) y por ello perdió el juicio.

§ 97. Enumeración. Las *Legis actiones* contenciosas eran cinco: el *sacramentum*, la *iudicis* (vel *arbitrivis*) *postulatio*, la *condictio*, la *manus iniecio* y la *pignoris capio* (Gayo, 4.12).

1. Si hablamos de casos contenciosos es porque Gayo parece ampliar el número, incluyendo entre las *legis actiones* a la *in iure cessio* (2.24), así como también nos dice que el *consortium* artificial del cual habla en 3.154a se constituía por una *legis actio*, que no serían casos contenciosos. Además, menciona de los casos especiales del *damnum infectum* y del *sacramentum* que se desarrolla ante el Tribunal de los Centunviris (4.31) como si fueran casos especiales. Hacemos esta aclaración por la terminología particular empleada por Gayo. En general se aceptan las cinco vías ya señaladas para desarrollar el procedimiento.

2. En la terminología actual, las tres primeras vías (*sacramentum*, *iudicis postulatio* y *condictio*) son "declarativas", es decir, concluyen luego del conocimiento de la causa con una sentencia que declara cuál de las dos partes es la beneficiada por la situación jurídica. En cambio, las otras dos (*manus iniecio* y *pignoris capio*) son "ejecutivas", ya para hacer cumplir la sentencia ("ejecutar la sentencia"), y también, en ciertos casos, aun sin sentencia, para lograr el cobro de lo debido por determinadas obligaciones.

§ 98. Iniciación del procedimiento. El primer acto es la citación del demandado para que concurra en juicio. Esto tenía especial importancia dada la obligatoriedad de la comparecencia de ambas partes. Se realizaba por medio de la *in ius vocatio*. Es el propio actor quien la realizaba, conminando en la vía pública y en presencia de testigos al adversario para que comparezca.

1. Quien conminaba a otro lo hacía en forma solemne: *in ius te voco* (te conmino para que compares ante la justicia), o *in ius ambula* (marcha y ven ante la justicia); cfr. Plauto, *Persa*, 4.9.8 ss.

2. La ley de las XII Tabas era muy minuciosa: si se demoraba o no concurría resistiéndose, podía el actor poner la mano encima al adversario (1.1.2); si aducía que estaba enfermo o que por razón de edad no podía ir, se le daba un vehículo tirado por bestias de carga (*umentum*), o si lo quería el actor un carro cubierto (*arcera*); XII Ts. 1.2; Aulo Gell., 20.1.25 ss.

3. La presencia del demandado podía ser asegurada por terceros que garantizaban que efectivamente iba a ir (*vades*).

§ 99. I. *Sacramentum*. Es la vía más antigua para lograr que se reconozca judicialmente que se está en determinada posición o situación jurídica. Es también la más general y amplia de todas, puesto que todas las causas pueden llevarse a cabo por este camino, tanto si se trata de una *actio in rem* como de una *actio in personam*.

A) *Sacramentum in rem*. Por esta vía se puede discutir la situación de propietario, de la *patria potestas**, de la *manus** sobre una mujer casada, de la condición de heredero, de la libertad de un hombre, etc.

El procedimiento consiste en una mutua afirmación solemne de su posición jurídica (*vindicatio*), y dada la situación de paridad, una de las partes provoca a la otra al *sacramentum*, es decir, a arriesgar una suma de dinero que deben aportar ambas partes, tras lo cual se pasa el asunto al *iudex* para que pronuncie la sentencia.

1. El procedimiento lo conocemos bien gracias a Gayo (4.16): Nos pone el ejemplo de la reivindicación de un esclavo. Éste estaba presente, al igual que las dos partes, ante el magistrado.

Uno de ellos (acá, por las características del rito da lo mismo que sea cualquiera de los dos litigantes) hace una *vindicatio* en estos términos: "Yo digo que este esclavo es mío *ex iure Quiritum*". Según su causa, como lo he dicho, he aquí que te he impuesto la *vindicta*", y al mismo tiempo colocaba una varilla de mimbre (*festuca*), tocando al esclavo. Su adversario decía exactamente la misma *vindicatio* y también colocaba su varilla sobre el esclavo.

Intervenía entonces el pretor y decía: "Dejad libre ambos a este hombre". Ellos lo hacían así. El que había hablado primero preguntaba entonces al otro: "Pido que digas en virtud de qué causa has hecho la *vindicatio*", a lo que el adversario respondía: "Yo he hecho el *ius* (es decir, los ritos de adquisición del esclavo) así como yo he impuesto la *vindicta* (nombre que se daba también a la *festuca*).

Vista la paridad de ambos contendientes, entonces el que había hablado primero provocaba al *sacramentum* de este modo: "Puesto que tú has hecho la *vindicatio* de manera injusta (contra el *ius*), te provoqué al *sacramentum* de 500 ases". Y el otro respondía: "Y yo a ti".

§ 100. *Monte del sacramentum*. La pena del *sacramentum* podía ser de dos montos distintos: de 500 ases si el monto de lo discutido era de 1.000 ases o más, o de 50, si era de un monto inferior. En caso de que se estuviera discutiendo si un hombre era libre o esclavo, cualquiera que fuera el valor de éste, siempre se usaba el *sacramentum* de 50 ases (*favor libertatis*, Gayo, 4.14). La parte gananciosa del juicio recobraba la suma de su *sacramentum*; en cambio, la otra lo perdía, a título de pena, pasando al erario público (Gayo, 4.13).

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza del *sacramentum*:

a) para unos se trataba de un juramento recíproco de tal modo que los litigantes se exponían a la venganza de los dioses;

b) para otros era una apuesta, de tal modo que con ella se superaba, mediante el riesgo pecuniario, la aplicación de la mera fuerza que pudo estar presente en una etapa prejurídica. El inconveniente está en la propia denominación de *sacramentum* (palabra formada a partir de *sacer* = sagrado; Varro, *de ling. lat.*, 5.180), lo que no se ve en una mera apuesta. Por ello,

c) otros piensan que en una primera época, la *provocatio ad sacramentum* debió haber consistido en la entrega de cabezas de ganado (mayor o menor, lo que explicaría los dos montos posteriores). Éstos eran llevados ante los Pontífices, quienes ordenaban su sacrificio para poder leer en las entrañas de los animales, cuál era el *sacramentum iustum* y cuál el *iniustum*. Se trataba, en consecuencia, de una "ordalía" (en el Medioevo se utilizará el "juicio de Dios"), de tal modo que son los dioses los que dictan la sentencia. Luego, en una etapa posterior, se laiciza totalmente el procedimiento, y en lugar de los animales, éstos son reemplazados por los montos de dinero mencionados, de tal modo que como ahora no hay necesidad de sacrificio. La causa pasa ahora al *iudex*, quien deberá resolver por las pruebas traídas quien es el vencedor. Esto último, que sólo tiene una mera apariencia de apuesta, sería lo narrado por Gayo.

§ 101. *Poseción interina de la cosa*. El magistrado, antes de pasar el caso al *iudex*, debía resolver quién se quedaba con la posesión interina de la cosa (en este caso el esclavo). Aquel a quien se le acordaba, debía dar al otro seguridades por la cosa y sus frutos (*praedes litis et vindiciarum*). Saber por quién se inclinaba el

pretor, es un punto oscuro. Se puede pensar en una prioridad del poseedor actual, o quizá también en quien ofrecía una suma mayor en calidad de *praedes litis et vindiciarum* (Gayo, 4.16). Finalmente, la sentencia del *iudex* tenía la particularidad de que sólo indicaba cuál era el *sacramentum iustum* y cuál el *iniustum*.

1. En cuanto al cumplimiento de la sentencia tenía importancia quién se había quedado con la posesión interina. Podía ocurrir que: a) quien ganara fuera dicho poseedor; acá no hay problemas, pues ya tiene la cosa; b) pero si fuera vencedor el que no tenía la posesión, está discutido si el otro podía ser obligado a restituirla (v. Gayo, 4.48). Lo más probable es que el vencedor no poseedor ejecutara los *praedes*, de tal modo que el vencido pudiera optar, ya por restituírle el esclavo, o de lo contrario, tuviera que pagar las garantías.

§ 102. B) *Sacramentum in personam*. Acá no tenemos en las fuentes una descripción tan detallada como la anterior. Cabe pensar que el actor debía afirmar solemnemente que el otro le debía algo. Y luego de la negativa del adversario, el actor lo provocaba al *sacramentum*, en términos análogos a cuando se accionaba *in rem*.

§ 103. II. *Iudicis (vel arbitrius) Postulatio*. A diferencia del *sacramentum*, esta segunda vía era solamente para ciertos casos determinados. Así, cuando en virtud de la Ley de las XII Tabas se reclama lo adeudado por una *sponsio* (o una *stipulatio*). Y también, como lo establecía la misma ley, en caso de división de la herencia (*actio familiae erciscundae*). Más tarde, la *lex Licinia* la tornará aplicable para el caso de partición del condominio (*actio communi dividundo*); Gayo, 4.17a.

El procedimiento era más sencillo. P.ej., si se reclama una suma de dinero debida por una *sponsio*, el actor, en presencia del pretor, afirmaba tal circunstancia ante el demandado, y ante la negativa de éste de que debiera algo, el actor pedía al magistrado que se designara un *iudex* o un *arbitrator*.

1. Generalmente, el nombramiento de un *iudex* correspondería cuando se trataba de una *sponsio certae pecuniae*, interviniendo un *arbitrator* si el monto es un *incertum* (Gayo, 4.17a). También se debía nombrar un árbitro en el caso de las acciones de partición que se mencionan, puesto que más que una cuestión jurídica, se trataba de dar a cada uno de los litigantes, la justa parte que le correspondía.

§ 104. III. *Condictio*. Esta *legis actio* fue la última en aparecer. Quedó establecida por las

leyes *Silia* y *Calpurnia*. Por la primera para sumas determinadas de dinero, mientras que por la segunda para toda cosa determinada. La característica principal es que producida la contradicción el actor, en lugar de pedir inmediatamente un *iudex* emplaza al adversario para que dentro de 30 días estuviere presente para tomar un *iudex* (Gayo, 4.17b-19). El establecimiento de este plazo tendía a facilitar la solución del juicio, dado que durante él las partes podían llegar a un arreglo de la situación conflictual creada.

1. El trámite era así: el actor decía "Afirmo que tú me debes dar 10.000 sestercios; te pido que lo afirmes o que lo niegues". El adversario decía que no debía. El actor manifestaba: "Puesto que tú lo niegas, yo te emplazo para tomar *iudex* dentro de 30 días". Y entonces el día trigésimo debían estar presentes para tomar un *iudex* (Gayo, 4.17b). *Condicere* significaba en la antigua lengua *denuntiare* (Gayo, 4.18).

§ 105. *Las vías ejecutivas* I. *Manus iniectio*. Es la vía normal para ejecutar la sentencia condenatoria de una obligación. El actor llevaba al demandado ante el pretor, ante quien proclamaba que el deudor ya condenado no le había pagado la suma de dinero o la cosa debida, agregando que por tal razón le "ponía la mano encima".

Quien sufre la ejecución no puede hablar, pero podía aparecer un tercero que respondiera por él (*vindex*), con lo cual el procedimiento se detiene. Si el deudor no daba o no aparecía este *vindex*, era llevado por el autor a su casa y era encadenado. Esta situación duraba 60 días, y si no existía ninguna solución de pago, el procedimiento desembocaba en que el deudor condenado debía responder con su propio cuerpo, en calidad de esclavo (Gayo, 4.21).

1. El procedimiento aparece tratado con cierta minuciosidad en la ley de las XII Tabas (3.1 ss.):

a) El deudor condenado (*iudicatus*) o el que había confesado deber algo (*confessus*), tenía un plazo de 30 días para pagar.

b) Si ello no ocurría, sucedía la *manus iniectio* ante el pretor.

c) Si el deudor no pagaba, o no aparecía un *vindex* que respondiera por él, el actor lo lleva a su casa pudiendo encadenarlo, estando obligado a proporcionarle por lo menos dos libras de harina diarias.

d) El procedimiento quedaba suspendido 60 días. Durante este plazo el deudor podía llegar a un pacto con el acreedor. Igualmente éste debía llevar al deudor en tres días de mercado continuos ante el pretor en el Foro, proclamando públicamente el monto de la deuda. Esto tenía el sentido de enterar a otros acreedores, al mismo tiempo que darle oportunidad para que apareciera un *vindex* que respondiera por él.

3. Pasado este plazo, y no habiendo sido satisfecho el acreedor o acreedores, se llegaba al desenlace final. Este podía ofrecer esta alternativa: o se lo llevaba al otro lado del Tiber (*trans Tiberim*), como si allí fuera terreno extranjero; pudiendo ser vendido como esclavo; o "en el tercer día de mercado era cortado en partes. Si lo hubieran cortado en más o en menos, que ello no sea fraude" (XII T. 3.6).

2. Esta última solución era un enigma para los mismos romanos de la época de Aulo Gellio, para quien tomando la expresión literal del texto legal lo consideraba repugnante (20.1.52), estableciendo que no se recuerda ningún caso en que hubiera sucedido así. Se han dado varias explicaciones. Así, que se trataba de una intimidación legal para que se pagaran las deudas, con lo cual no se explica qué pasaba si no obstante ello el deudor no pagaba. Quizá hay que pensar que el verbo empleado: *secare*, más que en su sentido primero ("cortar"), hay que leerlo como "dividir", de tal modo que la división no es física, sino una atribución jurídica como esclavo por parte de los acreedores, que pasarían a ser sus *domini*. Siendo así, se explicaría la frase final sobre la no consideración de fraude ante una atribución proporcional incorrecta, como dando a entender que la situación debía quedar concluida, sin poderse alegar más situaciones problemáticas.

3. Este procedimiento nos habla de la responsabilidad absolutamente personal que nacía de la obligación primitiva, hasta tal punto que el deudor debía responder con su propio cuerpo. En tal sentido guarda relación con lo que ocurría en el negocio del *nexum*, en el cual el deudor automanicaba su propio cuerpo como garantía, por lo que ahora en la *manus iniectio* se ejecutaba el mismo.

§ 106. Casos especiales. La *manus iniectio* podía servir para ejecutar una sentencia condenatoria de una obligación. Pero había otros casos en los cuales, aun sin sentencia, se podía ejercitar esta vía, asimilándola a la del *iudicatus*. Así, en el caso de la deuda confesada (al confeso se lo tiene por ya condenado: *confessus pro iudicato habetur*).

Gayo (4.22) nos dice que otras leyes permitieron recurrir a esta forma de *manus iniectio pro iudicato*, es decir, sin ser necesaria la sentencia. Así, la ley *Publilia* la permitió al garante (*sponsor*) que hubiera pagado la deuda, contra el deudor principal que no le hubiera devuelto dicho monto dentro de los seis meses siguientes. También, la ley *Furia de sponsu* la permitió contra aquel que hubiera exigido del *sponsor* más de la cuota parte que le correspondía.

En otros casos, se habla de *manus iniectio* no asimiladas al caso del *pro iudicato*, por lo que se las llama "puras". Así, la ley *Furia testamentaria* contra aquel que, en contra de lo dispuesto por dicha ley, había recibido por lega-

do o por causa hereditaria más de 1.000 ases. Y también por la ley *Marcia* para obligar a los prestamistas que hubieran cobrado intereses usurarios a restituirlos.

1. En estos casos, —no si se trata del caso del *iudicatus*— una *lex Vallia* (circa comienzos siglo II?) permite al ejecutado desprenderse de la *manus iniectio*, actuando por sí mismo por la *legis actio* (Gayo, 4.25).

§ 107. II. *Pignoris capio*. Esta vía era muy excepcional, quedando admitida sólo en pocos casos, ya por motivos de costumbres o legales. El ejecutante podía actuar directamente, sin estar presente el pretor, y mediante el empleo de palabras rituales, se cobraba por mano propia lo que le debía el deudor (Gayo, 4.26-29).

1. Gayo, prácticamente nuestra única fuente, nos menciona tres casos de *pignoris capio* basados en las costumbres de los soldados: así, podía cobrarse de este modo aquel soldado a quien no se efectuaba la paga (*aes militare*); también, para cobrar el dinero asignado para comprar un caballo (*aes equisire*) y por el dinero destinado al forraje de los caballos (*aes hordiarum*); Gayo, 4.27.

Igualmente, permitida por las leyes, las XII Tablas la permitían contra aquel que comprara una víctima de sacrificio y no pagara el precio. Igualmente, para cobrar el alquiler de un jumento, siendo que el dinero estaba destinado a una ofrenda sacrificial. Finalmente, la *lex censoria* otorgaba esta vía a los "publicanos", respecto de aquellos que no pagaran al *populus* las sumas debidas por el uso de campos públicos (*vectigalia*); Gayo, 4.28.

2. Gayo (4.29) nos dice que se dudaba de que se tratara de una *legis actio*, ya que podía no suceder ante el pretor, y a menudo en ausencia del adversario, pudiendo ser llevada a cabo aun en un día nefasto. Sin embargo, permanecía el requisito de los *certa et sollemnia verba*, es decir, el recitado de una forma ritual (desconocida), lo que permite admitir que se debía llevar a cabo ante testigos.

PARTE SEGUNDA

II. EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO

§ 108. Las *legis actiones* se volvieron odiosas, como dice Gayo (4.30), debido sobre todo a su exagerado ritualismo. Es por ello que se reemplazó este procedimiento por otro, mucho más ágil y también mucho más apto para hacer una mejor justicia en cada uno de los casos concretos. La denominación de "formulario" se debe a que se redactaba una "fórmula" escrita adaptada a cada juicio (Gayo, *ibid.*).

§ 109. Origen. El procedimiento formulario parece ser que tuvo su origen en las causas habidas entre un ciudadano romano y un extranjero, o entre extranjeros, las cuales debían ser presentadas ante el "pretor peregrino", juicios en los cuales no se podía recurrir a las *legis actiones*. Hacia la primera mitad del siglo II a.C., entre el 149 y el 130, apareció la *lex Aebutia*, extendiendo el procedimiento a causas entre ciudadanos romanos, convirtiéndolo en procedimiento propio del *ius civile*, aunque limitándose en un principio a los casos en que se podía actuar por la última de las *legis actiones* cognitórias, es decir, la *condictio*.

1. El texto de la ley *Aebutia* nos es desconocido. La primera opinión vulgarizada por los romanistas (Wlassak, Girard, etc.) establecía que por esta ley se otorgaba una opción a los ciudadanos romanos. actuar por el procedimiento de las *legis actiones* o por el nuevo. De este modo, durante más de un siglo, es decir hasta las leyes *Iuliae*, los romanos habrían podido actuar por uno u otro procedimiento. Pero la objeción principal es cómo podía ser que los litigantes dudaran entre emplear el viejo procedimiento ritual ("odioso" según Gayo) y el nuevo, totalmente elástico y simple.

2. En cambio, hoy día se acepta más lo que nos dice otra parte de la doctrina (Eisele, Pflüger, Kaser, d'Ors, etc.), para la cual la ley *Aebutia* sólo habría sustituido los viejos ritos por la fórmula en los casos en que era aplicable la *condictio*. En esto pudo tener importancia la sustitución para juicios donde se discutían deudas dinerarias, siendo que los préstamos representaban para esta época un serio problema socio-económico.

3. En cuanto a su implementación, esta primera aplicación del procedimiento formulario sólo estaba referida a los *iudicia legitima* (son aquellos que tienen lugar en Roma o en un radio de una milla de dicha ciudad, entre partes que son ciudadanos romanos y celebrados ante un solo juez (*unus iudex*); Gayo, 4.104. La ley *Aebutia* dio carácter de "legítimo" a esta primera aplicación, acudiéndose a la ficción de que había tenido lugar una *legis actio* (v. Gayo, 4.32-33).

Para las otras causas del *ius civile*, subsiste entre ciudadanos romanos el procedimiento de las *legis actiones*, aunque por el empleo de la ficción vamos asistiendo a una ampliación más frecuente de actuar por la fórmula. En cambio, en las cuestiones del *ius honorarium* (principalmente en los *bonae fidei iudicia*), el pretor no encontró inconvenientes, por ser asuntos no propios del *ius civile*, para aplicar el nuevo procedimiento.

§ 110. Augusto reconoció la legalidad del nuevo procedimiento, y por medio de sus dos leyes *Iuliae iudiciorum privatorum y publico-*

rum (año 17 a.C.) se impuso como sistema obligatorio el formulario para ser aplicado en todas las causas (Gayo, 4.30).

1. Siguió manteniendo la clase de *iudicia legitima*, que se diferenciaban de los otros (*iudicia imperio continentia*) y que eran aquellos en los cuales no se cumplía con alguno de los tres requisitos ya expresados. Se habían en el *imperium* del magistrado, y a ellos correspondían los que se llevan a cabo ante los *recuperatores*, o interviniendo un único juez, una de las partes o dicho juez era un extranjero o aquellos que se celebran fuera de una milla de Roma (Gayo, 4.105).

La diferencia, según la ley *Iulia*, estriba en que el *iudicium legitimum* "expira" en el plazo de un año y seis meses, mientras que el *iudicium imperio continens* caduca al cesar en su cargo anual el magistrado (Gayo, 4.104-106).

2. De este modo, este procedimiento formulario, que fue el típico de la época clásica, y el más eficiente para alcanzar los grandes logros jurídicos del Derecho Romano, coexistió durante más de un siglo con el viejo procedimiento de las *legis actiones*. Sólo en pocos casos se siguió actuando por los ritos antiguos; así, en el caso de celebrarse el juicio ante el Tribunal de los Centumviro, y también —aunque no se lo prefería— en el caso del "daño temido" (*damnum infectum*), Gayo, 4.31. Ya desde la época de Hadriano, el procedimiento formulario tuvo la fuerte competencia del procedimiento *extra ordinem*, que finalmente se impondrá en la época posclásica.

MARCHA DEL PROCEDIMIENTO FORMULARIO

Este procedimiento, continuando lo ya puesto en práctica en las *legis actiones*, divide el juicio en dos etapas: la primera ante el magistrado (*in iure*) y la segunda ante el *iudex* (*apud iudicem; in iudicio*).

I. Procedimiento in iure.

§ 111. A) *Iniciación del procedimiento*. Es el actor quien debe conminar al demandado a comparecer, utilizándose la *in ius vocatio* (Paulo, D.2.4.1), pero a diferencia de la época antigua, no se utiliza la fuerza ante la resistencia del accionado.

El actor debe extraprocesalmente notificar al adversario sobre la acción que intentará, así como la documentación que adjuntará contra él, entregándole un libelo donde se le aclare en qué consistirá el juicio, o permitiendo que el demandado saque una copia. A esto se llama *edere actionem*, y el acto *editio actionis* (Labeo-Ulp.,

D.2.13.1.1). Esto servía para que la contraparte estuviera totalmente enterada del juicio, de tal modo que pudiera preparar su defensa, o en su caso llegar a un avenimiento antes de la presentación ante el magistrado. Se puede exigir al demandado una garantía de que se presentará (ya un *vindex* solvente, o un *vadimonium* por el cual se compromete por un monto a presentarse).

1. El *vindex* se compromete a la asistencia del demandado. Si ello no ocurre, el pretor concede una *actio in factum* contra dicho garante (Gayo, 4.46). En caso de haber prestado el *vadimonium* al demandado o un tercero, él se realizaba sobre una *stipulatio* donde se establecía la pena (semejante al caso de los *vadimonia* para el caso de que el juicio requiera nuevas comparecencias), dando lugar a la *actio* nacida de la *stipulatio*.

2. Si el juicio no terminaba el mismo día, el demandado tenía que ofrecer nuevas garantías de que seguirá compareciendo (*vadimonia*; Gayo, 4.184). En algunos casos, estos *vadimonia* se hacían en forma "pura", es decir, con una simple promesa sin dar caución. En otros con caución; en otros con juramento (*iururandum*); en otros con interposición de los *recupratores*, de tal modo que si no se comparece es condenado por éstos por el monto del *vadimonium* (Gayo, 4.185; EP, §§ 17-24).

3. Hay ciertas personas contra las cuales no se puede dirigir la *in ius vocatio* sin permiso previo del pretor. Así, los ascendientes, los patronos o patronas o los descendientes de éstos (Gayo, 4.184; Ulp., D.2.4.4.1). Tampoco se puede citar en juicio a los magistrados, ni al Pontífice cuando está celebrando actos sagrados, ni al que se esté casando, ni al que preside un entierro familiar, etc. (Ulp., D.2.4.2). En caso de contravenir esto, se concede una acción *in factum* condenando al infractor con una multa fija (Gayo, 4.46, quien habla de 10.000 sesteracios para el caso del liberto que hubiera citado *in ius* a su patrono). Luego se establecerá para este caso de falta a la *reverentia* de una pena de 50 áureos (Ulp., D.2.4.24; Calístrato, D.2.6.2; en Inst., 4.16.3, se habla de 50 sólidos, que es el mismo valor).

El demandado que no obstante las garantías dadas no se presenta, se hallará en situación de "indefenso" (*indefensus*). El pretor no podrá librar la fórmula construyendo al demandado a defenderse, pues éste queda libre de no hacerlo (Paulo, D.3.3.45 pr.). Pero, a pedido del actor, el pretor procede a embargar los bienes del *indefensus*, otorgando la posesión de ellos al actor (*missio in bona rei servandae causa*, Gayo, 3.78; EP, § 202).

4. Lo mismo ocurre en el caso de una *actio in rem* (por fórmula petitoria) cuando el demandado se niegue a dar la *cautio iudicatum solvi* (por la cual se obliga a defenderse debidamente, a cumplir la conde-

na y abstenerse de todo acto doloso, Gayo, 4.91; Ulp., D.46.2.6).

5. Esta posesión es para mantener preservada la cosa a los efectos de la sentencia. Esto ocurre normalmente en el caso de que el demandado se presenta y no se defiende. Pero en el caso de que el demandado se esconda para no ser citado en juicio, o una vez citado se niegue a comparecer, la *missio in bona* conduce generalmente a la venta de los bienes (*bonorum venditio*); Gayo, 3.78; Ulp., D.42.4.7.16, citando decreto de Adriano respecto de una *actio in rem*.

§ 112. B) Partes del procedimiento. Las partes que están en el juicio (*lis, controversia*) son el demandante o actor (antes de la *litis contestatio* es "el que quiere actuar" —*is qui agere vult*—, luego es directamente el actor) y el demandado (*reus*).

Pero en el procedimiento formulario —a diferencia de lo que ocurría en las *legis actiones*— los litigantes pueden nombrar sus representantes. Éstos no actúan en "representación directa" de alguna de las partes, de tal modo que asumirían ellos directamente los efectos de la sentencia. Por técnicas especiales, estas consecuencias judiciales, favorables o desfavorables, pueden, según los casos, ser transferidas a los representados.

Hay dos formas de designar un representante, tanto para el actor como para el demandado: a) el *cognitor*, nombrado públicamente en presencia del adversario; y b) el *procurator*, nombrado sin esta formalidad. Los incapaces están representados por sus tutores o curadores y las corporaciones por sus actores.

1. En las *legis actiones*, ambas partes debían estar presentes en forma necesaria (Ulp., D.50.17.123 pr. "Nadie puede accionar en nombre de otro, por la ley"), pero se admitían algunas excepciones (Gayo, 4.82). Así, cuando se actuaba por una *actio popularis*, ésta podía ser intentada por cualquier ciudadano; cuando se acciona *pro libertate*, es decir, cuando se discute la libertad de alguien, era necesaria la presencia de un defensor de la libertad —aunque no es parte propiamente dicha— (*adsertor libertatis*); cuando se actuaba en virtud de una vieja ley *Hostilia* para el caso de *furtum* respecto de un romano tomado prisionero, o ausente por interés público (Inst., 4.10 pr.). Se cita también el caso del tutor (Inst., *loc.cit.*), pero el problema es bastante oscuro. Si el tutor acompaña con su *auktoritas* al pupilo, es éste quien actúa. Y si el tutor obra por la *gestio*, lo hace en nombre propio (*suo nomine*), y no *pro pupillo*.

§ 113. El *cognitor* es dado por el actor o el demandado, por medio de palabras especiales y en presencia del adversario. Así: "Puesto que te reclamo p.ej. un fundo, te doy a Lucio Ticio como mi *cognitor* en este asunto" (caso del ac-

tor). O "puesto que tú me reclamabas un fundo, te doy como mi *cognitor* en este asunto a Publio Mevio" (Gayo, 4.83).

La fórmula seguirá la técnica de la "trasposición de personas", de tal modo que en la *intentio* figura el nombre del "dueño del asunto", y en la *condemnatio*, el nombre del *cognitor*. Como la sustitución es plena, la acción se consume totalmente. Pero la ejecución (*actio iudicati*), aunque la sentencia recaiga en favor del *cognitor*, le será otorgada al "dueño del asunto", ya en su favor si hubiera resultado vencedor o en su contra, si hubiera sido condenado (FV., 317; 331).

1. Si quien da un *cognitor* es el actor, ninguno de los dos debe dar ninguna caución, ya que dado que la sustitución procesal se operó por "palabras especiales y cuasi solemnes", en presencia de la otra parte, no cabe ninguna duda acerca de que el *cognitor* es el representante (Gayo, 4.97).

2. Pero si quien da un *cognitor* es el demandado, el dueño del asunto debe dar una garantía (*cautio iudicatum solvi*), de que cumplirá la sentencia en caso de ser condenado, aplicándose la regla genérica de que "se considera que nadie puede ser defensor idóneo de un asunto ajeno sin dar caución" (Gayo, 4.101).

3. Justiniano suprimirá la figura del *cognitor*, sustituyéndolo en todos los casos, con las debidas interpolaciones, por la figura del *procurator*.

§ 114. El *procurator* aparece porque en determinadas circunstancias (enfermedad, viaje, edad, etc.) no se podía dar un *cognitor*. No había formas especiales para dar un *procurator*, ya como actor o como demandado, pudiendo hacerse el nombramiento en ignorancia o ausencia del adversario. Más aún, alguien, de buena fe, se podía presentar como *procurator* aun no habiendo mediado mandato del dueño del asunto, garantizando que sus actos serán ratificados luego por éste.

Como se puede comprender, era siempre dudoso saber si el que se presentaba como *procurator* había o no sido debidamente apoderado para intervenir en el juicio, por lo que se exigían seguridades concretas y especiales.

Si el *procurator* aparecía como representante del actor, como la sustitución (a diferencia de lo que ocurría con el *cognitor*) no es plena, la acción no se consume para el dueño del negocio, quien luego podría intentar de nuevo la acción. Por ello, el propio *procurator* debía prestar una caución (*cautio dominum rem ratam habiturum*, llamada más brevemente *cautio de rato*) de que el dueño del asunto ratificará lo actuado por él, y que no intentará demandar de nuevo por el mismo juicio en el supuesto de que la sentencia

le sea desfavorable (Gayo, 4.98). Si no la prestaba el pretor lo podía coaccionar denegándole la acción.

A su vez, si el *procurator* aparece como representante del demandado, en caso de ser condenado se corre el peligro de que el dueño del asunto no ratifique sus actos y que el *procurator* sea insolvente. Por ello, es también el propio *procurator* (y no el dueño del asunto, como ocurría con el *cognitor*) quien debe dar fianza (*cautio iudicatum solvi*) de que cumplirá la sentencia condenatoria (Gayo, 4.101).

En todos los casos, la *actio iudicati* no es dada al mandante o contra él, sino en favor o en contra del *procurator* (FV., 317).

1. La jurisprudencia posterior admitirá que si el *procurator* ha sido presentado personalmente a la otra parte (*procurator praesentis*), o consta de otro modo su carácter procesal (así, en un acta, *apud actam factum*), entonces queda equiparado al *cognitor*.

2. Respecto del *procurator* se aplicarán las mismas reglas de fórmula "con trasposición de personas".

3. En el caso de los tutores, curadores si actúan como actores deben dar en principio caución, pero en algunos casos se los exceptúa de ella (Gayo, 4.99; Inst., 4.11 pr.). Así, si el negocio litigioso había contado con su *auktoritas*, pero no si fue realizado por su *gestio* (Ulp., *loc.cit.*, 26. 39). Si el actor es demandado, deben siempre dar caución (Gayo, 4.101).

4. La representación de las corporaciones era llevada a cabo por sus representantes (actores), así, en el caso de los municipios, por sus *duumviri*. Su posición queda asimilada a la del *cognitor* de una persona particular.

§ 115. C) Actuación ante el magistrado. Ante el magistrado, el actor, en presencia del demandado debía renovar su *editio actionis* (que el demandado ya conocía en la etapa previa), manifestando lo que pide y solicitando al pretor que éste le conceda una determinada acción (*postulatio actionis*).

El magistrado escucha al actor, lo mismo que al demandado, estando las declaraciones libres de formalidades. Si el pretor advierte que lo pedido por el actor se ajusta a lo prescrito en alguna de las acciones que figuran en el Edicto, entonces la concederá (*datio actionis*). Si no está en el Edicto, la podrá rechazar; no obstante lo cual, si entiende que lo que ha pedido el actor merece amparo y protección jurídica, entonces, a pedido del demandante le puede otorgar una *actio in factum*, para ese caso concreto.

§ 116. Si el pretor comprueba que la situación jurídica del actor no merece protección, entonces le deniega la acción (*denegatio actio-*

nis). Lo mismo ocurre si comprueba que carece de competencia jurisdiccional o si fallan los presupuestos jurídicos para la actuación de las partes.

1. Por competencia jurisdiccional. A) Así, el pretor puede carecer de "jurisdicción" (*iurisdictio*). P.ej., si se trata de uno de los casos que deben tramitarse *extra ordinem*, o se trata de un asunto penal o administrativo; esto era resuelto por el pretor antes de la iniciación del procedimiento, o inmediatamente que tuviera noticias de ello.

B) También el pretor puede carecer de competencia por razón de la materia. Esta queda determinada en cada caso en particular. Así, cuando existe la posibilidad de elegir entre varios magistrados, la competencia está fijada por el domicilio del demandado (regla: *actor sequitur forum rei*). Pero con algunas excepciones: así, si se trata de una obligación, el lugar fijado para el cumplimiento de ella (*forum contractus*); si se trata de un delito, el lugar de comisión (*forum delicti commissi*); la regla del *forum rei sitae* (lugar donde está la cosa) para las acciones *in rem* es tardía (C.3.19.3, año 385).

2. Por falta de la "capacidad procesal". A) En principio todos los *sui iuris*, ciudadanos romanos o extrangeros tienen lo que en lenguaje procesal actual se denomina "legitimación activa y pasiva", es decir, el poder estar como actor o demandado en un juicio.

Los esclavos están excluidos. Los *filiifamilias* pueden actuar en lo que atañe a su *peculio castrense*, o por la *actio iniuriarum*, o en caso de ausencia de sus padres, representándolos a éstos. Las mujeres *sui iuris* pueden actuar con la *auctoritas* de su tutor. Algunos casos especiales carecían de la *postulatio actionis*: los menores de 17 años y los sordos, o de postular por otros: las mujeres, los ciegos y ciertas personas caracterizadas como *ignominiosae* (infames).

3. En ciertos casos se tornaba necesario previamente aclarar la "legitimación activa o pasiva". Así, cuando se actúa como o contra herederos, o en el supuesto de acciones noxales*. Como podían existir dudas, se utilizaba una interrogación previa entre las partes (*interrogatio in iure*); así, preguntar si el actor o el demandado es heredero de Ticio, y en qué proporción; si se es el *pater* o *dominus* del autor de un delito, etc.

§ 117. Posiciones que puede asumir el demandado. Durante la tramitación del juicio el pretor tiene también oportunidad de escuchar al demandado, quien puede adoptar diversas posiciones.

1. Reconocer la legitimidad plena de lo pedido por el actor. Esto significa que se allana a la demanda (*confessio in iure*). En este caso, no hay razón para continuar con el procedimiento. Al *confessus* se lo asimila al ya juzgado y condenado (*iudicatus*). XII Ts. 3.1, regla *confessus*

pro veritate habetur (al que ha confesado, se lo tiene como que ha dicho la verdad). Procede en consecuencia contra él la ejecución, por lo demandado, si bien en algunos casos habrá que determinar por un procedimiento estimatorio el monto de lo debido.

II. Oponerse a lo pedido por el actor. En este caso el demandado niega la posición jurídica que sirve de base a la *actio civilis*, o niega los hechos en que se basa la *actio honoraria*. En ambos casos, ha manifestado su voluntad de continuar adelante el juicio, que será dilucidado en la sentencia.

1. Se puede también pedir que la suerte de la cuestión quede resuelta sometiéndola al juramento (*iusiurandum voluntarium*) de la otra parte, la cual debe aceptarlo, ofreciendo atenerse a lo que se jure (*iusiurandum deferre*). Si el juramento es dado por el actor, le abre la vía de una *actio ex iure iurando*. Si lo presta el demandado, podrá oponer a la acción del actor, si ésta no es denegada, una *exceptio iursiurandi*. El *iudex* tendrá en cuenta el solo hecho del juramento sin entrar a verificar su veracidad o falsedad (Ulp., D.12.2.11.1; id. 3 pr.; id. 7).

2. Para el caso de reclamo de una suma determinada (*certa pecunia*) y luego también para el de una cosa determinada (*certa res*), el actor podía, autorizado por el pretor, provocar el juramento del demandado, ya no voluntario, sino obligatorio para éste (*iusiurandum necessarium*), poniéndolo en la alternativa de que jure que nada debe o referir recíprocamente el juramento del actor (*iusiurandum referre*) para que jure que efectivamente le debe y cuánto es el monto de la deuda. Estos juramentos son decisivos, de tal modo que con ellos se zanja la cuestión planteada, abriéndose, en su caso, la ejecución. En su momento se determinó que si el demandado rehúsa jurar, y no refiriere el juramento al actor, se lo consideraba *indefensus* (Diod., C.4.1.9).

3. Puede llamar la atención esta provocación al juramento, sobre todo en nuestra época actual, en la cual esta práctica resultaría más que peligrosa debido a la desvalorización del juramento. Pero ello no sucedía así en Roma. Por ello, Gayo (D.12.2.1) habla del "mayor remedio para terminar los pleitos": el recurrir a la "santidad del juramento".

III. Oponer una excepción. El demandado puede también no discutir la posición jurídica del actor, pero alegar que por alguna circunstancia ocurrida, apta para el *ius civile* o para el *ius praetorium*, merezca protección para detener la eficacia de la acción, pidiendo al pretor que le conceda una *exceptio*.

1. En este caso, si lo considera equitativo, el pretor accede a la acción, pero la fórmula se modifica

en cuanto que se intercala la *exceptio*, que de probarse y triunfar, detendrá el progreso de la *actio*.

IV. Mantener una posición pasiva sin decir nada. En este caso el demandado no discute, pero tampoco reconoce la posición jurídica del actor, sin solicitar tampoco la inserción de una *exceptio* en la fórmula.

1. Si se trata de una *actio in rem*, el demandado no queda constreñido a trabar el juicio, ya que por esta acción lo que se pide es un poder sobre la cosa o situación jurídica, y no sobre la persona del demandado, quien puede desistirse de su posición. El pretor le otorgará al actor ya una *actio ad exhibendum* (para que se muestre la cosa reclamada) o interdictos para entrar en posesión (*quem fundum, quem usufructum, quam hereditatem*).

2. En cambio, si se trata de una *actio in personam*, el demandado está obligado a trabar el juicio. Si no lo hace estará en situación de *indefensus*. Queda expuesto a que el pretor lo amenace con facultar al actor para constituir al deudor en prisión privada (*ductio*), así como también a pedido del actor, que el magistrado ordene el embargo de los bienes del deudor (*missio in bona*). No era necesario para ello que se probara nada. El actor, que puede aprehender los bienes, no los puede ejecutar hasta tanto tenga un título válido como la sentencia condenatoria. Era, pues, una medida pretoriana para incitar al demandado a defenderse en el juicio.

§ 118. D) Decreto de *iudicium dare*. Nombramiento del *iudex*. Libramiento de la fórmula. Una vez examinadas las cuestiones traídas por las partes, el pretor debe resolver si da la acción (*datio actionis*) o la deniega (*denegatio actionis*), así como la *exceptio* u otras defensas procesales. Por ello dicta un decreto de *iudicium dare*, y redactará la fórmula, en la cual quedan fijadas todas las cuestiones disputadas. Igualmente, nombrará al *iudex* a quien pasará la causa para fijar la sentencia.

1. El pretor solía invitar a los litigantes a llegar a una *transactio* para evitar la continuación del juicio. Mediante ella las partes se hacían concesiones que hasta podían ser recíprocas. La transacción generaba un pacto que daba lugar a una *exceptio* al que fuera demandado en contra de lo ya transado.

2. Las partes pueden pedir que su adversario preste juramento de que no está actuando conscientemente de que no tiene razón (*iusiurandum calumniae*). Así, el actor podía ser exigido de prestar juramento de que no litigaba con ánimo de calumnia, por el solo hecho de vejar al demandado, intentando la acción por temeridad (*non calumniar causa agere*; Gayo, 4.176), mientras que el accionado, en ciertos casos, debía jurar que no se oponía de manera capri-

chosa (*non calumniae causa infitias ire*; Gayo, 4.172). Si no se prestan estos juramentos, se puede provocar el *iudicium calumniae* (infra, § 122.c).

§ 119. *Iudex*. a) Juez único (*unus iudex*). Siendo el juicio en Roma un *iudicium privatum*, en principio las partes pueden ponerse de acuerdo en nombrar a una persona que actuará como *iudex*, la cual resultará elegida como tal, siempre que reuniera ciertas condiciones básicas (ser varón púber, no ser un insano ni un infame).

Si no había acuerdo entre las partes, se recurría al *album iudicum*, que era una lista oficial de jueces. El pretor podía ir proponiendo nombres que debían ser aceptados por las partes. En último caso, de no haber acuerdo, el pretor lo designaba mediante un sorteo de los que figuraban en la lista.

El *album iudicum* estaba formado por nombres de ciudadanos del orden senatorial y también del orden de los caballeros (*equites*), estableciéndose cada pretor para el año de su magistratura. Desde la ley *Aurelia* (año 70 a.C.), la lista se componía de 900 nombres (300 por cada *decuria*: una de senadores, otra de caballeros y una tercera de *tribuni aerarii*). Esto sufrió sucesivos cambios, estando en la época imperial integrada por el Príncipe.

b) *Recuperatores*. Fuera del caso del juez único (*unus iudex*), existía el tribunal de los *recuperatores*, que era colegiado. Su origen se encuentra en la dilucidación de conflictos internacionales. Así, se decía que existía una *recuperatio* (latín antiguo: *reciperatio*) cuando entre el *populus* romano y otro pueblo se concluía un tratado, determinando el modo por el cual los ciudadanos de uno u otro pueblo contratante se harían devolver y recuperarían sus intereses privados (*Festo v. reciperatio*). Luego estos *recuperatores* se ocuparían de determinados asuntos: procesos de libertad, delitos de lesiones o con violencia, reclamos por excesos de los publicanos y ciertas acciones pretorias como la citación procesal. Su número era siempre impar (generalmente 3; a veces 5; Cic., *in Verr.*, II. 2. 12. 60; Tito Livio, 43.2). Parece ser que la costumbre era que cada una de las partes eligiera uno y el pretor determinaba el tercero (Tit.Liv., 26. 48).

c) Tribunal de los *Centunviri*. Aparece en la segunda mitad del siglo II a.C. Estaba formado por 105 miembros (3 por cada una de las 35 tribus). En la época de Trajano, alcanzaron a ser 180. Estaba presidido por un *praetor hastarius*, y dividido en cuatro secciones (*consilia o hastae*). Esta denominación proviene de la lanza (*hasta*) que se fijaba en el suelo cuando se reunía el tribunal (Gayo, 4.16, *in fine*). Actuaban principalmente en cuestiones de propiedad, familia y herencia. Se podía actuar por el *sacramentum* (Gayo, 4.31).

d) *Decenviri litibus iudicandis*. Poco sabemos de ellos. Era un tribunal de 10 jurados e intervenían en las causas de libertad. Desde Augusto pasan a presidir las comisiones del Tribunal de los Centunviri.

e) En Italia, juzgaban los consulares y *iuridici*, mientras que en las provincias lo hacían los gobernadores (*praesides* y *procónsules*).

§ 120. E) *Litis contestatio*. Una vez que las partes están de acuerdo en celebrar el *iudicium*, el pretor, como hemos visto, fija la fórmula a la que se deberá resolver la cuestión jurídica por el decreto de *iudicium dare*. Este momento es el punto central del procedimiento *in iure*, y es llamado *litis contestatio*.

1. Recibe su nombre de la época de las *legis actiones*, cuando las partes reclamaban los testigos (*testes estoite* = "sed testigos"); de allí se forma la palabra *litis contestatio* (atestiguamiento del litigio).

La *litis contestatio* produce determinados efectos:

1. Las partes quedan vinculadas según los términos de la fórmula a la dilucidación del pleito conforme a la sentencia.

2. Produce un efecto preclusivo, lo cual quiere decir que el actor no puede variar la forma como ha presentado su petición y tampoco el demandado podrá, en principio, presentar nuevas excepciones (ver, sin embargo, *infra*, § 133.2). El litigio ha quedado trabado en los términos de la fórmula (en lenguaje actual, se dice "traba de la litis").

3. La cuestión litigiosa se convierte ahora en el objeto del *iudicium*, de tal modo que para el actor se produce la "consumición de la acción", ya que lo que ha peticionado se ha transformado en "el asunto introducido en el juicio": *res in iudicium deducta*. Ya ha agotado su *actio*, de tal modo que no puede iniciarse sobre la base de ella un nuevo juicio (regla: *bis in eadem re agere non potest* = "no se puede accionar dos veces sobre el mismo asunto"); o más simple: *non bis in eadem* = "no dos veces en lo mismo".

1. Este efecto opera de manera distinta según las características de la acción.

Así, en el caso de una *actio in personam*, y sólo si se trata de una fórmula redactada conforme al *ius civile* (*in ius concepta*) en un *iudicium legitimum*, es decir, dándose estos tres requisitos el crédito del actor se extingue (trasvase en la fórmula *ipso iure* luego de la *litis contestatio*, de tal modo que el mismo pretor denegará la petición de una nueva acción que verse sobre el mismo asunto).

En cambio, en los otros casos, es decir, si se trata de una *actio in rem* (y también si es *in personam* redactada *in factum*, o en juicios *imperio continencia*), el efecto de consumición de la acción no se produce *ipso iure*, como en el caso anterior, pero se le permite al demandado oponer una excepción en

caso de intentarse un nuevo juicio sobre lo mismo (*exceptio rei in iudicium deductae*).

En realidad, su denominación es *rei iudicatae vel in iudicium deductae*, pero acá opera la segunda parte de ella. Lo que sería la *exceptio rei iudicatae* es para el supuesto que se pretendía iniciar el nuevo juicio por lo mismo luego de dictada la sentencia. Es decir, si el actor pretende el nuevo inicio, luego de la i.c., pero antes de la sentencia, corresponde la excepción *rei in iudicium deductae*; y si lo quiere efectivizar luego de la sentencia la *exceptio rei iudicatae* (de cosa juzgada).

2. La cuestión de si la nueva acción es la misma que la anterior fue resuelta por los juristas en cada caso concreto. En principio existía la triple identidad: de personas (*easdem personae*), del mismo asunto (*eadem res*) y de la misma petición (*eadem causa petendi*). Lo relativo a este lema, lo tratamos luego con el efecto de la "cosa juzgada" en la sentencia.

3. En el caso de los efectos de "consumición de la acción" se suele hablar de "novación necesaria".

II. Procedimiento apud iudicem.

§ 121. La tarea del iudex. Una vez establecida la fórmula, y operada la *litis contestatio* termina la actuación del magistrado, y el asunto debe pasar al *iudex* (o al colegio judicial designado por el pretor). Éste está obligado a tener que respetar los términos de la fórmula que ha recibido. En ella están, en principio, ordenadas las "cuestiones de derecho" (*quaestiones iuris*), de tal modo que ante él las partes deberán aportar las pruebas de favor de cada posición, y de cada hecho implicado (*quaestiones facti*), dando su decisión en la sentencia.

1. Pese a ser privados, los jueces deben cumplir obligatoriamente su cometido (*munus personae*), aunque pueden excusarse por motivo fundado (así, por enfermedad, o por causa de sacerdocio; Ulp., D.50.5.13 pr.). Antes de comenzar su actuación deben prestar juramento de que actuarán conforme al *ius* y a la verdad.

Si descuida su función apartándose de lo que se dice en la fórmula, se entiende que "hace suya la causa" (*litern suam facit*), dándose contra él una *actio in factum* (EP, § 59); con Justiniano será uno de los casos de cuasidelitos.

En caso de no ver clara la cuestión de a quién le asiste la razón, le estaba permitido quedar libre de su oficio mediante juramento de que "no lo ve claro" (*rem sibi non liquere*). Sin embargo, debemos recordar que las partes podían siempre recurrir al juramento.

2. Los jueces realizaban su cometido en el *comitium*, o en el lugar que se hubiera convenido. Debían estar presentes las partes. Si una estaba ausente, su

situación, por no haber podido alegar, le era perjudicial. No existe la "rebeldía" en el sentido actual, pero la sentencia se podía dictar contra el demandado ausente, estando a las pruebas traídas (la expresión *adversus absentes pronuntiari*; D.48.19.5 pr., debe ser entendida como que se puede pronunciar la sentencia contra el ausente, pero no que necesariamente la sentencia debía ser "contra" el ausente).

3. Las partes realizaban primero una breve exposición de la causa. Esto ya era empleado en las *legis actiones* y conocida como *causae coniectio*, realizándose luego los alegatos. Para ello se podía llevar un orator que pronunciara una defensa de los intereses y de la posición jurídica de su cliente, analizando las pruebas. Ésta fue una de las tareas predilectas de Cicerón, que no era un *prudens* (que entendía el *ius*), sino un orator que manejaba la retórica, o sea, el arte de convencer por el razonamiento y la elocuencia.

4. Siguiendo el viejo principio de las XII Ts. (1.7-9), el juicio debía ser tramitado en un solo día, dictándose la sentencia antes de la caída del sol, pero se admitía un aplazamiento de la vista de la causa para un día determinado.

5. En general, las cuestiones que debía resolver el *iudex* son "de hecho", pero si hubiera alguna implicancia jurídica podía recurrir a los juristas, dado que no suelen conocer el *ius*. Las partes deben abstenerse de probar el *ius* al juez (sin embargo, el principio actual *iura novit curia* no es romano).

Todas las actuaciones ante el *iudex* son orales (principio de oralidad), públicas (principio de publicidad) y directas ante él (principio de inmediación). Respecto de la apreciación de las pruebas es totalmente libre de fijar su criterio (su "sentir").

1. Respecto de la "carga de la prueba" (*onus probandi*), aunque no hay reglas fijas, corresponde a quien haya afirmado cada uno de los hechos ("incumbe la prueba a aquel que dice, no a aquel que niega"; Paulo, D.22.3.2; Marciano, id. 21), por lo que normalmente el actor deberá probar sus peticiones, y el demandado lo que haya introducido como excepción.

2. Las pruebas podían consistir en cualesquiera de los medios usuales: a) la confesión, o el resultado del juramento; b) los testigos (no hay reglas sobre el mínimo: podía ser uno solo); c) los documentos (*instrumenta*), ya por declaraciones extrajudiciales de testigos escritas sobre tablas de cera, o los libros de los banqueros (*argentarii*), el documento escrito de la *stipulatio* (*cautio*), etc.

3. Respecto de las "presunciones", es decir, determinadas situaciones por las cuales se dispensa de la prueba en ciertos hechos que no necesitan ser probados porque la experiencia demuestra su veracidad, en el Derecho Clásico no hay reglas precisas, no existiendo presunciones legales (*iuris et de iure*, es decir,

que no admiten pruebas en contrario), si bien existen ciertas reglas que desde la época posclásica, son llamadas presunciones (p.ej., la de *conmiserencia*: si conmuera hijo y padre, se presume primero la de éste); o la de que debe entenderse por "padre" en las *iustas nuptiae*, el marido casado con la madre en este matrimonio legítimo; son *iuris tantum*, es decir, que admiten la prueba en contrario.

§ 122. La sentencia. El oficio del *iudex* culmina con la sentencia, donde expresa su decisión. En las *actiones in personam*, dirá que condena (*condemno*) o que absuelve (*absolvo*) al demandado. En las *actiones in rem* (con cláusula arbitraria) la condena no versa sobre la devolución de la cosa, sino que siempre es pecuniaria (Gayo, 4.48). El juez debía previamente hacer la *pronuntiatio*, para que el demandado opte por restituir lo reclamado o ser condenado por la cantidad estimada y jurada por el actor (*litis aestimatio*). En las acciones divisorias emplea la palabra "adjudico" (*adiudico*).

1. La condena puede quedar agravada en determinadas circunstancias:

a) En algunas acciones, como pena al demandado recalcitrante (*infilians*), es decir, que no ha reconocido la razón del actor, que es el que triunfa, deberá pagar el *duplum* (caso de la *actio instauratio*, de la *actio depensi*, de la *actio legis Aquiliae*).

b) Cuando en la *condictio* las partes se cruzan promesas de pagar una suma adicional en caso de perder el juicio: así, la *sponsio** (del demandado) *et restipulatio* (del actor) *tertias partis* (por la tercera parte); o en la *actio de pecunia constituta* por la mitad (*dimidia partis*); Gayo, 4.180.

c) Cuando el actor litigó por el simple hecho de vengar al demandado, no habiendo triunfado, y no prestó el juramento de calumnia, puede verse accionado por un *iudicium calumniae* y ser condenado por una décima parte de lo que reclamó; excepto en el juicio de libertad, ya que contra el *adsertor* se da por la tercera parte (Gayo, 4.175).

El pretor ofrecía también contra el *calumniator* una acción penal por el *quadruplum* dentro del año (luego por el *simpulum*) de la cantidad que cobró del demandado antes de la sentencia, por encubrir de mala fe una acción, o haber cobrado una suma para desistir de ella (Ulp., D.3.6.10.1; D.5.1.10.10, EP, §§ 36-38).

d) En ciertos juicios se da también el *contrarium iudicium*, como pena contra el actor vencido. Así, si se demandó, sin probarlo, por injurias (décima parte), o contra la mujer a la cual se le dio la *missio in possessionem*, en nombre del hijo que lleva en su vientre, y transmitió en forma dolosa dichos bienes a otro, siendo que no le correspondían (quinta parte), o cuando se accionó alegando que el pretor dio a alguien la *missio in possessionem*, y un tercero lo ha

privado de ella dolosamente (quinta parte), Gayo, 4.177. En este *contrarium iudicium* no es necesario que se pruebe la mala intención al demandar, lo cual es necesario en el *calumnias iudicium* (Gayo, 4.178).

e) Cuando ocurrió en un juicio el juramento de cisorio (*iuramentum in litem*), si el condenado no cumple con él, en la condena se toma el valor de la cosa en litigio (así, un legado, no por el monto quizá disminuido por la *lex Falcidia*, sino por su valor real; Iavol., D.35.2.60).

f) Finalmente, las condenas en ciertas acciones tienen carácter infamante. Así, los condenados en la *actio furti*, *actio vi bonorum raptorum*, *actio iniuriarum*, lo mismo que en la *actio pro socio*, la *actio fiduciae*, *actio tutelae*, *actio mandati*, *actio depositi*, son tachados de infames (*ignominiosi*); Gayo, 4.182.

§ 123. Efectos de la sentencia. Lo resuelto en una sentencia tiene la fuerza de la "cosa juzgada" (*res iudicata*). Esto significa que lo decidido lo es en forma definitiva, impidiendo que la misma cuestión entre las mismas partes vuelva a iniciarse de nuevo (regla: *non bis in eadem*).

1. La sentencia produce este efecto de la *res iudicata*, análogo al que había producido la *litis contestatio*. También acá se suele hablar de "novación necesaria", ya que la obligación que naciera de la fórmula (*intentio: dare praestare facere oportet*) es ahora obligación por la sentencia (*condemnari oportere*).

2. Para saber si el nuevo juicio que se intenta merece el efecto de la *res iudicata*, hay que atender a cada caso en particular. Como regla general, se debe dar la triple identidad dicha por Paulo (D.44.2.12.14): *idem corpus*, *eadem causa petendi* y *eadem conditio personarum*.

a) *Idem corpus*. Existe cuando se reclama la misma cosa o la misma cantidad, o el mismo derecho (Ulp., D.44.2.7); no importa el aumento o disminución de la cantidad o calidad (Paulo, D.44.2.14 pr.). Así, si reclamo un rebaño, no obsta a la *exceptio rei iudicatae*, que hayan muerto o nacido animales (Pomp., D.44.2.31.1). Si se pide la totalidad, no puedo volver a pedir una parte integrante (así, primero reclamar la casa, y luego el fundo, las vigas, etc.; Ulp., D.44.2.7 pr.). Pero si se reclaman primero los intereses, puedo accionar luego por el capital (Ulp., D.44.2.23).

b) *Eadem causa petendi*. Se debe tratar de la misma petición jurídica. Hay que distinguir entre las acciones *in personam* y las acciones *in rem*. En el caso de las primeras, si, p.ej., a propósito de los vicios redhibitorios* en la cosa comprada, he accionado por la *actio redhibitoria* y he perdido, no puedo intentar la *actio quanti minoris* (Juliano, D.44.2.25.1). Pero si me es debida una cosa por una venta y además por un legado, si intento la *actio empti* (acción de compra) y la pierdo, podré iniciar el reclamo de la cosa por la acción propia del legado, pues estoy intentando una nueva *causa petendi*.

Si se trata de una *actio in rem*, p.ej., la *rei vindicatio*, se considera que el reclamar que yo soy propietario estoy invocando todas las causas de adquisición del dominio. Por tanto, si pierdo el pleito, no puedo intentar uno nuevo, salvo que hiciera valer una nueva causa de adquisición posterior a la sentencia del juicio primero (Ulp., D.44.2.2.4-5).

Si se trata del ejercicio de la *actio furti* puedo acumular la *condictio furtiva* (o la *rei vindicatio*), puesto que por la primera estoy reclamando una pena, mientras que por cualquiera de las otras estoy reclamando por la cosa.

c) *Eadem conditio personarum*. La sentencia produce efectos respecto de las partes que han intervenido en el juicio, no respecto de terceras personas, a las cuales no afecta (Modest., D.44.1.19). Esta identidad existe también cuando aun tratándose de personas físicas distintas, una de ellas es continuación jurídica de la otra. Así, el heredero continúa la persona del *de cuius*; el *filiius in potestate* es una misma persona, desde este ángulo, que su *pater* (Ulp., D.44.2.11.8).

Sin embargo, en el caso de las acciones penales, éstas se llevan a cabo contra todos y cada uno de los que cometieron el delito. Se habla de "concurrencia cumulativa", ya que se ejerce la misma acción contra varias personas distintas. Se ve acá que no se da el requisito de *eadem personae*.

ANÁLISIS DE LA FÓRMULA

§ 124. Características. La fórmula es un corto documento en el cual figura la nominación del *iudex* y además las circunstancias fácticas y las pautas jurídicas que el pretor determina para la solución del litigio. Es, pues, un programa de acción al cual se ve sujeto el *iudex*. Al dar la acción y por ello ordenar la redacción de la fórmula, el pretor ha admitido que la posición jurídica del actor (y en su caso, la del demandado en la *exceptio*) merece protección jurídica. Es decir, ha resuelto la *quaestio iuris*, pero ahora las partes deberán probar *apud iudicem* que los hechos alegados por ellas (*quaestio facti*) eran verdaderos. De ahí que la redacción adopta siempre una forma condicional: Si se comprueba un determinado supuesto (p.ej., la compra de un esclavo, en la cual no se pagó el precio) entonces el *iudex* deberá condenar al demandado a pagarlo. De no aparecer probado el negocio o también probado el pago de dicho precio, hay que absolverlo.

1. Las fórmulas ofrecidas por el pretor que serán aplicables durante el año de su pretura, aparecen publicadas en el Edicto, expuesto en el Foro. Sin embargo, cada fórmula es típica y exclusiva para cada caso determinado, de tal modo que el magistrado podrá modificarla introduciendo aquellas circuns-

tancias que merezcan protección. Igualmente podrá admitir una fórmula nueva, del orden honorario, cuando estime que ello es necesario para amparar la situación jurídica planteada.

2. El actor solía presentar un borrador del texto y el demandado podrá proponer modificaciones. Todo, sin embargo, queda sujeto a lo que finalmente decida el magistrado en cuanto a la redacción final, pudiendo por supuesto quitar o agregar cuanto considere conveniente.

§ 125. Partes ordinarias de la fórmula. Hay ciertas partes que se pueden distinguir en la fórmula, no siendo necesario que todas ellas estén presentes; su mención depende de las características de cada asunto. Las llamadas partes ordinarias son cuatro: *demonstratio*, *intentio*, *condemnatio* y *adiudicatio* (Gayo, 4.39).

1. Además, generalmente, al comienzo de la fórmula aparece la mención del *iudex* elegido. Así, "Que Ticio sea el *iudex*:" (*Titius iudex esto*), o si son *recuperatores*: "Que Ticio, Cayo y Marco sean los *recuperatores*" (*Titius, Caius, Marcus recuperatores sunt*).

Tomemos como ejemplo la fórmula de la *actio empti* (acción de la compra):

*Quod A*A° de N*N° hominem q(uo) de (a)gitur emit, q(uo) de re) a(gitur), quidquid ob eam rem Nm.Nm Ao.Ao. dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Nm.Nm. Ao.Ao. c(ondemnatio); si (n(on) p(aret), absolvito* (EP, § 110).

Así aparecía en el Edicto para la lectura de un litigante. Traducida dice así:

"Por aquel esclavo por el cual se acciona que Aulo Agerio compró a Numerio Negidio, por todo lo que a causa de este asunto Numerio Negidio deba dar o hacer a Aulo Agerio conforme a la buena fe, que el *iudex* decida que Numerio Negidio sea condenado en favor de Aulo Agerio; si no aparece probado, que sea absuelto".

1. Como se ve, la redacción es muy breve, pese a lo cual nos encontramos con distintas partes. Lo puesto en latín entre paréntesis, es porque en el Edicto, por razón de brevedad, sólo figura la primera letra. Las partes litigantes aparecen mencionadas nombrando al actor como Aulo Agerio (derivado de *agere*: accionar) y al demandado como Numerio Negidio (derivado de *negare*: negar).

2. La primera parte es la *demonstratio* (Gayo, 4.40), en la cual se indica brevemente la causa del asunto, en este caso la causa de la obligación ("Por aquel esclavo por el cual se acciona que Aulo Agerio compró a Numerio Negidio"). Se sabe por ella que se ha alegado la compra de un esclavo por parte de Numerio Negidio a Aulo Agerio.

La *demonstratio* va siempre que se peticione algo

indeterminado (*incertum*), es decir, con *intentio incerta*, debiendo por ello el juez averiguar lo que debe pagar el demandado si es condenado. Por ello, acá ya seguía de la frase: "Por todo aquello..."

3. La segunda frase es la *intentio* (Gayo, 4.41), es decir, la parte por la cual el actor expresa su reclamo: "Por todo aquello que a causa de este asunto deba N.N. dar o hacer a Aulo Agerio conforme a la buena fe".

En este caso, lo que se reclama es un *incertum*, puesto que la *actio empti* por ser un *bonae fidei iudicium*, la suma a pagar, en caso de condena, deberá ser fijada por el *iudex* según los principios de la buena fe (*ex fide bona*).

Pero, en otros casos, la petición puede ser de un *certum*. Así, en la *rei vindicatio* cuando se reclama ser propietario de una cosa determinada. O en una *actio in personam*, si se reclama el pago de una suma determinada de dinero o una cosa determinada (Gayo, 4.41). Siendo la *intentio certa* no es necesaria la *demonstratio*.

4. La tercera parte, el resto de la fórmula es la *condemnatio*, o sea, la instrucción dada al juez concediéndole la *potestas* de condenar o de absolver, conforme a las pruebas que se presenten y su criterio de apreciación de ellas (Gayo, 4.43).

§ 126. *Adiudicatio*. En los juicios divisorios, es decir, aquellos en los cuales hay que dividir una cosa que tienen varios en común, se emplea otra parte que es la *adiudicatio*, que autoriza al juez a adjudicar a las partes que lo pidan la porción material que les corresponde en la división de la cosa que tienen en común. Así: "Que el *iudex* adjudique a Ticio cuanto deba serle adjudicado" (Gayo, 4.42).

Esto ocurre con la *actio communi dividundo* (división de la cosa en condominio), la *actio familiae erciscundae* (división de la herencia) y la *actio finium regundorum* (regulación de los límites confusos entre dos inmuebles).

1. Pero el *iudex* al adjudicar la porción correspondiente al actor o actores, puede condenar a pagar sumas de dinero para compensar y equilibrar el reparto, ya que no siempre resulta exacta la división material. Por ello, cuentan estas acciones con una *intentio incerta*, por la cual las indemnizaciones, ganancias conseguidas y pérdidas sufridas deben ser tomadas en consideración (EP, §§ 79.80.81). De este modo la *condemnatio* es, por tal motivo, complementaria de la *adiudicatio*.

§ 127. Particularidades de la *intentio*. Como hemos visto, la *intentio* puede referirse a reclamar algo determinado (*intentio certa*), o algo indeterminado (*intentio incerta*). En el primer caso debe pedir exactamente la suma de dinero que se le debe o la cosa determinada.

cuidándose de no pedir de más (*pluris petitio*) o pedir de menos (*minus petitio*). De estos dos errores, el más importante es la *pluris petitio*, puesto que en la época clásica pierde el juicio. En cambio, los efectos de la *minus petitio* son menos importantes. Estos errores por parte del actor sólo existen si la *intentio* es cierta, pero no si es incierta (así, "Por todo aquello que aparezca que el adversario deba dar o hacer" o "Por cuanto parte del fundo por el cual se acciona que aparezca que es del actor"; Gayo, 4.54).

A) *Pluris petitio*. Se puede reclamar de más: a) En relación con la cosa (*pluris petitio re*): Me deben 10.000 y reclamo 20.000, o siendo propietario de una parte de la cosa hubiera reclamado la totalidad de ella (Gayo, 4.53 a; Inst., 4.6.33 a).

b) En relación con el tiempo (*pluris petitio tempore*): Cuando reclamo una suma debida antes de que se cumpla el plazo o la condición (Gayo, 4.53 b; Inst., 4.6.33 b).

c) En relación con el lugar (*pluris petitio loco*): Cuando se me prometió dar algo en cierto lugar (así, en Efeso) y lo reclamo en otro (así, en Roma); Gayo, 4.53 c; Inst., 4.6.33 c.

d) En relación con la causa (*pluris petitio causa*). Así, p.ej., cuando en una obligación de género, reclamo al deudor una cosa concreta (así, se me debe un esclavo, y demando al esclavo Stichus). O en una obligación alternativa: p.ej., se me deben dar 10.000 sestercios o el esclavo Stichus, a elección del deudor, y yo reclamo el esclavo Stichus, quitándole la facultad de elegir al demandado (Gayo, 4.53 d; Inst., 4.6.33 d).

1. En este último caso, Gayo agrega que aun en el caso de que se pidiera la cosa que es de menor valor, lo mismo se incurre en *pluris petitio*, puesto que le estamos quitando la elección al deudor, y a éste le puede resultar preferible cumplir con la prestación no reclamada (Gayo, 4.53 d; Inst., 4.6.33 d).

2. No se incurre en *pluris petitio re* si se demanda la cosa que se debe, sino otra (reclamo al esclavo Stichus y se me debe el esclavo Eros). Obviamente acá se ha pedido la cosa equivocada, y de seguirse el juicio, lo perderá el actor puesto que no podrá probar que la cosa pedida le es debida; pero podrá haber un nuevo litigio por la cosa verdaderamente debida (Gayo, 4.55; Inst., 4.6.35).

3. Se excusaban de la *pluris petitio* en algunos casos: (i) si se trataba de un menor de 25 años (Inst., 4.6.33 a); (ii) si se había incurrido en ella por un error excusable (Paulo, 1.7.2), como p.ej., si alguien, ignorando codicilos* posteriores, pidiera la totalidad de un legado, lo cual no era admisible por la ley *Falcidia*, ya que no estaba obligado a conocer dichos codicilos (Inst., 4.6.33 a); (iii) cuando hubiera mediado coacción (*metus*) o dolo del adversario (Paulo, *ibid.*).

4. Para la época de Justiniano, y aun antes para

ciertos casos, se varió la sanción de pérdida del juicio en caso de *pluris petitio*, admitiendo una mayor flexibilidad. De este modo:

(i) si se había incurrido en *pluris petitio re*, el juicio no se pierde, pero el actor queda obligado por el *tripulum* de los daños y perjuicios ocasionados al demandado (Inst., 4.6.33 c; C.3.10.2; año 530). Sólo pierde el juicio el actor si, con dolo o malicia, pide una caución excesiva al demandado; aunque se lo perdonaba si se arrepentía y no iniciaba el juicio en el caso en que pidió la caución (C.3.10.3).

(ii) si se había incurrido en *pluris petitio tempore*, por una constitución del emperador Zenón, que mantuvo Justiniano, el actor no pierde el juicio, pero el lapso que pidió de más, le era duplicado en favor del demandado, quien veía prolongado el plazo, sin intereses. Además, debía pagar al adversario las *litis expensas* (gastos del pleito) con antelación al inicio del segundo juicio (C.3. 10.1; Inst., 4.6.33 e; Inst., 4.13.10).

(iii) si se había incurrido en *pluris petitio loco*, el mismo pretor atenuaba el principio de la pérdida del juicio, al conceder la *actio certi* con un agregado *cum loci adiectione* (la llamada *actio de eo quod certo loco*; D.13.4; C.3.18). El juez podía decidir que el demandado pagara tanto menos cuanto son los perjuicios que le acarrea tener que pagar en otro lugar (Gayo, D.13.4.1; Africano, D.18.8). Ello representaba una ventaja tanto para el actor que no perdía el juicio, como para el demandado, ya que p.ej., el precio de ciertas cosas genéricas, así el vino, el aceite, el trigo, etc., variaba según las localidades; lo mismo ocurría con el dinero, que no produce en todas partes el mismo interés.

(iv) si se había incurrido en *pluris petitio causa*, Justiniano decidió la no pérdida del juicio, pero condenaba al actor por el *tripulum* del daño que resultare por ello al demandado (Inst., 4.6.33 c).

B) *Minus petitio*. Si el actor incurre en el error de pedir "de menos" (*minus petitio*), no sufrirá la pérdida del juicio. Así, si se le deben 10.000 sestercios, podrá probar que esa suma menor le es debida. Por los 2.000 sestercios restantes, no podrá accionar ante el mismo pretor, ya que el demandado lo puede repeler por la *exceptio litis dividuae* (no dividir el pleito en juicios menores), pero los podrá demandar ante el siguiente pretor el año siguiente (Gayo, 4.56).

1. Esta solución será modificada por una constitución de Zenón, aprobada por Justiniano, pudiendo el juez condenar por la cantidad total que se hubiera probado (C.3.10.1.3; Inst., 4.6.34).

En cambio, si existiera *pluris petitio* o *minus petitio* en la *demonstratio*, como nada de ella le es planteada al juez como petición, el asunto permanece inalterado (Gayo, 4.58).

§ 128. *Particularidades de la condemnatio*. La condena, en la época clásica, se refiere siempre a una suma de dinero. El *iudex* estaba obligado a observar los términos en que está redactada la *condemnatio*. Ésta podía ser:

Certa: Cuando se establece una cantidad determinada de dinero. Así: "Condena a Numerio Negidio por 10.000 sestercios en favor de Aulo Agerio. Si no aparece así, absuelve" (Gayo, 4.50). No puede el *iudex* condenar por una suma mayor o menor; de lo contrario, se entendía que "hacía suya la causa" (*litem suam facit*), quedando obligado al resarcimiento a la parte perjudicada (Gayo, 4.52).

Incerta: Cuando no se establece ninguna suma determinada de dinero. Así: "Condena a Numerio Negidio en favor de Aulo Agerio por tanto dinero cuanto valga la cosa". Acá el *iudex* puede condenar por una suma determinada, teniendo mayor libertad en cuanto a su monto (Gayo, 4.51).

Incerta cum taxatione: En algunos casos la *condemnatio* era limitadamente incerta, puesto que se establecía un monto máximo de condena (*taxatio*), de tal modo que el juez no puede condenar más allá de dicho monto, pero sí por menos.

Esta *condemnatio incerta cum taxatione* podía ocurrir p.ej. en la *actio de peculio et de in rem verso** (hasta el monto del peculio o de la ganancia obtenida por el pater demandado), o cuando se da el "beneficio de competencia", para que el demandado pague según las posibilidades de su solvencia actual.

1. La *condemnatio* no existe en los procedimientos prejudiciales, en los cuales sólo figuraba la *intentio*; así, si se trata previamente de saber si alguien es libre, o cuánto es el monto de la dote, etc. (Gayo, 4.44).

2. Una *pluris petitio* en la *condemnatio* no perjudica al actor, pero sí al demandado, al cual se le restituye el exceso por medio de una *in integrum restitutio**. Si existe una *minus petitio*, el actor sólo recibirá el monto fijado en ella, puesto que el juez no puede exceder el monto de la *condemnatio*. Pero si el actor es un menor de 25 años, el pretor lo protege por medio de la *in integrum restitutio* (Gayo, 4.57).

§ 129. *Litis aestimatio*. Como la condena debía ser siempre pecuniaria, en caso de no tratarse de una suma de dinero, era necesario hacer una previa estimación del litigio (*litis aestimatio*).

Esto tiene especial importancia en aquellas acciones en las cuales hay que restituir la cosa conforme a una "cláusula arbitraria" (p.ej., la *rei vindicatio*). El juez anticipaba su *pronuntia-*

tio, de tal modo que el demandado vencido tuviera que optar entre pagar la *litis aestimatio* (según el juramento del actor que generalmente sobrevaloraba la cosa) o producía la restitución de ella.

1. Si el demandado vencido en la *rei vindicatio* prefiere pagar la *litis aestimatio*, podrá retener la posesión de la cosa. Pero si pierde su posesión, necesita una acción, que surge a partir de Juliano, quien extiende la posesión civil a su favor a título de compra (*pro emptore*), contando con la *actio Publiciana in rem*, y posibilitándole la *usucapio* (Juliano, D.6.2.7.1; Paulo, D.6.1.46). Esto no debe ser entendido como que Juliano viera en ello una compra por la *litis contestatio* (idea bizantina), ya que en ningún caso el poseedor puede adquirir la propiedad civil antes de haberse cumplido los plazos de la *usucapio*.

2. La *litis aestimatio* podía tener variantes según cada caso de acción. Así, podía quedar referida:

a) en las acciones penales, al valor existente en el momento de la comisión del delito (*quanti ea res fuit* —en pasado—; por lo que valía la cosa en ese momento);

b) al valor existente en el momento de la *litis contestatio* (*quanti ea res est* —en presente—; por lo que vale la cosa cuando se traba el litigio). Esto ocurre en las acciones *in personam* de restituir la cosa (así, la *actio depositi*, *actio commodati*, de dolo, etc.).

c) al valor en el momento de la sentencia (*quanti ea res erit* —en futuro—; por lo que valdrá la cosa) en las otras acciones de derecho estricto;

d) al valor que fije el juez, sin referirse a un momento determinado (*tantam pecuniam...*); esto ocurre en los *bonae fidei iudicia*, en los cuales se tiene en cuenta "lo que le interesa" al actor (*id quod interest*).

§ 130. *Partes extraordinarias de la fórmula*. Aparte de las denominadas partes ordinarias (*demonstratio*, *intentio*, *condemnatio* y *adiudicatio*), las fórmulas pueden contener otras que son extraordinarias: así, una *praescriptio* o una *exceptio*.

§ 131. A) *Praescriptio*. Es una cláusula que iba al comienzo de la fórmula, para advertir al juez sobre alguna circunstancia que debe ser salvaguardada en favor del actor —*pro actore*—. Así, si la obligación consiste en el pago de sucesivas mensualidades o anualidades, para evitar que con el ejercicio de la acción por alguna de las cuotas impagas se considerara que el actor habría agotado la acción respecto de alguna otra cuota futura. El pretor agregaba entonces la siguiente *praescriptio*: "Que el asunto se accione por aquella suma cuyo plazo ha vencido" (*Ea res agatur cuius dies fuit*). De este modo, quedaba aclarado que la acción quedaba

expedida por las cuotas futuras (Gayo, 4.130-133).

1. Gayo (4.133) nos aclara que, si bien la *proscriptio* es dada en la época clásica en favor del actor, en sus comienzos era dada también en favor del demandado, pero esta defensa se transformó en la *exceptio*. Esto debió haber ocurrido a comienzos del procedimiento formulario, puesto que en las *legis actiones* no cabían las *exceptiones* (Gayo, 4.108).

§ 132. B) *Exceptio*. Es una defensa dada en favor del demandado, quien alega alguna circunstancia que por aplicación de la *aequitas* merece ser amparada por el pretor. Con ello, una vez probada la *exceptio* se neutraliza la *intentio* del actor, evitando con ello la condena (Gayo, 4.116; 119).

1. Así, p.ej., si hubo una *stipulatio* por una suma de dinero, pero el dinero no le fue efectivamente entregado al que aparece como deudor en dicha promesa de pago, en principio el estipulante tiene la acción para reclamar, pero como resultaría inicu la condena de tener que pagar algo que no se recibió, el pretor le otorga al demandado la *exceptio doli mali* (Gayo, 4.116 a; Inst., 4.13.3).

2. En general todo pacto —no genera una *actio*— está amparado por una *exceptio* (*exceptio pacti conventi*), lo mismo que si alguien es demandado por un negocio en el que se actuó por dolo (*exceptio doli mali*), o ha sido objeto de coacción (*exceptio quod metus causa*). En los *bonae fidei iudicia* no había necesidad de intercalar una *exceptio* en la fórmula, puesto que se la puede hacer valer directamente ante el juez.

3. En la fórmula aparece redactada luego de la *intentio* y antes de la *condemnatio*. En el procedimiento *extra ordinem* posterior, al no haber fórmula, se sigue manteniendo la *exceptio*, que será entendida como medio de defensa del demandado (Inst., 4.13 pr.).

4. Una *exceptio* generalmente es dada en favor del demandado. Pero puede verse rechazada por alguna circunstancia que la desvirtúa. Así, si el actor demanda una suma de dinero por la *condictio certae creditae pecuniae*, el demandado que había pactado con el acreedor actor un pacto de espera, puede intercalar la *exceptio pacti conventi*. A su vez, si el actor alegara que luego de dicho pacto existió un segundo por el cual se dejaba sin efecto el primero, el pretor le concede en favor del actor la intercalación de una *replicatio*, que enerva la fuerza de la *exceptio* (Gayo, 4.126). El pretor, que escucha en la etapa cognitoria a las dos partes, puede en casos más complejos admitir otra cláusula en favor ahora del demandado tendiente a enervar la *replicatio* del actor, que era llamada *duplicatio* (así, p.ej., si alegara que el segundo pacto fue obtenido coactivamente; Gayo, 4.127; Inst., 4.15.1). Y si surgieran nuevas circuns-

tancias incuvas que merezcan protección, le puede dar al actor una *triplicatio* para tornar inane la *duplicatio* (Gayo, 4.128; Inst., 4.15.2). Y así sucesivamente nuevos agregados (Gayo, 4.129; Inst., 4.15.3).

Todo esto es una muestra de la elasticidad que tenía el procedimiento formulario, que atendía todas las circunstancias, aun las más complejas que podían suceder en un litigio. Esto era imposible bajo el primitivo procedimiento de las *legis actiones*.

§ 133. *Clasificación de las exceptiones*. Se suele clasificar las excepciones en "perentorias" y "dilatatorias".

Las primeras son las que valen a perpetuidad ("perpetuas"), de tal modo que de triunfar resultan definitivas para la suerte del asunto, es decir, lo hacen "perimir" (Gayo, 4.121; Inst., 4.13.9(8)); así, p.ej., la *exceptio doli mali*, la *exceptio quod metus causa*, etc.

En cambio, las "dilatatorias" son las que valen por cierto tiempo ("temporales"), como, p.ej., la *exceptio pacti conventi*, en virtud de un pacto de no reclamar la cosa, supongamos, por cinco años, ya que luego de transcurrido este plazo no se puede oponer la excepción (Gayo, 4.122; Inst., 4.13.10 (9)).

1. En la época clásica, esta distinción de las excepciones es muy relativa, ya que siendo "perentoria" o "dilatatoria", una vez introducida en la fórmula, por efecto de la *litis contestatio*, el procedimiento marcha hacia la sentencia, de tal modo que si se hubiera intercalado una "dilatatoria" (*exceptio pacti conventi*), de triunfar, el actor perdería el juicio por haber incurrido en *pluris petitio tempore*. Con ello, tendría el mismo efecto que si hubiera sido "perentoria". El actor, avisado de la posible intercalación de esta *exceptio*, debía considerar que le resultaba más provechoso no llegar a la *litis contestatio*.

2. Sin embargo, alguna aplicación tenía la división en la época clásica. En efecto, si el demandado omitió intercalar una excepción "perentoria" en la fórmula, lo podrá hacer *apud iudicem* antes de la sentencia (Gayo, 4.125), criterio que se mantendrá luego por una constitución de Diocleciano y Maximiliano (C.7.50.2; año 294). A su vez, el mismo Gayo nos dice que respecto de una excepción "dilatatoria" estaba cuestionado para su época si se podía alegar la misma, omitida antes, en la etapa *apud iudicem*.

CLASIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS

§ 134. I. *Fórmulas in ius conceptae*. Una fórmula está redactada *in ius* cuando lo que reclama el actor está tutelado por el *ius civile*.

1. Así, p.ej., la *rei vindicatio*. La fórmula dice así: "Si aparece probado que tal cosa (designándola con

precisión) por la cual se acciona es del dominio *ex iure Quiritium* de Aulo Agerio..." Sería el caso de una *actio in rem*.

Acá, la fórmula petitoria hace neta referencia al dominio civil (*si parcat esse ex iure Quiritium*). Como no se basa en una obligación del demandado, ésta ni siquiera es nombrado, ni tampoco la posesión que tiene de la cosa; a pesar de que ella es la que legitima pasivamente al demandado para estar en juicio.

2. A su vez, también la *actio certae creditae pecuniae*: "Si aparece probado que Numerio Negidio le debe dar 10.000 sestericios a Aulo Agerio" (*Si parcat... 10.000 s. dare oportere*). Acá es el caso de una *actio in personam*, en la cual la suma de dinero (podría ser también una cosa) es *certa*; pero si se trata de la *actio ex stipulatu*, por ella se puede peticionar un *incertum*.

§ 135. II. *Fórmulas in factum conceptae*. En otros casos, el pretor, por razones de equidad, concede la acción, pero no basada en el derecho civil (*in ius*) sino en el hecho ocurrido. Por ello no se redacta una *intentio* sino que al comienzo de la fórmula se menciona dicho hecho, dándosele en la *condemnatio* al juez la potestad de condenar o de absolver (Gayo, 4.46). Son denominadas *formulae in factum* (basadas en "el hecho") y todas ellas son pretorias (u honorarias).

1. Así, p.ej., la usada por el patrono en contra del liberto que lo demandó sin haber pedido autorización al pretor. La *demonstratio-intentio* es reemplazada por la mención del hecho: "Que haya *recuperatores*. Si aparece que este patrono hubiera sido citado en juicio por este liberto del patrono en contra (del edicto) del pretor, entonces *recuperatores*, condenar a este liberto a dar 10.000 sestericios a este patrono. Si no aparece así, absolverlo" (Gayo, 4.46). Como no se basa en el *ius civile*, dado que la permisión para actuar del libertus estaba ordenada en el edicto, el pretor consideraba solamente ese hecho.

2. Igualmente, para el ejercicio de la *actio legis Aquiliae*, que es del *ius civile* (y también *legitima*, por emanar de una ley), se exige que el daño haya sido ocasionado por la acción directa del cuerpo del agente sobre la cosa (*corpore corpori datum*), pero si ello no se cumple, el pretor concede una *actio in factum* (Pomp., D.19.5.11), considerando que por equidad merece amparo jurisdiccional.

3. En algunos casos podían existir dos fórmulas: una más antigua redactada *in factum* (pretoria), y otra redactada *in ius*, más reciente, lo que significa que la situación jurídica está amparada por el *ius civile*. Tal es el caso, p.ej., de la *actio depositi*. La *actio depositi in factum* hace mención de que el depositario no ha devuelto la cosa por dolo malo. En cambio, la *actio depositi in ius* ampara directamente la obligación de devolver de acuerdo con el *ius civile*

(contiene en la *intentio* la expresión *dare facere oportet ex fide bonae*; Gayo, 4.47).

§ 136. III. *Fórmulas ficticiae*. También, por razones de equidad, en una acción pretoria, el magistrado ordena al juez que tenga por existente un hecho inexistente, o por inexistente uno existente. De este modo, hace proceder una acción que según el *ius civile* no correspondería, pero que se considera inicu que no se tenga en cuenta. Son llamadas también *actiones utiles*.

1. Así, p.ej., hay fórmula con *fictio* para el caso de que demandara el cobro de una obligación hereditaria el *bonorum possessor* (sin ser heredero), o se demandara contra él una obligación del causante. Como no tiene "acciones directas", el pretor fingió que es el heredero (Gayo, 4.34). O en el caso análogo del *bonorum emptor*, respecto del cual se fingió que es heredero del deudor (Gayo, 4.35). El caso más célebre es el de la *actio Publiciana in rem*, en la cual se fingió que el comprador de buena fe ha completado el plazo de la usucapción (Gayo, 4.36). O para el caso de la *actio furti* ejercida contra o por un extranjero, fingiendo la ciudadanía romana (Gayo, 4.37).

2. Un caso en que se fingió inexistente un hecho existente, lo tenemos cuando un acreedor del que se ha dado en *adrogatio* lo ha demandado, fingiéndose que la adopción no ha tenido lugar (Gayo, 4.38).

§ 137. IV. *Bonae fidei iudicia*. Es un procedimiento ante el juez, pero de tal modo que por concesión del pretor se le concede la libre potestad de estimar lo que se debe restituir, sin darle una limitación cuantitativa determinada, sino estableciendo que lo precise conforme a lo que indica la buena fe (*ex bono et aequo*); Gayo, 4.61; Inst., 4.6.39.

Ello ocurre en los casos siguientes: en el de la compraventa, la *locatio conductio*, la *negotiorum gestio*, el mandato, la *fiducia*, la sociedad, la tutela y las cuestiones de dote —*rei uxoriae*— (Gayo, 4. 62; Inst., 4.6.18).

1. El *iudicium*, si bien está respaldado en una fórmula, no es considerado una fórmula, es decir, no son términos sinónimos. El *iudex* debido a la complejidad que pueden tener estos casos, debe examinar el negocio en sí, pudiendo condenar en más o en menos de lo que reclama el actor, efectuando en su caso compensaciones (Gayo, 4.63; Inst., 4.6.30).

2. Están referidos a algunos supuestos (caso de la compraventa y demás contratos consensuales) que no provienen estrictamente del *ius civile*, pero que estaban fundamentados en la buena fe. Al ser reconocidos por el derecho civil, la cláusula *ex bono et aequo* permitía dispensar al juez manos libres para interpretar las cláusulas del negocio, lo cual hubiera re-

sultado muy complicado de atender en una fórmula corriente.

3. Justiniano agrega a la lista de *bonae fidei iudicia* de Gayo, la del comodato, la prenda, las acciones divisorias *communi dividundo* y *familiae eriscundae*; así como la *actio praescriptis verbis*, la *actio ex permutatione* y la *heredis petitio* (Inst., 4.6.28). A su vez, los otros juicios que no son *bonae fidei iudicia*, los cuales en la época clásica no tenían ninguna denominación genérica, serán llamados por Justiniano *stricti iuris* (Inst., 4.6.28).

§ 138. Otras fórmulas pretorianas. A) *Fórmula arbitraria*. En algunas fórmulas (caso de la *rei vindicatio*), el pretor agrega la cláusula "a falta de restitución" (*nisi restituatur* o *neque restituatur*), de tal modo que si en una *actio in rem* o exhibitoria el demandado no restituye o exhibe la cosa, podía ser condenado a tener que pagar el valor estimado de ella según juramento del actor (*litis aestimatio*).

1. Son llamadas comúnmente *actiones arbitrarie* puesto que al parecer se dejaba la ejecución al *arbitrium iudicis*. Gayo (4.141; 163) emplea la expresión de "fórmula arbitraria" también al caso de actuación de un árbitro. Justiniano las denomina *actiones arbitrarie*, como dependientes del arbitrio del juez. Podían ser tanto *actiones in rem* (reivindicación, exhibición, Publiciana, Serviana, etc.), como *actiones in personam* (dolo, coacción). En todas ellas el juez tiene la potestad de sobrevalorar la cosa por el juramento del actor, como medio coercitivo para que el demandado vencido la restituya (Inst., 4.6.31). Pero éste podía aceptar pagar la *litis aestimatio*, reteniendo la cosa y gozando sobre ella de la propiedad bonitaria.

B) *Fórmulas con trasposición de personas*. En ellas, la *condemnatio* está redactada respecto de una persona que sustituye a la que aparece en la *intentio*. El propósito es conseguir que la condena produzca sus efectos en favor o en contra de una persona distinta de la que aparece implicada en la *intentio*. Así, en las deudas contraídas por los hijos o esclavos (*actiones adiecticiae qualitatis*), o en los casos de representación procesal (*cognitor, procurator*).

OTROS MEDIOS PRETORIANOS ESPECIALES

I. Interdictum.

§ 139. *Concepto*. Los *interdicta* (en singular *interdictum*) son medidas, o mejor órdenes dispuestas por el pretor (o el procónsul) para resolver una cuestión urgente, de tal modo que se

haga respetar inmediatamente una determinada situación que está protegida jurídicamente, y cuya solución no admite mayor demora (Gayo, 4.138 ss.).

1. El interdicto procede no de la *iurisdictio* del magistrado, sino de su *imperium*. Funcionan, pues, igual que otras medidas directas que toma el pretor: así, en el caso de una *missio in bona*, de una *in integrum restitutio* y de las *stipulationes praetoriae*.

2. Por ello, a diferencia de una *actio*, el *interdictum*, cuya fórmula es dada en el Edicto, no sigue el procedimiento de las dos etapas usuales (*in iure* y *apud iudicem*), sino que todo es tramitado ante el *imperium* del pretor. Esto le da celeridad y mayor eficacia.

3. Si bien el mismo Gayo (4.139) advierte que el mayor campo de aplicación de los interdictos era el de la posesión, se pueden referir a múltiples cuestiones: así, para proteger un lugar sagrado, religioso o santo (EP, § 235); para restituir la libre navegación de un río o el uso de sus riberas (EP, § 241); para permitir al dueño de un fundo recoger las bellotas que caen en terreno vecino (EP, § 260); para obligar a otro a exhibir un *filius* que se refugia arbitrariamente (EP, §§ 261-262); o para exhibir un liberto (EP, § 263); o para obligar al deudor a restituir lo retenido por fraude al acreedor (EP, § 268).

§ 140. *Clases*. Los *interdicta* son restitutorios, exhibitorios o prohibitorios (Gayo, 4.140). En el caso de un interdicto restitutorio, el comienzo de la orden es con la palabra "restituas..." (para que restituyas la cosa o se vuelva a la situación anterior). El interdicto exhibitorio emplea la palabra "exhibeas..." (para que exhibas). Los prohibitorios emplean una orden en forma negativa; así, *vim fieri veto* (prohibo que se haga violencia).

1. Gayo (4.140) establece que cuando en el interdicto se ordena algo, así que se exhiba o que se restituya, reciben el nombre de *decretis*. En cambio, cuando se prohíbe que se haga algo, así que no se haga violencia sobre quien posee sin vicios o que no se haga algo en un lugar sacro, reciben propiamente el nombre de *interdicta* (de *interdicere* = prohibir; Inst., 4.15.1).

§ 141. *Procedimientos*. Si el demandado acata la orden del pretor, el actor consigue lo que se había propuesto con el interdicto. En cambio, si resiste la orden pretoria, a petición del actor se inicia un procedimiento que termina con la decisión del *iudex* (o de los *recuperatores*), es decir, una ejecución forzosa.

1. Gayo (4.156 ss.) nos dice que los interdictos son "simples" o "dobles". Son "simples" cuando uno es

actor y el otro es demandado (así, los exhibitorios y restitutorios, y también los prohibitorios del tipo: prohibir a alguien hacer algo en un lugar sacro o en un río o en sus riberas; Gayo, 4.157; 159). En cambio, son "dobles" cuando ambos litigantes asumen recíprocamente el papel de actores y de demandados (así, en los interdictos posesorios *Uti possidetis* y *Utrubi*; Gayo, 4.160).

2. En los "simples", la ejecución es *per formulam arbitriam*, es decir, el demandado pide la intervención de un árbitro. Lo debía hacer inmediatamente, antes de que el pretor se retirara, no recibiendo pedidos posteriores (Gayo, 4.164). Si se cumple la orden del árbitro, entonces el demandado obra sin riesgos (*sine periculo*), y es absuelto. Pero si no la acata, entonces es condenado por cuanto valga la cosa (*aestimatio: quanti ea res erit*).

Pero si el demandado no pidiera un árbitro antes de abandonar el tribunal, se utiliza el procedimiento de que el actor provoca al demandado a una *sponsio** (p.ej.: "Si en contra de lo dispuesto en el interdicto no restituyes *spondes* (prometes solemnemente) darme tantos sestercios? y el otro contesta *spondeo* (lo prometo). El demandado provoca a su vez al actor a una *restipulatio* (p.ej.: "Si restituyes conforme al interdicto *spondes* darme tantos sestercios? y el otro contesta: *spondeo*). Estas *sponsiones* y *restipulationes* tenían un carácter penal, por cuanto el que era condenado a cumplir la orden, perdía la suma de su *sponsio* o *restipulatio*. Por ello se decía que acá el procedimiento era "con riesgo" (*cum periculo*); Gayo, 4.163.

3. En el caso de los interdictos "dobles" el procedimiento era más complicado, ya que ambos aparecen como actores y demandados (casos del *Uti possidetis* y del *Utrubi*).

a) Primero había que proceder a la *fructus licitatio* (licitación de los frutos), que conlleva la posesión interina de la cosa y el goce de sus frutos. Ambas partes pujaban en la licitación. El que triunfaba porque ofrecía una suma mayor, debía garantizar por una *fructuaria stipulatio* al adversario para el caso de que perdiera el procedimiento. Esta garantía era *poenalis*, ya que además de pagarla debía restituir la posesión y los frutos, utilizándose el juicio *Cascellianus* o consecutivo (Gayo, 4.166a-167).

b) Luego había que proceder a las *sponsiones* y *restipulationes*, que acá, a diferencia de lo que ocurría en los interdictos "simples", se duplicaban. Así, A celebra una *sponsio* comprometiéndolo a B, y éste a su vez "restipula" respecto de A; pero también B celebra otra *sponsio* con A; y éste una nueva *restipulatio* con B.

De este modo, se hace necesario redactar cuatro fórmulas, correspondientes a las cuatro *sponsiones* y *restipulationes*, más una quinta por el resultado final, en el supuesto de que quien por la *fructus licitatio* fuera vencido y por la decisión del juez tuviera que devolver la cosa discutida y sus frutos y no lo hiciera (*iudicium Cascellianum sive secutorium*).

Y además, está la sexta fórmula por la *fructuaria stipulatio* que era llamado *iudicium fructuarium* (Gayo, 4.169).

Si alguien rehusaba seguir los distintos pasos de este procedimiento, el pretor establecía "interdictos secundarios", ordenando directamente restituir lo que poseyera, y si no fuera el poseedor, no hacer violencia al que lo fuere.

Incluso, para evitar estos procedimientos, se solía convenir a una expulsión simbólica por parte de uno de ellos respecto del otro (*vis ex conventu*). De este modo, se eludía el tener que plantear el interdicto *Uti possidetis* (caso de un inmueble), que era prohibitorio y doble, para poder plantear (alegando el despojo "simbólico") el interdicto restitutorio *Unde vi*, que era "simple". A esta vía parece referirse Cicerón en su *pro Caecina*.

Estos engorrosos procedimientos fueron eliminados en la época posclásica. Justiniano los sigue denominando *interdicta*, pero quedaron asimilados a las "acciones útiles" (Inst., 4.15.8, D.43.1).

II. In integrum restitutio.

§ 142. En determinados casos, el pretor podía rescindir una determinada situación negocial volviendo las cosas al estado originario. El magistrado, luego de conocer la causa (*cognitio causae*), comprobando la veracidad de lo ocurrido y que ello justificaba la medida, ordenaba la *in integrum restitutio*. Así, para proteger a los menores de 25 años que por su inexperiencia habían realizado negocios que les eran perjudiciales; pero también en casos de violencia, fraude, perjuicio de los acreedores, y también en algunos casos de justo error (Ulp., D.4.1.1; Paulo, D.12: Paulo, 1.7.1).

III. Missio in possessionem (in bona).

§ 143. Para proteger determinadas situaciones, el pretor puede ordenar el embargo de todo el patrimonio de una persona (*missio in bona*), o al menos de una cosa (*missio in rem*).

1. Su finalidad es garantizar la conservación de los bienes embargados, por lo que es más la simple detentación de las cosas que una verdadera posesión (*missio rei servandae gratia*). Salvo que la situación sea definitiva no goza de la normal protección posesoria interdictal. Pero, no obstante su carácter provisional, se le otorga al *missus* un interdicto para que no se le impida con violencia retener la cosa en su poder (D.43.4), y en algunos casos una *actio in factum* contra quienes le impidan, con dolo, poseer la

cosa (esf. 2.º los acreedores en la *venditio bonorum*; EP, § 216).

2. Se le concede: a) al actor cuando el demandado se ubica en la situación de *indensus*; b) en favor de quien no da una caución exigida por el pretor; c) a los acreedores en la *venditio bonorum*; d) en favor del *nasciturus* para preservar sus derechos hereditarios (*missio ventris matris*; EP, § 147); etc. En estos casos se da respecto de todos los *bona*. Un caso de *missio in rem* (respecto de una sola cosa) se da en el *damnum infectum* (EP, § 175).

IV. Stipulationes praestoriae.

§ 144. El magistrado puede, en ciertos casos, obligar a que nazcan obligaciones creadas bajo la forma de una *stipulatio*, a los efectos de asegurar un determinado derecho. Así, p.ej., si se hubiera dejado un legado de usufructo, el usufructuario debía prometer que usará correctamente la cosa "según el arbitrio de un buen varón" y de que cuando finalice el usufructo restituirá la cosa (*cautio usufructuaria*; Ulp., D.7.9.1 pr.; EP, § 286). De no hacerlo, le denegará la acción al legatario usufructuario.

1. Las *stipulationes praestoriae* (u honorarias) pueden ser de variada aplicación. Aquí, en el caso de la *cautio usufructuaria*, lo mismo que en el caso de la *collatio bonorum** y la *satisfactio rem pupilli salvam fore**, de no prestarse eran sancionadas con la denegación de la acción para entrar a gozar el usufructo, la herencia o la administración de los bienes en la tutela.

2. Para el supuesto de que se exigiera en la *cautio damni infecti*, la *cautio iudicatum solvi**, los *vadimonia** o la *cautio legatorum*, la sanción era una *missio in possessionem* en favor del actor que pudiera por el daño eventual temido, el demandado que no prestara las cauciones o el heredero que no cumpliera el legado.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO FORMULARIO

§ 145. *Actio iudicati*. Quien ha sido condenado en la sentencia debe pagar el monto de la condena pecuniaria. El actor triunfante goza de la *actio iudicati*, la cual tiene la particularidad de que ejercida contra un condenado recalcitrante, es decir, que se resiste provocando un proceso negando la deuda nacida de la sentencia u oponiendo una *exceptio*, la condena final crece hasta el *duplum* (litiscrescencia por *infinitio*; Gayo, 4.102).

1. La *actio iudicati* puede llevarse a cabo contra el condenado o el *confessus in iure*, es decir, el que

ha confesado ante el pretor que el actor tiene razón en su petición.

2. La ejecución puede ser "personal" o "patrimonial". La primera, resabio de la vieja *manus iniectio*, permitía que el pretor autorizara al actor a llevarse al deudor a su casa reteniéndolo con prisión por causa de deuda. A pesar de la dureza de esta vía, esta forma de ejecución privada seguirá perdurando.

La ley *Poetelia Papiria* (año 326 a.C.) había mitigado el procedimiento autorizando al deudor a defenderse por sí mismo, sin necesidad de un *uxor*. La expresión de Tito Livio (3.28.8) de que por esta ley se cambió la ejecución personal en ejecución patrimonial parece una simplificación excesiva. Al parecer, la ejecución patrimonial fue debida "según se dice" al pretor Publio Rutilio (fines del siglo II a.C.); Gayo, 4.35, pero se sospecha que debió haber sido de aparición más antigua.

De todos modos, estamos muy poco informados acerca de la ejecución personal; pareciera ser que luego de la *addictio* del deudor, como consecuencia del decreto del magistrado de *duci* (Cicer., *pro Flacco*, 20.43; *lex Rubria*, 21, en *Fontes*, I, p. 173), el prisionero, que permanecía libre, debía trabajar hasta pagar su deuda (Ps Quint., *declam.*, 311). Por los pocos datos que tenemos, parece cierto que lo preferido fue la "ejecución patrimonial".

§ 146. La *venditio bonorum*. La ejecución patrimonial consiste en la venta de todo el patrimonio del *damnatus* y es denominada *venditio bonorum* (Gayo, 3.77-81). Es un procedimiento concursal que puede ser iniciado por quien ganó el juicio y cuenta con la *actio iudicati*; pero también pueden actuar, permitidos por el pretor, otros acreedores, los cuales, luego, son llamados públicamente a intervenir. Con la venta pública del patrimonio se tratará de satisfacer, en la medida del valor de dichos bienes, el interés de todos los acreedores, ocurriendo generalmente que éstos no logren cobrar el todo de sus créditos. La *venditio bonorum* arrastra la tacha de infamia para el deudor ejecutado (Gayo, 2.154; Cic., *pro Quinct.*, 15).

1. Son interesantes las consideraciones que hace Álvaro d'Ors (DRP, § 114) para una mejor comprensión del régimen clásico de la ejecución:

a) La costumbre muy utilizada de los garantes y fiadores personales hacía que los acreedores, en lugar de ir contra el deudor primario, trataran de buscar la satisfacción de los créditos en dichos garantes. Esto permite pensar que, por una cuestión práctica, antes de proceder a la *venditio bonorum*, existieran dilaciones por tratativas con ellos, por lo que sólo ante su fracaso se debía acudir a la ejecución patrimonial de la venta del patrimonio del deudor primario, por lo que pocas veces se tenía que recurrir al procedimiento judicial.

b) La *venditio bonorum* se da, no en el caso del deudor que carece de bienes (carecería de interés práctico), sino contra aquel que por falta de liquidez no tiene en forma inmediata el dinero suficiente, es decir, el insolvente (el que no puede pagar).

c) En Roma se distinguía entre el insolvente ordinario y aquel otro que oculta dolosamente su insolvencia, de tal modo que en este último caso resultaba criminalizado por el perjuicio a los acreedores, pudiendo ser reducido a prisiones públicas (Paulo, D.5.26.2; Ulp., D.26.10.3.16).

§ 147. Trámite de la *venditio bonorum*. La *venditio bonorum* debía seguir los siguientes pasos:

a) *Missio in bona*. El pretor ordena, ante el pedido del acreedor, el embargo del patrimonio del deudor. El acreedor (o acreedores) es puesto en posesión de los bienes del deudor, al solo efecto de retener, conservar y administrar el patrimonio (*rei servandae causa*). Esta *missio in bona* era dada por un decreto (EP, § 217), pudiéndose pedir al magistrado un *curator bonorum* (Paulo, D.42.5.14 pr.).

1. En principio, cuando uno de los acreedores pide la *missio in bona*, se le otorga a él, pero también tienen acceso los otros acreedores, siempre permitiéndolo el magistrado (Paulo, D.42.5.12 pr.). Para la elección del *curator bonorum* el magistrado no era totalmente libre. Se prefería al acreedor, sobre todo al que se le debiera la mayor cantidad, incluso respecto de un cognado, pero también al cognado respecto de una persona extraña (Gayo, D.42.5.16). Igualmente un *vir consularis* y un *vir praefectorius* debían ser preferidos a una *femina consularis* (Ulp., D.1.9.1); también los hijos respecto de parientes más alejados (Ulp., D.50.16.56.1).

2. El favorecido con la *missio in bona* deberá dar publicidad de lo ocurrido mediante avisos públicos, durante 30 días si el deudor está vivo, y 15 días si ha fallecido (Gayo, 3.79). Con ello se facilita el conocimiento de los demás acreedores que se quieran presentar al concurso, y también para que se presente alguien que quiera pagar por el deudor evitándole la tacha de infamia. Por ello se explica que se conceda un plazo mayor respecto del deudor vivo que de uno fallecido, "para que no se vean expuestos tan fácilmente a sufrir la venta de sus bienes" (Gayo, 3.79).

3. Los acreedores que tengan un *pignus* o una hipoteca no se presentan a la *venditio bonorum*, ya que ellos ejecutan directamente sus créditos con los bienes garantizados, los cuales quedan excluidos de la masa de bienes.

b) Elección del *magister*. Trascurridos estos plazos, el pretor ordena que se elija entre los acreedores un *magister* (lo que hoy día sería un

síndico en una quiebra o en un concurso). Este se encarga de realizar la venta, trazando un cuadro general del activo y del pasivo, es decir, un inventario, que contiene además las condiciones de pago de la venta que se producirá (*lex venditionis*); Gayo, 3.79.

1. De la masa de bienes hay que excluir los bienes ajenos al deudor. Igualmente, aquellos que están garantizando una prenda o una hipoteca. Pero también pueden existir ciertos acreedores privilegiados que cobrarán primero y por entero, siempre que los bienes alcancen. Así, el Fisco respecto de lo que le deban los contribuyentes, los que tengan un crédito por gastos de entierro, por restitución de la dote, el incapaz respecto de su tutor o curador, el que dio dinero para hacer refacciones a un edificio del deudor, etc.

2. Igualmente el *magister* debe separar ciertas masas patrimoniales: así, el peculio del hijo que responde a sus deudas propias, o las *separationes bonorum* hereditarias.

3. El *magister* debe ordenar que la venta sea hecha en 10 días, si se trata de un deudor vivo, y en 5 días si éste está fallecido (Gayo, 3.79).

c) Finalmente ocurrirá la venta, la cual es realizada por el *magister vendendi*. Esta no se realiza a precio fijo, sino que la atribución (*ad dictio*) del patrimonio vendido se hace en favor de aquel que ofrece pagar el más alto porcentaje de los créditos de los acreedores. El adquirente es el *bonorum emptor*.

1. En la venta, el interés del licitador está dado por el cálculo valorativo que ha hecho de los bienes del activo y las deudas del pasivo, pensando que de triunfar en la subasta, luego podrá vender en forma más tranquila y reductible los bienes obtenidos.

Esto significa que los que pujen en la licitación, luego de haber hecho dichos cálculos ofrecerán pagar un determinado porcentaje de las obligaciones del deudor, triunfando aquel que ofrezca pagar el porcentaje mayor. Como éste no será por el 100 por ciento, todos los acreedores quirografarios (es decir, no los prendarios e hipotecarios ni los privilegiados, que se cobrarán primero) sólo cobrarán un porcentaje de sus créditos.

2. El deudor no queda, sin embargo, totalmente liberado, debiendo responder por los residuos impagos de deudas anteriores a la *venditio bonorum*, pero durante el año siguiente gozará del *beneficium competentiae** (Diocl., C.7.75 b jtp?).

El *bonorum emptor* adquiere la propiedad bonitaria de los bienes del deudor, pudiendo usucapirlos (Gayo, 3.80). El pretor le concede un interdicto *possessorium* para entrar en posesión

de ellos (Gayo, 4.145). Respecto de los bienes o créditos debidos al deudor concursado, o los debidos por éste, el pretor concede al *bonorum emptor* acciones útiles (Gayo, 3.81).

1. Así, si se trata de un concursado que vive, se le otorga (a favor y en contra) la *actio Rutiliana*, mientras que si el concursado ha fallecido, el pretor le concede (en favor y en contra) la *actio Serviana* (que no hay que confundir con la del mismo nombre del acreedor pignoraticio); Gayo, 4.65.

2. Estas acciones se hacen con *clausula ficticia*, por cuanto se finge que el *bonorum emptor* es el que ha contraído la obligación, o que es heredero del deudor concursado (Gayo, 4.35). Se emplea en la fórmula respectiva la técnica de "trasposición de personas".

3. Si el demandado por el *bonorum emptor* contra con créditos oponibles, el actor debe accionar con una *deductio* de ellos, de tal modo que la condena sea sólo por el saldo restante (Gayo, 4.65).

§ 148. *Cessio bonorum*. El deudor que actuando sin dolo llegare a una situación de insolvencia, gozaba de la posibilidad de ceder sus bienes a los acreedores (*cessio bonorum*). Debía pedir al magistrado, y los acreedores la debían aceptar, procediéndose luego a la venta de los bienes. El deudor evitaba con esta cesión del patrimonio la ejecución personal, así como la tacha de infamia.

1. Este procedimiento era muy usual. Era posible en virtud de una *lex Iulia de bonis cedendis* (C.7.71.4). Gayo (3.78) la denomina simplemente *lex Iulia*. Para algunos se trataba de un capítulo de la *lex Iulia iudiciorum privatorum* (año 17 a.C.); para otros, era de la época de César.

2. Quien había cedido sus bienes, por las deudas anteriores a la cesión, continúa obligado, pero goza del "beneficio de competencia", de tal modo que debía pagar según sus posibilidades patrimoniales (*in id quod focere potest*: Inst., 4.6.40; Ulp., D.42.3.4).

Justiniano (Ulp., D. 42.3.6 itp.) entendió que se le debía permitir al cedente de los bienes, la posibilidad de reconstituir su patrimonio, de tal modo que si adquirió una nueva y pequeña cosa (así, una anualidad o mensualidad de alimentos, o un usufructo de alimentos) no se lo podía ejecutar por la *venditio bonorum*.

§ 149. *Distractio bonorum*. En algunos casos excepcionales se permite la ejecución, no de todo el patrimonio, sino de los bienes singulares, uno a uno, hasta satisfacer a los acreedores (*distractio bonorum*).

1. Así, entre estos beneficiados, figuraban en el Edicto, el caso del incapaz de hecho carente de tutor

o curador (Paulo, D.42.5.6 pr.; Ulp., D.42.4.7.11). Igualmente respecto de personas de la clase senatorial (*cleras personae*), un a.c. dispuso en general que en lugar de la *venditio bonorum*, les sea nombrado un *curator bonorum* (Gayo, D.27.10.5), pudiendo los acreedores mismos proponer al deudor esta forma de pago (Juliano, D.42.7.5).

PARTE TERCERA

PROCEDIMIENTO EXTRA ORDINEM (LA COGNITIO)

§ 150. *Generalidades*. Hemos visto que en el procedimiento formulario la actuación sucedía en dos etapas (*in iure* y *apud iudicem*). En la primera intervenía el magistrado, quien analizaba si correspondía o no el amparo jurisdiccional (*quaestio iuris*); y luego pasaba la fórmula al *iudex*, quien luego de merituar las pruebas traídas (*quaestiones facti*), dictaba la sentencia. Este *iudex* era siempre una persona privada (del *ordo iudiciorum privatorum*).

Pero ya desde la época de Augusto se instituye para ciertas causas un procedimiento especial (*extra ordinem*). Se caracteriza por cuanto desaparece la bipartición de las etapas *in iure* y *apud iudicem*. Las cuestiones son directamente resueltas por un magistrado-juez, quien ahora no es privado, sino que aparecen como funcionarios oficiales, delegados en forma mediata o inmediata del Príncipe.

En la época posclásica asistimos a la desaparición del procedimiento formulario (u ordinario), y a una correlativa ampliación de este nuevo procedimiento *extra ordinem*. De este modo, la jurisdicción pasa a manos de estos jueces oficiales quienes asumirán por entero todo el conocimiento (*cognitio*) del juicio, desde la citación hasta la sentencia. De ahí que esta nueva vía jurisdiccional sea conocida como "procedimiento cognitorio".

1. En la época del Principado, este procedimiento *extra ordinem* se aplicaba en ciertas causas especiales, generadas por situaciones rodeadas de cierta complejidad. Así, las causas referidas a los fideicomisos eran tramitadas ante el *praetor fideicommissarius*, lo mismo que las que versaban sobre tutelas (*praetor tutelaris*) y sobre causas de libertad (*praetor de liberibus causis*); la *querela inofficiosi testamenti*; causas sobre honorarios profesionales, etc.

2. A su vez, en las provincias, si bien se suele enunciar que regía el procedimiento formulario, basándose en principio en el *Edictum provinciale*, parece cierto que no conservó las mismas características que tenía en Roma. Las causas debían suceder ante el gobernador (*praeses*), pero éste acostumbraba nombrar directamente al juez (*iudex datus*), entre las personas

de su confianza. Se aproximaban a los *iudices pedanei*, revistiendo un carácter oficial, ya que eran como delegados del gobernador.

3. Bajo Adriano, las importantes innovaciones producidas (la aprobación del Edicto Perpetuo, la formación del *Consilium* de juristas oficiales y el *ius novum* producido por los rescriptos y las constituciones imperiales) permiten apreciar un interés cada vez más creciente por el nuevo procedimiento de la *cognitio*. Ya en la segunda mitad del siglo II, desplazó, en Italia, al procedimiento formulario. Y en la misma Roma, hacia mediados del siglo III también dejó de practicarse. Bajo Diocleciano ya no se habla de división del procedimiento en dos etapas, desapareciendo definitivamente por una constitución de Constantino y Constante (C.2.57.1; año 342).

4. Para la aplicación de la *cognitio* aparecen funcionarios especiales, determinándose una verdadera burocracia judicial:

a) En las ciudades de Roma y de Constantinopla, el juez ordinario era el *praefectus urbi*, el cual ya durante el siglo III ha ido desplazando al pretor.

b) En las provincias, ahora mucho más reducidas, para las causas más importantes, el juez era el gobernador de ella (*praeses*; o también *corrector* o en otros casos *consulares*). Pero éste solía delegar la función judicial en jueces nombrados por él (*iudices dati* o *iudices pedanei*: que están a sus pies, es decir le están subordinados); en otros casos intervenían los *vicarii* a cargo de una diócesis.

En los asuntos de menor importancia intervenían funcionarios municipales (*duumviri iure dicundo*) y más tarde el *defensor civitatis*, que en un principio era un protector de los intereses ciudadanos, pero que luego irá extendiendo sus funciones, atendiendo jurisdiccionalmente causas jurídicas.

c) Entre los jueces superiores, están principalmente los *praefecti pretorio* (2 en Oriente y 2 en Occidente), que actúan en grado de apelación como representantes del Emperador (*vices Principis*). A su vez, el Emperador —salvo contra las decisiones de un *praefectus*— es la instancia suprema.

Todos estos jueces están asistidos por asesores (*adsores*) y un cuerpo de oficiales (*militia cohortalis*).

§ 151. *Características*. El nuevo procedimiento de la *cognitio* se fundamenta ahora en una mayor caracterización del juicio como público y autoritario. De este modo, el juez tiene un mayor poder, pudiendo adaptar el procedimiento a las circunstancias con un arbitrio más amplio. A su vez, las partes quedan constreñidas al juicio, prescindiéndose del acto de sumisión formal de los litigantes, como ocurría con la *litis contestatio* en el procedimiento formulario.

§ 152. *Marcha del procedimiento*: A) *Comparecencia de las partes*. Se emplea la *litis de-*

nuntiatio, que en un principio es privada, pero desde Constantino es realizada por un oficial público que la redacta y hace llegar al demandado (CTH. 2.4.2).

Justiniano la reemplaza por el *libellus conventiois*, que era una citación escrita del juez, a pedido del actor. En ella se expresan sumariamente las pretensiones del actor, y son llevadas por un *viator* o *executor* al demandado. Éste debe dar caución de comparecer (*cautio iudicis sisti*; D.2.6). Si una de las partes no comparece el procedimiento continuará en rebeldía. Esto no significa que el demandado pierda el juicio, pero indudablemente se encontrará más indefenso al no presentarse.

§ 153. B) *Actuación ante el juez*. Si ambas partes comparecen ante el juez, se inicia el juicio. El actor alega sus peticiones en la *narratio* y el demandado en la *contradictio* (C.3.9; C.2.58.2 pr., año 531; C.3.14.4; año 530). Pueden ocurrir, como en la época clásica, *interrogationes in iure*, la *confessio* y las provocaciones al *lusu-randum*.

1. El procedimiento ya no se desarrolla al aire libre, sino en salas cerradas. El acto del juez de escuchar a las partes se denomina *audientia*. Las partes y ciertas personas tienen acceso al *secretarium*; el público debía mantenerse separado por barreras y velos, que se abren sólo ante la lectura de la sentencia; a este acto debe asistir el demandado. Ambas partes deben prestar el *iuramentum non calumniae*, asegurando que litigan no haciendo un uso desorbitado de sus derechos.

2. Si bien el procedimiento continúa siendo oral, la burocracia bizantina, muy amante de lo escrito, obliga a que se tengan que levantar actas de los actos procesales. También, por escrito se realizan las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio (*interlocutiones*). Estas piezas escritas tendrán importancia para la apelación.

3. Cuando ambas partes han expresado sus posiciones, se sigue hablando de *litis contestatio* (C.3.1.14.4.1). Pero ésta se ha desnaturalizado, perdiendo la eficacia que tenía en el procedimiento formulario. No se produce la novación judicial como en la época clásica, quedando el efecto pertinente trasladado a la sentencia.

4. Por otra parte, el demandado puede oponer excepciones (ahora designa toda clase de defensas). Si se trata de excepciones dilatorias deben ser alegadas antes de la *litis contestatio*, pero pueden ser probadas luego que el actor ha probado su derecho (C.4.19.19). En el caso de las excepciones perentorias ("perpetuas"), éstas pueden en época de Justiniano ser opuestas en cualquier etapa del juicio, incluso después de la *litis contestatio*, y aun de la *appellatio* (C.7.62.6.1).

§ 154. C) *Las pruebas*. La elección de ellas no se deja simplemente al arbitrio de las partes, sino que incumbió al juez el pedir las que estime necesarias (*plena inquisitio*; CTh. 2.18.1; año 321 = C.3.1.9). A su vez, el juez se ve limitado en la apreciación de las pruebas por ciertas reglas; así, la prueba documental adquiere mayor valor que la testimonial; respecto de ésta se aplica el principio de que no vale el testimonio de un solo testigo (regla: *Unus testis, nullus testis*; CTh. 11.39.3 = C. 4.20.9; año 334). Existen las presunciones, que a veces pueden ser desvirtuadas (presunciones *iuris tantum*) y otras no (presunciones *iuris et de iure*).

§ 155. D) *La sentencia*. La sentencia figuraba por escrito y se la hace pública oralmente. La condena ya no es necesariamente pecuniaria. Si se trata de una *actio in rem* el juez puede ordenar la restitución de la cosa misma (Inst., 4.6.32). Si se trata de una *actio in personam*, el juez debe operar directamente la compensación entre créditos recíprocos de los litigantes, resultando la condena por el saldo (C.4.31.14; año 531).

§ 156. E) *La apelación*. Dado el nuevo carácter escrito de las actuaciones judiciales, y la formación de la burocracia imperial, se permitirá la apelación. De las sentencias de los jueces locales (*iudices dati* o *iudices pedanei*) se puede apelar ante el *praefectus praetorio* o ante el *vicarius*, que es un superior de los gobernadores. De las decisiones del *vicarius* se puede ir nuevamente en apelación al Emperador. En cambio, las decisiones del *praefectus praetorio*, dado su carácter de representante directo del emperador (*vice sacra*), eran inapelables.

1. En la época clásica, cuando se actuaba *extra ordinem*, la apelación debía ser presentada en dos o tres días. Si el juez la admitía, la elevaba con lo actuado al superior. Caso contrario, debía elevar la misma (*relatio*) a la jurisdicción superior, dándole copia al apelante (*editio opinionis*; Macer, D.49.5.6). En caso de fracaso de la apelación, el recurrente debía pagar una pena pecuniaria igual a la tercera parte del valor del pleito (Ulp., D.49.4.1.5; Paulo, 5.33).

2. En el Bajo Imperio, el apelante tenía 10 días para recurrir ante el juez, ya verbalmente o por escrito, siendo esto último lo más usado. Si en cinco días el juez no se pronunciaba, el apelante podía ir directamente al juez superior, y si tenía éxito, el inferior era severamente sancionado.

Si el juez acepta la apelación, debía enviar el escrito del recurrente (*relatio*), así como las réplicas (*libelli refutatorii*), al superior, pero Justiniano determinó que esta tarea le incumbía al apelante (Nov. 126).

3. Por una constitución muy peligrosa de Constantino, si la apelación no progresaba, el recurrente podía ser condenado, si era pudiente, a dos años de destierro (*relegatio in insula*), y de la pérdida de la mitad de sus bienes, o, si se trataba de un pobre, a dos años de trabajos forzados en las minas (CTh. 1.5.3). Justiniano, mencionando una constitución de Diocleciano, atemperó estas penalidades, permitiendo que el juez pronunciara una pena moderada contra la apelación injustificada (C.7.62.4).

4. Para asuntos importantes, el Emperador podía recibir una apelación. En una primera época, estas peticiones (*supplicationes*) eran atendidas por una sección de la Cancillería imperial (*o cognitionibus*), de tal modo que luego de haber escuchado a las partes, el Príncipe consulta con su *consilium*, y finalmente decide la cuestión con un *decretum*. Otras veces, el Príncipe (por medio de la sección *a libellis* de la Cancillería), delegaba su función en un juez, al que le remitía un *rescriptum* con instrucciones (*libellus datus*).

Esto fue lo acostumbrado hasta mediados del siglo V, pero Theodosio II decidió que el asunto debía ser decidido ya por el *praefectus praetorio*, ya por el cuestor del palacio (*quaestor sacri palatii*; algo así como el ministro de justicia; C.7.62.32). En este caso, el *quaestor* obraba mediante el procedimiento del *rescriptum* imperial, firmando luego la sentencia definitiva. Justiniano encargó las apelaciones a dos funcionarios, quienes junto con el cuestor del Sacro Palacio debían resolver en definitiva (C.7.62.34).

5. El poder judicial del Emperador se hace sentir de diversas formas:

a) Si bien contra las decisiones del *praefectus praetorio* no hay *appellatio*, como remedio supletorio el Emperador puede atender una *supplicatio* (súplica), pudiendo resolver éste encomendar que contemple nuevamente el caso dicho prefecto (o su sucesor).

b) Si el juez ordinario encuentra oscura la cuestión y no se atreve a dar la sentencia, puede elevarla para su conocimiento al Emperador (procedimiento de relación o consultivo). Esto es distinto de la apelación, que presupone el dictado de la sentencia. Pero a veces, la *appellatio* fue equiparada al procedimiento de relación (*appellatio more consultationis*).

c) Otras veces, el actor, antes de iniciar el juicio, dada su importancia, dirigía un pedido (*preces*) al Emperador para que éste resolviera el caso con un *rescripto*. El juez ordinario está obligado a acatar la decisión imperial, siempre y cuando no se haya faltado a la verdad de la cuestión planteada. Por eso, el *rescripto* era con la salvedad de que "el ruego no faltaba a la verdad" (*si preces veritate nituntur*). Al demandado le cabe la defensa de alegar que la causa no ha sido expuesta conforme a la verdad, y que por ello el *rescripto* no le es aplicable. Este procedimiento, muy costoso, era empleado cuando el juez ordinario estaba sospechoso de corruptibilidad.

§ 157. *El procedimiento arbitral*. Ya desde la época clásica era posible dilucidar un litigio sin acudir a la jurisdicción del magistrado. Para ello se acordaba entre las partes un *compromissum*, designando un árbitro que debía aceptar el cometido (*receptum arbitri*).

1. El *compromissum* determinaba: a) que por medio de un *pactum* se renunciaba a la acción; de no acatarse daba lugar a una *exceptio*, y b) el acuerdo por medio de estipulaciones penales de acatar la resolución del árbitro. Si el *arbitrator* no se pronunciaba, se daba contra él una *actio in factum*. Justiniano le da al *compromissum* valor de "pacto legitimo", dándole a lo decidido fuerza de sentencia.

2. En la época cristiana se acostumbró a acordar que el litigio fuera resuelto por el obispo del lugar, aprovechando su ascendiente moral sobre los fieles. El procedimiento era libre y las decisiones episcopales (*episcopalis audientia*) podían ser ejecutadas ante los jueces ordinarios (CTh. 16.2.13 (año 376); Nov. Valent., 35 pr. (452), C. 1.3.25 pr. (456?); etc.).

Constantino permitió este procedimiento aun cuando ambas partes ya hubieran iniciado el juicio (CTh. 1.27.1, año 313?) y hasta bastaba que una de las partes quisiera seguir este procedimiento episcopal (*const. Sirmond.* 1, año 331). Pero desde fines del siglo IV se requiere el acuerdo de ambas partes.

§ 158. *Las vías de ejecución*. Estas dependen de las distintas condenas. Lo significativo es que la ejecución no depende de la actividad privada, sino que corresponde a la fuerza pública, que actuará por medio de un *executor*.

1. Si se trata de la restitución de una cosa, se puede ordenar que el demandado la entregue por la fuerza (*manu militari*; Ulp., D.6.1.68 ítp.).

2. Si se trata del pago de una suma de dinero, y el condenado aparece como una persona solvente, los *executores* embargarán bienes suficientes en carácter de prenda, siendo luego vendidos (*pignus ex causa iudicati captum*).

3. Si se trata de un deudor que aparece como insolvente, los acreedores podrán pedir la *missio in bona* de los bienes del condenado, incluyendo esta medida también en favor de los acreedores que no han intervenido en el juicio. Se espera un plazo de 2 años para quienes viven en la misma provincia, y de

4 años si viven en distinta provincia. Pero no se sigue la *venditio bonorum*, sino el procedimiento de la venta individualizada de los bienes (*distractio bonorum*), deteniéndose la venta cuando se alcanza a satisfacer a los acreedores.

4. En el Bajo Imperio se continúa admitiendo también la prisión corporal privada, siempre y cuando que el deudor, para salvar su honor no haya efectuado la "cesión de bienes" (*cessio bonorum*).

De ésta no pueden usar los deudores deshonestos o imprudentes que han dilapidado o sustraído bienes del patrimonio. Por una constitución del año 379 (CTh. 4.20.1) se decide que no es permitida la cesión de bienes salvo que se trate de insolvencia producida por un caso de fuerza mayor (incendio, naufragio, etc.). Justiniano, más amplio, permite una cesión de bienes extrajudicial (Marciano, D.42.3.9 ítp.), agregando que el deudor debe jurar que ha abandonado todos sus bienes a los acreedores sin haber sustraído nada.

5. Los emperadores Theodosio, Valentiniano y Arcadio sustituyeron la prisión privada del deudor por la prisión pública (CTh. 9.11.1; año 388). A pesar de que se consideraba crimen de lesa majestad retener al deudor en prisión privada, los acreedores poderosos (*potentes*), aprovechándose de la falta de ejecución por parte del poder central, la seguían usando, sobre todo en Egipto. Se trató de reprimir los abusos (C.9.5.1) y Justiniano atenuó las penas a los infractores, con la esperanza de que los magistrados lo vieran como un aliciente para no dudar en aplicar la prohibición de prisiones privadas (C.9.5.2).

§ 159. *Apreciación de la cognitio*. En suma, la *cognitio* o procedimiento *extra ordinem*, no obstante algunas imperfecciones, y no haberse desprendido del todo de ciertas reglas que venían de un procedimiento distinto, como lo era el formulario, se mostró muy superior a las experiencias procesales anteriores, tanto el de las *legis actiones*, como el mismo de la época clásica. Bajo estas circunstancias, pese al lenguaje classicista de Justiniano, en cierto modo distorsiona al estudioso romanista la autenticidad de las instituciones clásicas. Pero su virtud principal fue la de tratar de hacer prevalecer el fondo sobre la forma. Les resultó muy útil a los canonistas, y a partir de ellos es que pasa a ser la base del procedimiento moderno y actual.

PARTE SEGUNDA
DERECHO DE LAS PERSONAS